

스터디파이터 감정평가사 민법 핵심요약서

2026년 대비

감정평가사
1차 합격을
위한
민법
핵심요약서

제1판

감정평가사 민법

핵심정리

C O N T E N T S



PART

01

민법총칙

PART

02

물권법

PART 01

민법 총칙

CHAPTER 01	서론	006
CHAPTER 02	권리의 주체(자연인)	015
CHAPTER 03	권리의 주체(법인)	033
CHAPTER 04	권리의 객체(물건)	045
CHAPTER 05	법률행위	052
CHAPTER 06	기간과 소멸시효	094

PART 02

물권법

CHAPTER 01	물권변동	110
CHAPTER 02	점유권	119
CHAPTER 03	소유권	125
CHAPTER 04	용익물권	139
CHAPTER 05	담보물권	149



PART

01

민법총칙

감정평가사 민법 핵심정리

- CHAPTER 01 서론
- CHAPTER 02 권리의 주체(자연인)
- CHAPTER 03 권리의 주체(법인)
- CHAPTER 04 권리의 객체(물건)
- CHAPTER 05 법률행위
- CHAPTER 06 기간과 소멸시효

◎ 단원별 출제경향

구 분	28회	29회	30회	31회	32회	33회	34회
서론	2	0	3	2	2	2	2

제1절 법원(法源)의 순위

제1조 【법원】 민사에 관하여 법률에 규정이 없으면 관습법에 의하고 관습법이 없으면 조리에 의한다.

- ① 법원의 종류(법률·관습법·조리)와 그 순위를 정하고 있다.
- ② 판례의 법원성은 법적으로는 부정되고 있다.
- ③ 민법 제1조에서의 법률은 실질적 의미의 법률을 말하므로, 명령이나 자치법규 등을 포함하는 넓은 의미의 법률이다. 반면 민법 제185조(물권법정주의)에서의 법률은 형식적 의미의 법률이다.

제2절 성문민법과 불문민법

1. 성문민법

성문민법 = 법률(민법전)·명령·대법원규칙·조약·자치법규



헌법재판소의 결정

헌법재판소의 결정은 법률과 동일한 효력을 가지므로 그 결정 내용이 실질적으로 민사에 관한 것인 때에는 민법의 법원이 된다.

- ① 민법 제764조의 적용에 있어서 사죄광고를 명하는 판결은 위헌이라는 결정(헌재 1991.4.1. 89헌가160)
- ② 임대차의 존속기간은 20년을 넘지 못한다고 규정한 제651조제1항에 대한 위헌 결정(2013.12.26. 2011헌바234)

2. 불문민법

불문민법 = 관습법·판례법·조리

(1) 관습법

- ① 관습법의 성립요건
 - ㉠ 법적 내용에 관한 민사관행이 있어야 한다.
 - ㉡ 관행이 법적 가치를 가진다는 법적 확신(법원의 판결)에 의하여 지지를 받아야 한다.
 - ㉢ 관행이 사회질서에 반하지 않아야 한다.
- ② 인정되는 제도
 - ㉠ 분묘기지권·관습법상의 법정지상권·동산의 양도담보권이 있다.
그러나 온천권, 미등기 무허가건물에 대한 소유권취득이나 근린공원이용권 등은 관습법상의 물건에 해당하지 않는다.
 - ㉡ 관습법상의 공시방법으로서 미분리과실과 수목집단에 대한 명인방법이 있다.

(2) 판례법

(3) 조리(條理)

경험칙·신의칙·사회통념 등으로 표현하기도 한다.

제3절 신의성실의 원칙

1. 의의

법률관계에 참여한 모든 자는 상대방의 정당한 이익을 고려할 의무를 진다는 것이며, 즉 상대방의 신뢰를 헛되이 하지 않도록 성실하게 행동하여야 한다는 원칙을 말한다. 당사자의 행위규범이자 법관의 재판규범이 될 수 있다.

2. 근거

“권리의 행사와 의무의 이행은 신의에 좇아 성실히 하여야 한다.”(법 제2조 제1항)

3. 적용

- ① 신의성실의 원칙은 민법의 전 영역에 적용되며 사법의 전 영역과 나아가 사회법 및 공법에도 적용된다.
- ② 신의칙위반을 이유로 제한능력자의 취소권을 배척하지는 못한다.
우리 민법상 제한능력자 제도는 어떤 제도보다 우월하게 적용된다.

4. 파생원칙

(1) 실효의 원칙

권리를 장기간 행사하지 않아서 상대방이 그 권리를 행사하지 않는 것으로 믿을 만한 사유가 있을 후 새삼스럽게 그 권리를 행사하는 것은 이 원칙에 반하여 인정되지 않는다.

(2) 사정변경의 원칙

계속적 채권관계, 즉 계속적인 보증계약에 있어서 보증계약 성립 당시의 사정에 현저한 변경이 생긴 경우에는 사정변경을 이유로 보증계약을 해지할 수 있다고 한다. 사정변경의 원칙은 계약준수의 원칙의 예외로서 인정된다.

(3) 금반언(禁反言)의 원칙

자신의 선행행위와 모순되는 행위는 허용되지 않는다는 원칙이다.

제4절 권리남용금지의 원칙

1. 의의 및 근거

외형상은 권리의 행사와 같이 보이지만 구체적·실질적으로 볼 때에는 권리의 사회성·공공성에 반하여 권리의 행사로서 인정될 수 없는 행위를 말한다. 민법은 “권리는 남용하지 못한다.”라고 규정(제2조 제2항)하고 있다.

2. 적용

권리남용금지원칙은 신의칙과 함께 민법 전체에 적용되는 규정이며, 공법분야에도 이 원칙은 적용된다.

3. 요건

- ① 권리의 행사가 있을 것(권리의 불행사가 권리남용이 되는 경우가 있음)
- ② 권리의 행사가 사회성·공공성에 반할 것
- ③ 가해목적이 존재할 것(주관적 요건)
- ④ 위법성이 있을 것

4. 판례의 태도

대법원의 판례는 대체로 주관적 요건과 객관적 요건을 모두 그 요건으로 요구하고 있다.

5. 남용의 효과

- ① 청구권의 행사가 남용이 되면 법은 조력(助力)하지 않는다(주장배척).
- ② 형성권의 행사가 남용이 되면 효과의 발생이 부정된다.
- ③ 친권의 행사가 남용이 되면 친권상실 또는 일시정지의 선고를 받는 경우가 있다(제924조).
- ④ 항변권의 행사가 남용이 되면 권리의 행사가 저지된다.

제5절 권리의 분류

01 권리의 기본적 분류

	종류	내용
내용에 의한 분류	재산권	경제적 이익을 누리는 것을 내용으로 하는 권리로서 양도성과 상속성을 가지는 권리이다(물권·준물권·채권·지식재산권).
	인격권	권리의 주체와 분리할 수 없는 인격적 이익을 누리는 것을 내용으로 하는 권리이다(생명권·신체권·명예권·정조권·성명권·초상권 등).
	가족권	가족관계 내지 친족관계에 있어서의 일정한 지위에 따르는 이익을 누리는 것을 내용으로 하는 권리이다(친권·부양청구권·상속권 등).
	사원권	사단의 구성원이 그 지위에 기하여 사단에 대하여 가지는 권리를 말한다(이익배당청구권·의결권·업무집행권 등).
작용에 의한 분류	지배권	권리의 객체를 직접 배타적으로 지배할 수 있는 권리로서 절대권 또는 대세권이라고도 한다(인격권·물권·지식재산권·친권 등).
	청구권	특정인이 다른 특정인에 대하여 일정한 행위(급부)를 요구할 수 있는 권리이다(채권·물권적 청구권·부양청구권·재산분할청구권·계약갱신청구권 등).
	형성권	권리자의 일방적 의사표시만으로 권리의 발생·변경·소멸의 효과가 생기는 권리를 말하며, 상대방의 동의나 승낙을 요하지 않는다(별도로 설명).
	항변권	타인의 청구권의 행사를 저지하는 권리를 말한다(연기적 항변권으로서의 동시이행의 항변권과 보증인의 최고·검색의 항변권이 있고, 영구적 항변권으로서 상속인의 한정승인의 항변권이 있다).

일방적 의사표시에 의하여 행사하는 것	동의권, 철회권, 상계권, 추인권, 해지권, 해제권, 취소권, 매매의 일방예약완결권 등이다.
재판에 의하여 행사하여야 하는 것	① 채권자취소권은 실체법상의 권리이지만 반드시 재판상 행사하여야 한다(406조). ② 재판상 이혼권(840조), 친생부인권(846조), 입양취소권(884조), 재판상 파양권(905조) 등이 있다.
청구권으로 불리지만 형성권으로 해석되는 것	① 공유물분할청구권(268조) ② 지상권자 및 지상권설정자의 지상물매수청구권(283조, 285조) ③ 전세권자 및 전세권설정자의 부속물매수청구권(316조) ④ 치료증감청구권(286조), 매매대금감액청구권(572조), 차임증감청구권(627조, 628조), 전세금증감청구권(312조의2) ⑤ 지상권소멸청구권(287조), 전세권소멸청구권(311조) 등이 있다. ◎ 계약갱신청구권이나 등기청구권, 상속회복청구권 등은 청구권이다.



핵심 판례 정리

- 01.** 관습법은 당사자의 주장·입증을 기다림이 없이 법원이 직권으로 이를 확정하여야 하고 사실인 관습은 그 존재를 당사자가 주장·증명하여야 한다.
- 02.** 성년 남자만을 종중의 구성원으로 하고 여성은 종중의 구성원이 될 수 없다는 종래의 관습은, 변화된 우리의 전체 법질서에 부합하지 아니하여 정당성과 합리성이 있다고 할 수 없으므로, 종중 구성원의 자격을 성년 남자만으로 제한하는 종래의 관습법은 이제 더 이상 법적 효력을 가질 수 없게 되었다.
- 03.** 동일인 소유이던 토지와 그 지상 건물이 매매 등으로 인하여 각각 소유자를 달리하게 되었을 때 그 건물 철거 특약이 없는 한 건물 소유자가 법정지상권을 취득한다는 관습법은 현재에도 그 법적 규범으로서의 효력을 여전히 유지하고 있다고 보아야 한다(대법원 2022.7.21. 2017다236749 전원합의체).
- 04.** 신의칙은 비단 계약법의 영역에 한정되지 않고 모든 법률관계를 규제·지배하는 원리로 파악되며, 따라서 신의칙에 반하는 소권(訴權)의 행사 또한 허용될 수 없다.
- 05.** 신의성실의 원칙에 반하는 것은 강행규정에 위배되는 것이므로 당사자의 주장이 없더라도 법원은 직권으로 판단할 수 있다.

- 06.** 사용자로부터 해고된 근로자가 퇴직금 등을 수령하면서 아무런 이의의 유보나 조건을 제기하지 않았다면, 다른 특별한 사정이 없는 한 해고처분을 유효한 것으로 인정했다고 할 것이고, 따라서 해임 및 의원 면직된 후 9년이 지난 후에 해고의 효력을 다투는 소송을 제기하는 것은 신의칙이나 금반언의 원칙에 위배된다.
- 07.** 신의성실의 원칙에 위배된다는 이유로 권리의 행사를 부정하기 위해서는 상대방에게 신의를 공여하였거나 객관적으로 보아 상대방이 신의를 가짐이 정당한 상태에 있어야 하며, 이러한 상대방의 신의에 반하여 권리를 행사하는 것이 정의관념에 비추어 용인될 수 없는 정도에 이르러야 한다.
- 08.** 취득시효완성 후에 그 사실을 모르고 당해 토지에 관하여 어떠한 권리도 주장하지 않기로 하였다가 이에 반하여 시효주장을 하는 것은 특별한 사정이 없는 한 신의칙상 허용되지 않는다.
- 09.** 법정대리인의 동의 없이 신용구매계약을 체결한 미성년자가 사후에 법정대리인의 동의 없음을 사유로 들어 이를 취소하는 것이 신의칙에 위배된 것이라고 할 수 없다.
- 10.** 강행법규를 위반한 자가 스스로 그 약정의 무효를 주장하는 것이 신의칙에 위반되는 권리의 행사라는 이유로 그 주장을 배척한다면, 강행법규에 의하여 배제하려는 결과를 실현시키는 결과가 되므로 특별한 사정이 없는 한 위와 같은 주장은 신의칙에 반하는 것이라고 할 수 없다.
- [판례해설]** 법령에 위반되어 무효임을 알고서도 그 법률행위를 한 자가 강행법규 위반을 이유로 무효를 주장한다 하여 신의칙 또는 금반언의 원칙에 반하거나 권리남용에 해당한다고 볼 수는 없다.
- 11.** 회사의 이사의 지위에서 부득이 회사와 제3자 사이의 계속적 거래로 인한 회사의 채무에 대하여 보증인이 된 자가 그 후 퇴사하여 이사의 지위를 떠난 때에는 보증계약 성립 당시의 사정에 현저한 변경이 생긴 경우에 해당하므로 이를 이유로 보증계약을 해지할 수 있다.
- 12.** 병원은 진료뿐만 아니라 환자에 대한 숙식의 제공을 비롯하여 간호, 보호 등 입원에 따른 포괄적 채무를 지는 것인 만큼, 입원환자의 휴대품 등의 도난을 방지함에 필요한 적절한 조치를 강구하여 줄 신의칙상의 보호의무가 있다.
- 13.** 동시이행의 항변권의 행사가 주로 자기 채무의 이행만을 회피하기 위한 수단이라고 보여지는 경우에는 그 항변권의 행사는 권리남용으로서 배척된다.
- 14.** 아파트 분양자는 아파트단지 인근에 공동묘지가 조성되어 있는 사실을 수분양자에게 고지할 신의칙상의 의무를 부담한다.

- 15.** 권리의 행사가 주관적으로 오직 상대방에게 고통을 주고 손해를 입히려는 데 있을 뿐 이를 행사하는 사람에게는 아무런 이익이 없고, 객관적으로 사회질서에 위반된다고 볼 수 있으면, 그 권리의 행사는 권리 남용으로서 허용되지 아니하고, 그 권리의 행사가 상대방에게 고통이나 손해를 주기 위한 것이라는 주관적 요건은 권리자의 정당한 이익을 결여한 권리행사로 보여지는 객관적인 사정에 의하여 추인할 수 있다(대법원 2010. 12. 9. 2010다59783).
- 16.** 학교의 편입학허가가 교육법에 위반되어 무효라면 이와 같은 당연무효의 행위를 학교법인이 취소하는 것은 그 편입학허가 등의 행위가 처음부터 무효이었음을 당사자에게 통지하여 확인시켜주는 것에 지나지 않으므로 여기에 신의칙을 적용할 수 없고 그러한 뜻의 취소권은 시효로 인하여 소멸하지도 않는다.
- 17.** 변호사와 의뢰인 사이에 약정된 보수액이 부당하게 과다하여 신의성실의 원칙이나 형평의 원칙에 반한다고 볼 만한 특별한 사정이 있는 경우에는, 상당하다고 인정되는 범위 내의 보수액만을 청구할 수 있다.
- 18.** 인지청구권은 본인의 일신전속적인 신분관계상의 권리로서 포기할 수도 없으며 실�효의 법리가 적용되지 않는다.



중요 지문 정리

- 01.** 신의성실의 원칙은 법질서 전체를 관통하는 일반 원칙으로서 실정법이나 계약을 형식적이고 엄격하게 적용할 때 생길 수 있는 부당한 결과를 막고 구체적 타당성을 실현하는 작용을 하므로, 사적 자치나 계약자유도 신의칙에 따라 제한될 수 있다. ()

신의성실의 원칙은 법질서 전체를 관통하는 일반 원칙으로서 실정법이나 계약을 형식적이고 엄격하게 적용할 때 생길 수 있는 부당한 결과를 막고 구체적 타당성을 실현하는 작용을 한다. 사적 자치나 계약자유도 신의칙에 따라 제한될 수 있다(대법원 2018. 5. 17. 2016다35833). (○)

- 02.** 판례에 의하여 인정되는 관습법으로는 분묘기지권, 동산양도담보 등이 있고, 관습법상 인정되는 물권으로는 사도통행권, 온천권 등이 있다. ()

판례에 의하여 인정되는 관습법으로는 분묘기지권(2013다17292)·관습법상의 법정지상권, 명인방법·명의신탁·동산양도담보 등이 있다. 그러나, 사도(私道)통행권·온천권·공원이용권 등은 관습법상 인정되는 물권이 아니다. (×)

- 03.** 종중의 구성원인 종원의 자격은 성년의 남자로서만 제한된다. ()

종중이란 공동선조의 분묘수호와 제사 및 종원 상호간의 친목 등을 목적으로 하여 구성되는 자연발생적인 종족집단이므로, 종중의 이러한 목적과 본질에 비추어 볼 때 공동선조와 성과 본을 같이 하는 후손은 성별의 구별 없이 성년이 되면 당연히 그 구성원이 된다고 보는 것이 조리에 합당하다. (×)

04. 사회생활규범이 관습법으로 승인되었다면 그것을 적용하여야 할 시점에서
의 전체 법질서에 부합하지 않아도, 그 관습법은 법적 규범으로서의 효력
이 인정된다. ()

관습법은 헌법을 최상위 규범으로 하는 전체 법질서에 반하지 아니하는 것으로서 정당성과 합리성이 있다고 인정될 수 있는 것이어야 하고, 그렇지 아니한 사회생활규범은 비록 그것이 사회의 거듭된 관행으로 생성된 것이라고 할지라도 이를 법적 규범으로 삼아 관습법으로서의 효력을 인정할 수 없다(대법원 2005.07.21. 2002다 1178 전원합의체). (X)

05. 신의성실의 원칙에 반하는 것은 강행규정에 위배되는 것으로서 당사자의
주장이 없더라도 법원이 직권으로 판단할 수 있다. ()

신의성실의 원칙에 반하는 것 또는 권리남용은 강행규정에 위배되는 것이므로 당사자의 주장이 없더라도 법원은 직권으로 판단할 수 있다(대법원 1998.08.21. 97다37821). (O)

06. 임차권의 양도에 있어서 양도인은 그 임차권의 존속기간, 임대기간 종료 후
의 재계약 여부, 임대인의 동의 여부와 이에 관계되는 모든 사정을 양수인
에게 알려주어야 할 신의칙상의 의무가 있다. ()

임차권 양도에 관한 임대인의 동의 여부 및 임대차 재계약 여부에 대한 설명 없이 임차권을 양도한 것은 기망행위에 해당하고 신의칙에 위배된다. (O)

07. 분양회사는 아파트단지 인근에 쓰레기 매립장이 건설될 예정이라는 사실을
알았더라도 이를 수분양자에게 고지할 신의칙상 의무를 부담하지 않는다.
()

아파트 분양자는 아파트 단지 인근에 쓰레기 매립장이 건설예정인 사실을 분양계약자에게 고지할 신의칙상 의무를 부담한다(대법원 2006.10.12. 2004다 48515). (X)

08. 법령에 위반되어 무효임을 알고서도 그 법률행위를 한 자가 강행법규 위반
을 이유로 무효를 주장하는 것은 신의칙 또는 금반언의 원칙에 반하므로
허용되지 않는다. ()

법령에 위반되어 무효임을 알고서도 그 법률행위를 한 자가 강행법규 위반을 이유로 무효를 주장하는 것이 신의칙 또는 금반언의 원칙에 반하거나 권리남용에 해당한다고 볼 수는 없다. (X)

09. 신의칙에 위배된다는 이유로 그 권리행사를 부정하기 위해서는 상대방에게
신의를 공여하였거나 객관적으로 보아 상대방이 신의를 가지는 것이 정당
한 상태에 이르러야 하고 이와 같은 상대방의 신의에 반하여 권리를 행사하
는 것이 정의관념에 비추어 용인될 수 없는 정도의 상태에 이르러야 한다.
()

타당한 기술이다(대법원 2019.7.25. 2016다274607). (O)

10. 취득시효 완성 후에 그 사실을 모르고 당해 토지에 관해 어떠한 권리도 주
장하지 않기로 하였다 하더라도 이에 반하여 시효주장을 하는 것은 특별한
사정이 없는 한 신의칙상 허용되지 않는다. ()

타당한 기술이다(대법원 1998.5.22. 96다 24101). (O)

11. 인지청구권의 행사가 상속재산에 대한 이해관계에서 비롯되었다 하더라도 정당한 신분관계를 확정하기 위해서라면 신의칙에 반하는 것이라 하여 막을 수 없다. ()

인지청구권의 행사가 상속재산에 대한 이해관계에서 비롯되었다 하더라도 정당한 신분관계를 확정하기 위해서라면 신의칙에 반하는 것이라 하여 막을 수 없다(대법원 2001.11.27. 2001므1353). (○)

12. 계속적 거래관계로 인하여 발생하는 불확정한 채무를 보증하기 위한 이른바 계속적 보증에 있어서 보증계약 성립 당시의 사정에 현저한 변경이 생긴 경우에는 보증인은 보증계약을 해지할 수 있다. ()

이사의 지위에 있었기 때문에 부득이 회사와 은행 사이의 계속적 거래로 인한 회사의 채무에 대하여 연대보증인이 된 자가 그 후 퇴사하여 이사의 지위를 상실한 경우, 사정변경을 이유로 연대보증계약을 일방적으로 해지할 수 있다(대법원 2000.3.10. 99다61750). (○)

13. 판례는 일반적으로 권리남용의 요건으로 행위자에게 이익이 없으면서 상대방에게 손해·고통만을 주기 위한 목적이 있어야 한다는 주관적 요건은 요구하지 않는다. ()

권리남용의 요건으로는 권리의 존재, 권리의 행사라고 볼 수 있는 행위의 존재, 행위자의 이익과 상대방의 불이익 사이의 불균형(객관적 요건), 행위자에게 이익이 없으면서 상대방에게 손해·고통만을 주기 위한 목적(주관적 요건)이 있어야 한다(대법원 2003다40422). (×)

14. 판례는 일반적으로 권리남용에 있어 주관적 요건을 요구하고 있는데, 권리의 행사가 상대방에게 고통이나 손해를 주기 위한 것이라는 주관적 요건은 권리자의 정당한 이익을 결여한 권리행사로 보이는 객관적인 사정에 의하여 추인할 수 있다. ()

타당한 기술이다(대법원 1998.6.26. 97다4282). (○)

15. 형성권은 반드시 재판상 행사해야 한다. ()

형성권은 권리자의 일방적 의사표시에 의하여 행사하는 것과 반드시 재판에 의하여 행사하여야 하는 것이 있다. 전자에는 동의권, 철회권, 상계권, 추인권, 해지권, 해제권, 취소권, 매매의 일방예약완결권 등이 있고, 후자에는 채권자취소권(제406조), 친생부인권(제846조), 입양취소권(제884조), 재판상 이혼권(제840조) 등이 있다. (×)

16. 공무원의 직무상 불법행위책임에 대하여 국가배상법과 민법의 규정이 경합하는 경우 전자만이 적용된다. ()

공무원의 직무상 불법행위책임에 대하여 국가배상법과 민법의 규정이 경합하는 경우 전자만이 적용되는데 이를 법규의 경합(특별법우선의 원칙)이라고 한다. (○)

◎ 단원별 출제경향

구 분	28회	29회	30회	31회	32회	33회	34회
자연인	3	3	3	3	2	2	2

제1절 자연인의 권리능력

1. 출생의 신고

출생이 있으면 1월 이내에 관계공무원에게 신고하여야 하지만 출생신고의 유무는 권리능력의 취득과는 무관(보고적 신고)하다. 출생신고는 일종의 보고적 신고이지 창설적 신고가 아니므로 신고가 없어도 출생과 동시에 당연히 권리능력을 취득한다.

2. 태아의 권리능력

(1) 우리 민법의 태도(개별적 보호주의)

중요한 법률관계에 대해서만 태아를 이미 출생한 것으로 보는 입법주의, 즉 개별적 보호주의를 취하고 있다.

① 불법행위로 인한 손해배상청구권(제762조)

㉠ 父의 생명침해로 인한 子 자신이 위자료를 청구하는 경우를 말하며, 父의 생명침해로 인한 재산적 손해는 일단 父에게 손해배상청구권이 발생하고 그것이 상속인(태아)에게 상속된다는 것이 판례의 태도이다.

㉡ 태아 자신이 입은 불법행위로 인한 손해에 대하여 배상청구를 하는 경우이다.

② 상속(제1000조)

③ 유류분권(제1112조)

④ 대습상속(제1001조)

⑤ 유증(제1064조)

⑥ 인지(제858조)

父의 태아에 대한 인지는 인정되나 태아의 父에 대한 인지청구권은 부정된다는 것이 판례의 태도이다.

⑦ 사인증여(제562조)

판례는 부정한다. 법률행위의 성질상 유증은 단독행위이고 사인증여는 계약이기에 태아가 승낙할 수가 없다. 그리고 현행법상 태아의 법정대리인제도가 인정되지 않는다.

(2) 태아의 법률상의 지위

개별적 보호주의에 입각하여 태아의 지위를 “이미 출생한 것으로 본다.”의 의미를 어떻게 파악하여야 하는가에 대하여 판례는 정지조건설의 입장이다. 태아의 개별적 보호주의에 따른 그 권리의 행사는 태아가 살아서 출생한다는 것을 전제로 하는 것이다.

제2절 권리능력의 종기(終期)

1. 자연인의 사망

자연인의 권리능력은 심폐정지설(맥박중지설)에 입각한 사망으로 소멸한다.

2. 동시사망의 추정

- (1) 2인 이상이 동일한 위난으로 사망한 경우에는 동시에 사망한 것으로 추정한다(제30조).
- (2) 동시에 사망한 것으로 추정됨으로써 사망자 사이에는 상속의 문제가 발생되지 아니한다.
- (3) 추정규정이므로 반증을 들어 그 추정을 번복할 수 있다.

3. 인정사망

- (1) 사망한 것이 확실하다고 생각되지만 시체를 발견할 수 없는 경우에 그것을 조사한 관공서의 사망보고에 의하여 가족관계등록부에 사망으로 기재하는 제도이다(가족관계등록에 관한 법률 제87조).
- (2) 실종선고는 간주주의를 취하나, 인정사망은 추정주의를 취한다.

4. 실종선고

사망이 확실하지 않으나 그 개연성이 매우 높은 경우에 실종선고에 의하여 일정한 시기에 사망한 것으로 간주하는 제도이다(제27조). 실종자의 종래의 주소나 거소를 중심으로 한 사법적 법률관계만을 종료하게 하는 제도로써 실종자의 권리능력의 상실과는 무관하다.

제3절 행위능력

1. 제한능력자제도의 성격

- ① 제한능력자가 단독으로 행한 법률행위는 원칙적으로 취소할 수 있다.
- ② 제한능력자제도에 관한 규정은 강행규정이며 어떠한 제도보다 우선하여 적용된다.

2. 제한능력자의 법률행위의 효력

- (1) 제한능력자의 법률행위는 제한능력자 측에서 취소할 수 있다(제5조 제2항).
그리고 제한능력에 대한 증명책임은 법률행위의 효력을 부인하는 자에게 있다.
- (2) 취소의 효과는 절대적 취소로서 선의의 제3자에게 대항할 수 있다.
- (3) 취소의 효과로 권리의무에 관하여 아직 이행하지 않은 부분은 이행할 필요가 없게 되지만 이미 이행한 부분은 부당이득으로 서로 반환하여야 한다(제741조).
이 경우에 제한능력자측은 현존이익만을 반환하면 된다(제141조 단서).

제4절 제한능력자의 유형

미성년자

1. 미성년자의 의의

(1) 미성년자

만 19세 미만자로서 혼인하지 않는 자를 미성년자라고 한다.

(2) 혼인에 의한 성년의제(성년간주)

- ① 미성년자가 법정대리인의 동의를 얻어 혼인한 경우 성년자와 같은 능력을 갖는다.
- ② 성년의제는 민사상의 법률관계에 한하여 적용되며, 공법상의 법률관계에는 적용되지 않는다.
- ③ 혼인이 해소되거나 혼인이 취소된 경우에도 성년의제의 효과는 소멸하지 않는다.

2. 미성년자의 행위능력

(1) 원칙

미성년자가 법률행위를 하려면 원칙으로 법정대리인의 동의를 얻어야 한다(제5조 제1항 본문).
동의를 얻지 않은 법률행위는 미성년자 본인이나 법정대리인이 이를 취소할 수 있다(동조 제2항).

(2) 예 외

다음의 경우에는 미성년자가 법정대리인의 동의 없이 단독으로 법률행위를 할 수 있지만 의사능력은 가지고 있어야 한다.

- ① 권리만을 얻거나 의무만을 면하는 행위(제5조 제1항 단서)
 - ㉠ 부담 없는 증여를 받거나 채무면제를 받는 행위, 서면에 의하지 않은 증여계약의 해제(제555조)
 - ㉡ 부담부 증여, 상속의 승인, 경제적으로 유리한 매매계약을 체결하는 행위, 변제를 받는 행위 등은 법정대리인의 동의를 요한다.
- ② 처분(포괄적인 재산처분의 허락이 아니라 범위를 정하여)이 허락된 재산의 처분행위(제6조)
- ③ 허락받은 영업에 관한 행위(제8조 제1항)
 - ㉠ 법정대리인이营业을 허락함에 있어서는 반드시 영업의 종류를 특정하여야 한다. 따라서 모든營業을 허락하거나, 영업 중의 일부만을 허락할 수는 없다.
 - ㉡ 미성년자의 허락받은 영업에 관한 행위(점포임대차, 점원고용, 자금차입 등)에 관하여는 법정대리인의 대리권은 소멸한다.
- ④ 대리행위(제117조)

대리인은 행위능력자임을 요하지 않으므로 미성년자인 대리인의 대리행위로 인한 모든 법률효과는 직접 본인에게 귀속되고 대리행위로 인한 불이익이 미성년자에게 귀속되지 않으므로 허용된다.
- ⑤ 혼인을 한 미성년자의 행위(제826조의2)
- ⑥ 유언행위(제1061조)

만 17세에 달한 미성년자는 단독으로 유효하게 유언을 할 수 있다.
- ⑦ 근로계약의 체결과 임금의 청구(근로기준법 제67조·제68조)

임금의 청구에 대하여는 법정대리인의 대리권이 제한된다.

(3) 동의와 허락의 취소 또는 제한

- ① 미성년자가 법률행위를 하기 전에는 법정대리인은 동의나 일정범위의 재산처분에 대한 허락을 취소할 수 있다(제7조). 여기서의 취소는 철회의 의미로 해석한다. 따라서 소급효가 없다. 철회의 상대방은 미성년자나 그 상대방이 된다.
- ② 법정대리인은 미성년자에게 한 영업의 허락을 취소(철회) 또는 제한할 수 있으나 그것을 가지고 선의의 제3자에게는 대항할 수 없다고 해석한다(제8조 제2항). 미성년자와 거래한 상대방을 보호하기 위한 규정이다.
- ③ 동의를 받은 미성년자가 단독으로 법률행위를 행하기 위해서는 적어도 의사능력을 필요로 한다.

(4) 미성년자의 법정대리인(法定代理人)

- ① 미성년자의 법정대리인이 되는 자는 제1차로 친권자이고 제2차로 후견인이다.
- ② 친권은 부모가 혼인 중인 경우에는 공동으로 행사한다.
- ③ 친권자가 없거나 대리권을 행사할 수 없을 때에는 후견인이 법정대리인이 된다.

3. 미성년자의 법정대리인의 권한

(1) 동의권

(2) 대리권

(3) 취소권

법정대리인은 미성년자가 동의를 받지 않고서 행한 법률행위를 취소할 수 있다(제5조 제2항, 제140조 이하).

(4) 추인권

법정대리인은 취소할 수 있는 법률행위를 추인할 수 있다.

피한정후견인

1. 피한정후견인의 의의

제12조 【한정후견개시의 심판】

- ① 가정법원은 질병, 장애, 노령, 그 밖의 사유로 인한 정신적 제약으로 사무를 처리할 능력이 부족한 사람에 대하여 본인, 배우자, 4촌 이내의 친족, 미성년후견인, 미성년후견감독인, 성년후견인, 성년후견감독인, 특정후견인, 특정후견감독인, 검사 또는 지방자치단체의 장의 청구에 의하여 한정후견개시의 심판을 한다.
- ② 한정후견개시의 경우에 제9조제2항을 준용한다.

2. 피한정후견인의 행위와 동의

- ① 가정법원은 피한정후견인이 한정후견인의 동의를 받아야 하는 행위의 범위를 정할 수 있다(제13조 제1항).
- ② 가정법원은 본인, 배우자, 4촌 이내의 친족, 한정후견인, 한정후견감독인, 검사 또는 지방자치단체의 장의 청구에 의하여 제1항에 따른 한정후견인의 동의를 받아야만 할 수 있는 행위의 범위를 변경할 수 있다(제13조 제2항).

- ③ 한정후견인의 동의를 필요로 하는 행위에 대하여 한정후견인이 피한정후견인의 이익이 침해될 염려가 있음에도 그 동의를 하지 아니하는 때에는 가정법원은 피한정후견인의 청구에 의하여 한정후견인의 동의를 갈음하는 허가를 할 수 있다(제13조 제3항).
- ④ 한정후견인의 동의가 필요한 법률행위를 피한정후견인이 한정후견인의 동의 없이 하였을 때에는 그 법률행위를 취소할 수 있다. 다만, 일용품의 구입 등 일상생활에 필요하고 그 대가가 과도하지 아니한 법률행위에 대하여는 그러하지 아니하다(제13조 제4항).

3. 한정후견의 종료

한정후견개시의 원인이 소멸된 경우에는 가정법원은 본인, 배우자, 4촌 이내의 친족, 한정후견인, 한정후견감독인, 검사 또는 지방자치단체의 장의 청구에 의하여 한정후견종료의 심판을 한다(제14조).

피성년후견인

1. 피성년후견인의 의의

제9조 【성년후견개시의 심판】

- ① 가정법원은 질병, 장애, 노령, 그 밖의 사유로 인한 정신적 제약으로 사무를 처리할 능력이 지속적으로 결여된 사람에 대하여 본인, 배우자, 4촌 이내의 친족, 미성년후견인, 미성년후견감독인, 한정후견인, 한정후견감독인, 특정후견인, 특정후견감독인, 검사 또는 지방자치단체의 장의 청구에 의하여 성년후견개시의 심판을 한다.
- ② 가정법원은 성년후견개시의 심판을 할 때 본인의 의사를 고려하여야 한다.

제14조의3 【심판사이의 관계】

- ① 가정법원이 피한정후견인 또는 피특정후견인에 대하여 성년후견개시의 심판을 할 때에는 종전의 한정후견 또는 특정후견의 종료 심판을 한다.
- ② 가정법원이 피성년후견인 또는 피특정후견인에 대하여 한정후견개시의 심판을 할 때에는 종전의 성년후견 또는 특정후견의 종료 심판을 한다.

2. 피성년후견인의 행위와 취소

- ① 피성년후견인의 법률행위는 취소할 수 있다(제10조 제1항).

- ② 제1항에도 불구하고 가정법원은 취소할 수 없는 피성년후견인의 법률행위의 범위를 정할 수 있다
(제10조 제2항).
- ③ 가정법원은 본인, 배우자, 4촌 이내의 친족, 성년후견인, 성년후견감독인, 검사 또는 지방자치단체의
장의 청구에 의하여 제2항의 범위를 변경할 수 있다(제10조 제3항).
- ④ 제1항에도 불구하고 일용품의 구입 등 일상생활에 필요하고 그 대가가 과도하지 아니한 법률행위는
성년후견인이 취소할 수 없다(제10조 제4항).

3. 성년후견의 종료

성년후견개시의 원인이 소멸된 경우에는 가정법원은 본인, 배우자, 4촌 이내의 친족, 성년후견인,
성년후견감독인, 검사 또는 지방자치단체의 장의 청구에 의하여 성년후견종료의 심판을 한다(제11조).

피특정후견인

1. 피특정후견인의 의의

- ① 가정법원은 질병, 장애, 노령, 그 밖의 사유로 인한 정신적 제약으로 일시적 후원 또는 특정한 사무에
관한 후원이 필요한 사람에 대하여 본인, 배우자, 4촌 이내의 친족, 미성년후견인, 미성년후견감독인,
검사 또는 지방자치단체의 장의 청구에 의하여 특정후견의 심판을 한다(제14조의 2 제1항).
- ② 특정후견은 본인의 의사에 반하여 할 수 없다(제14조의 2 제2항).
- ③ 특정후견의 심판을 하는 경우에는 특정후견의 기간 또는 사무의 범위를 정하여야 한다(제14조의 2 제3항).

2. 피특정후견인의 행위능력

- ① 특정후견의 심판을 하는 경우에 가정법원은 특정후견의 기간 또는 사무의 범위를 정하여야 한다.
- ② 특정후견의 심판이 있다고 하여 피특정후견인의 행위능력이 제한되는 것은 아니다.

제5절 제한능력자와 거래한 상대방보호

1. 확답을 촉구할 권리(최고권)

제15조 【제한능력자의 상대방의 확답을 촉구할 권리(최고권)】

- ① 제한능력자의 상대방은 제한능력자가 능력자가 된 후에 그에게 1개월 이상의 기간을 정하여 그 취소할 수 있는 행위를 추인할 것인지 여부의 확답을 촉구할 수 있다. 능력자로 된 사람이 그 기간 내에 확답을 발송하지 아니하면 그 행위를 추인한 것으로 본다.
- ② 제한능력자가 아직 능력자가 되지 못한 경우에는 그의 법정대리인에게 제1항의 촉구를 할 수 있고, 법정대리인이 그 정하여진 기간 내에 확답을 발송하지 아니한 경우에는 그 행위를 추인한 것으로 본다.
- ③ 특별한 절차가 필요한 행위는 그 정하여진 기간 내에 그 절차를 밟은 확답을 발송하지 아니하면 취소한 것으로 본다.

구분	내용
의 의	① 형성권의 일종이다. ② 제한능력자 측에 취소 또는 추인 여부를 촉구하고 기간 내에 확답이 없을 때에는 취소 또는 추인의 효과가 발생한다.
요 건	상대방은 제한능력자 측에 대하여 1월 이상의 유예기간을 정하여 추인 여부의 확답을 최고할 수 있다.
상대방	법정대리인 또는 제한능력자이었던 본인이 그 상대방이 된다.
효 과	기간 내에 확답을 발신하지 않은 때 ① 보통의 경우(법정대리인이 단독으로 추인할 수 있는 경우) : 추인으로 간주한다. ② 특별한 절차를 요하는 경우 : 취소로 간주한다.

2. 제한능력자의 상대방의 철회권과 거절권

제16조 【제한능력자의 상대방의 철회권과 거절권】

- ① 제한능력자가 맺은 계약은 추인이 있을 때까지 상대방이 그 의사표시를 철회할 수 있다.
다만, 상대방이 계약 당시에 제한능력자임을 알았을 경우에는 그러하지 아니하다.
- ② 제한능력자의 단독행위는 추인이 있을 때까지 상대방이 거절할 수 있다.
- ③ 제1항의 철회나 제2항의 거절의 의사표시는 제한능력자에게도 할 수 있다.

- ① 선의의 상대방은 제한능력과 체결한 계약에 대하여 제한능력자 측의 추인이 있기 전까지는 그 의사표시를 철회할 수 있다(제16조 제1항).
- ② 제한능력자의 단독행위에 대해 제한능력자 측에서 추인하기 전까지는 상대방은 거절할 수 있다(제16조 제2항). 철회권과 달리 거절권은 상대방의 선의·악의를 불문한다.
- ③ 철회나 거절의 의사표시는 법정대리인뿐만 아니라 제한능력자에 대하여도 할 수 있다.

3. 취소권의 배제

제17조 【제한능력자의 속임수(사술)】

- ① 제한능력자가 속임수로써 자기를 능력자로 믿게 한 경우에는 그 행위를 취소할 수 없다.
- ② 미성년자나 피한정후견인이 속임수로써 법정대리인의 동의가 있는 것으로 믿게 한 경우에도 제1항과 같다.
- ① 미성년자나 피한정후견인이 속임수로써 법정대리인의 동의가 있는 것으로 믿게 한 경우에도 그 행위를 취소할 수 없다.
- ② 속임수(사술)의 정도에 대하여 판례는 적극적 사술(동의를 위조 등)만이 사술에 해당한다고 한다.

제6절 주소

1. 입법주의

우리 민법이 인정하는 입법주의는 실질주의(생활의 실질관계를 중시하여 구체적으로 결정)와 복수주의(주소는 동시에 두 곳 이상 둘 수 있다.)이며, 민법에 명문규정은 없으나 객관주의(정주(定住)의 사실만으로 주소를 결정)를 취하는 것이 통설이다.

2. 주소와 비슷한 개념

- (1) 거소 : 주소를 알 수 없을 때와 국내에 주소가 없는 자에 대해서는 거소를 주소로 본다(제19조·제20조).
- (2) 현재지 : 장소와의 밀접도가 거소보다 못한 곳(ex. 여행자가 일시 체재하는 장소)을 말한다.
- (3) 거주소 : 어떤 거래에 관하여 당사자가 일정한 장소를 정하여 주소로 정한 때 그 장소를 말한다(제21조).

제7절 부재자의 재산관리

1. 부재자 자신이 재산관리인을 정한 경우

지 위	부재자의 수임인이며 임의대리인이다.
권 한	① 부재자와 재산관리인의 계약에 의한다. ② 재산관리인의 권한이 분명치 않을 때에는 제118조를 적용한다.
법원의 개입	- 원칙 : 법원은 개입하지 않는다. - 개입 ① 본인의 부재 중에 관리인의 권한이 소멸한 때 ② 부재자의 생사가 불명하게 된 경우 (가정법원은 재산관리인·이해관계인·검사의 청구에 의해 관리인을 개임하거나 감독을 행함)

2. 부재자 자신이 재산관리인을 정하지 않은 경우

(1) 법원의 처분

- ① 법원은 이해관계인 또는 검사의 청구에 의하여 재산관리에 관하여 필요한 처분을 명한다.
- ② 필요한 처분이란 재산관리인의 선임 등이다.
- ③ 이해관계인이란 법률상의 이해관계인을 말하는 것으로 상속인, 배우자, 채권자, 보증인 등을 말하며 사실상의 이해관계를 가진 자, 즉 사실혼의 배우자나 친구 등은 이에 해당하지 아니한다.
- ④ 선임된 재산관리인은 언제든지 사임할 수 있고, 법원도 언제든지 개임할 수 있다.

(2) 재산관리인의 권리와 의무

지 위	일종의 법정대리인이다.
권 리	보수청구권을 가진다(제26조 제2항).
권 한	① 관리행위(보존·이용·개량행위)는 가능하다(제118조). ② 처분행위(매각·담보설정행위)는 법원의 허가를 요하며 또한 부재자를 위한 경우에 가능하다(판례).
의 무	선량한 관리자의 주의의무로 재산을 관리하여야 한다(제681조).

제8절 실종선고

1. 의 의

부재자의 생사불명의 상태가 장기간 계속된 경우에 일정한 조건하에 법원이 실종선고를 하고 일정한 기간(실종기간)의 경과에 의해서 사망으로 간주하는 제도이다.

2. 요 건

- (1) 부재자의 생사가 불명할 것
- (2) 일정한 실종기간이 경과할 것

보통실종 (제27조 제1항)	최후의 소식이 있는 때로부터 기산한다(통설).		5년
특별실종 (제27조 제2항)	전쟁실종	전쟁이 종지한 때(항복·휴전선언)	1년
	선박실종	선박이 침몰한 때	1년
	항공기실종	항공기가 추락한 때	1년
	위난실종	위난이 종료한 때(지진·화재·홍수 등)	1년

- (3) 이해관계인(배우자, 상속인, 채권자, 법정대리인, 재산관리인 등) 또는 검사의 청구가 있을 것
(제27조 제1항·제2항), 사실상의 이해관계인(사실혼 배우자, 친구 등)은 해당되지 않는다.

- (4) 공시최고를 행할 것

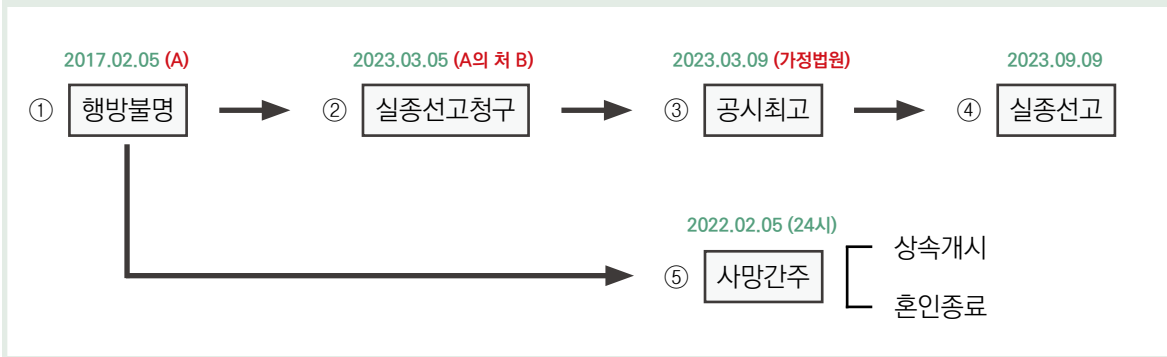
- ① 6월 이상의 기간을 정하여 공시최고를 행한다.
- ② 공시최고기간의 경과 후 실종선고를 한다.

이상의 요건이 갖추어진 경우에는 법원은 반드시 실종선고를 하여야 한다.

3. 효 과

- (1) 실종기간 만료시에 사망한 것으로 간주한다(제28조). 따라서 상속이 개시되고 잔존배우자와의 사이에 혼인관계가 종료한다. 간주주의(의제주의)를 취하므로 실종선고가 취소되지 않는 한 생존 등의 반증이 제기되더라도 선고의 효력을 부정할 수 없다.
- (2) 실종자의 종래의 주소를 중심으로 하는 사법적 법률관계(상속·혼인의 종료 등)만을 종료하게 한다.
따라서 공법관계(선거권·피선거권·납세의무·범죄능력 등)에는 선고의 효과가 미치지 아니한다.
- (3) 생활 후의 법률관계나 신주소지에서의 법률관계에는 선고의 효과가 미치지 아니한다.
실종선고제도는 실종자의 권리능력 자체를 박탈하는 제도가 아니다.

◎ 실종선고와 효과



4. 실종선고의 취소

(1) 절차

- ① 본인·이해관계인·검사의 실종선고취소청구가 있어야 한다(제29조 제1항).
- ② 실종선고절차와 달리 공시최고는 요하지 아니한다.

(2) 효과

① 원칙

실종선고로 인하여 생긴 법률관계는 소급적으로 무효가 된다.

② 예외

- ㉠ 실종선고로 직접 재산을 취득한 자의 반환의무
 - ㉡ 선의자는 그 받은 이익이 현존하는 한도에서 반환의무가 있다.
 - ㉢ 악의자는 그 받은 이익에 이자를 붙여 반환하여야 하고, 손해가 있으면 그것을 배상하여야 한다.
- ㉣ 실종선고 후 그 취소 전에 선의로 한 행위의 효력에는 영향을 미치지 아니한다.



핵심 판례 정리

01. 의사능력이란 자기 행위의 의미나 결과를 정상적인 인식력과 예기력을 바탕으로 합리적으로 판단할 수 있는 정신적 능력이나 지능을 말한다. 의사능력 유무는 구체적인 법률행위와 관련하여 개별적으로 판단해야 하고, 특히 어떤 법률행위가 일상적인 의미만을 이해해서는 알기 어려운 특별한 법률적 의미나 효과가 부여되어 있는 경우 의사능력이 인정되기 위해서는 그 행위의 일상적인 의미뿐만 아니라 법률적인 의미나 효과에 대해서도 이해할 수 있어야 한다.

02. 교통사고의 충격으로 태아가 조산(早産)되고 또 그로 인하여 제대로 성장하지 못하고 사망하였다면 위 불법행위는 한편으로 산모에 대한 불법행위인 동시에 한편으로는 태아 자신에 대한 불법행위라고 볼 수 있다.

- 03.** 태아가 특정한 권리에 있어서 이미 태어난 것으로 본다는 것은 살아서 출생한 때에 사건의 시기까지 소급하여 태아가 출생한 것과 같이 보아야 하므로 태아가 모체와 같이 사망하여 출생의 기회를 못 가진 이상 배상청구권이 인정되지 않는다.
- 04.** 부(父)가 교통사고로 상해를 입을 당시 태아가 출생하지 아니하였다고 하더라도 그 뒤에 출생한 이상父의 부상으로 인하여 입게 될 정신적 고통에 대한 위자료를 청구할 수 있다.
- 05.** 미성년자가 토지매매를 부인하는 경우에는 미성년자가 그 법정대리인의 동의를 얻었다는 점에 관한 증명책임은 미성년자의 상대방에게 있다.
- 06.** 미성년자가 법률행위를 함에 있어서 요구되는 법정대리인의 동의는 언제나 명시적이어야 하는 것은 아니고 묵시적으로도 가능하다.
- 07.** 만 18세가 넘은 미성년자가 월 소득범위 내에서 신용구매계약을 체결한 사안에서, 스스로 얻고 있던 소득에 대하여는 법정대리인의 묵시적 처분허락이 있었다고 보아 위 신용구매계약은 처분허락을 받은 재산범위 내의 처분행위에 해당한다.
- 08.** ‘제한능력이자 사술로써 능력자로 믿게 한 때’에 있어서의 사술을 쓴 것이라 함은 적극적으로 사기수단을 쓴 것을 말하는 것이고 단순히 자기가 능력자라 사언(詐言)함은 사술을 쓴 것이라고 할 수 없다.
- 09.** 부재자재산처분에 있어서는 민법 제25조에 따른 권한초과행위에 대한 허가를 받아야 하며 그 허가를 받지 아니하고 한 부재자의 재산매각은 무효이다.
- 10.** 재산관리인에 의한 부재자 소유의 부동산 매매에 대한 법원의 허가결정은 그 허가를 받은 재산에 대한 장래의 처분행위뿐만 아니라 과거의 처분행위(기왕의 매매)를 추인하는 방법으로도 할 수 있다.
- 11.** 부재자 재산관리인으로서 권한초과행위의 허가를 받고 그 선임결정이 취소되기 전에 위 권한에 의하여 이루어진 행위는 부재자에 대한 실종선고기간이 만료된 뒤에 이루어졌다고 하더라도 유효하다.
- 12.** 법원이 선임한 부재자의 재산관리인은 그 부재자의 사망이 확인된 후라 할지라도 위 선임결정이 취소되지 않는 한 그 관리인으로서의 권한이 소멸되는 것은 아니다.
- [판례해설]** 부재자 재산관리인의 선임결정이 취소되었다 하더라도 그 취소는 소급효가 없으며, 따라서 이미 한 처분행위는 그대로 유효하다.

- 13.** 부재자 재산관리인이 법원의 매각처분허가를 얻었다 하더라도 부재자와 아무런 관계가 없는 남의 채무의 담보만을 위하여 부재자 재산에 근저당권을 설정하는 행위는 부재자를 위한 처분행위로 볼 수 없다.
[판례해설] 법원의 매각처분허가를 얻었다 하더라도, 그것은 부재자의 이익을 위하여 처분되어야 하는 것을 전제로 한다.
- 14.** 부재자로부터 재산처분권까지 위임받은 재산관리인은 그 재산을 처분함에 있어 법원의 허가를 요하는 것은 아니다.
[판례해설] 부재자 자신이 재산관리인을 둔 경우, 이는 부재자의 수임인이며 임의대리인이므로 부재자와 재산관리인 사이의 계약에 의하여 정하여진다.
- 15.** 실종선고를 청구할 수 있는 이해관계인이라 함은 법률상뿐만 아니라 경제적 또는 신분적 이해관계인이어야 할 것이므로 부재자의 제1순위 재산상속인이 있는 경우에 제2순위의 재산상속인은 위 부재자에 대한 실종선고를 청구할 이해관계인이 될 수 없다.
- 16.** 실종선고의 효력이 발생하기 전에는 실종기간이 만료된 실종자라 하여도 소송상 당사자능력을 상실하는 것은 아니므로 실종선고 확정 전에는 실종기간이 만료된 실종자를 상대로 하여 제기된 소도 적법하고 실종자를 당사자로 하여 선고된 판결도 유효하다.
- 17.** 실종선고에 의한 사망의 효과를 저지하려면 반증으로서는 안 되고, 실종선고의 취소가 있어야 한다.



중요 지문 정리

01. 자연인은 출생으로 권리능력을 취득하지만 예외적으로 태아가 살아서 출생하지 못한 경우에도 권리능력을 가지는 경우가 있다. ()

태아의 개별적 보호주의에 다른 권리능력은 태아가 살아서 출생한다는 것을 전제로 인정되는 것이므로, 태아가 사산(유산)된 경우에는 권리능력을 인정할 여지가 없다. (×)

02. 태아는 채무불이행에 기한 손해배상의 청구권에 관하여는 이미 출생한 것으로 본다. ()

불법행위로 인한 손해에 대하여 배상청구를 하는 경우 출생한 것으로 본다. (×)

03. 태아는 모든 법률관계에서 자연인과 동일한 권리능력을 갖는다. ()

우리 민법은 태아의 경우 모든 법률관계가 아니라 개별적 법률관계에서만 출생한 것으로 보는 입법주의인 개별적 보호주의를 취하고 있다. (×)

04. 의사능력은 자신의 행위의 의미와 결과를 합리적으로 판단할 수 있는 정신적 능력으로 구체적인 법률행위와 관련하여 개별적으로 판단되어야 한다. ()

타당한 기술이다. (○)

05. 행위능력은 독자적으로 완전하고 유효한 법률행위를 할 수 있는 자격 또는 능력을 말한다. ()

06. 미성년자가 유효한 법률행위를 하려면 원칙적으로 법정대리인의 동의를 얻어야 하며, 법정대리인의 동의를 얻지 않은 미성년자의 법률행위는 법정대리인만이 취소할 수 있다. ()

07. 단순히 권리만을 얻거나 의무만을 면하는 행위는 법정대리인의 동의 없이도 미성년자가 단독으로 할 수 있다. ()

08. 미성년자가 월 소득범위 내에서 신용구매계약을 체결한 경우라도 법정대리인의 명시적인 동의가 없는 경우라면 제한행위능력을 이유로 그 법률행위를 취소할 수 있다. ()

09. 미성년자가 토지매매행위를 부인하고 있는 이상, 미성년자가 그 법정대리인의 동의를 얻었다는 점에 관한 증명책임은 미성년자에게 없고 이를 주장하는 상대방에게 있다. ()

10. 미성년자의 근로계약체결은 법률행위이므로 법정대리인이 근로계약체결을 대리하여야 한다. ()

11. 미성년자는 대리행위, 유언행위(만 17세 이상), 임금청구, 법정대리인이 범위를 정하여 처분을 허락한 재산의 처분행위, 법정대리인으로부터 허락을 얻은 특정한 영업에 관한 행위에 관하여 법정대리인의 동의 없이 단독으로 유효한 법률행위를 할 수 있다. ()

12. 법정대리인의 동의 없이 신용구매계약을 체결한 미성년자가 사후에 법정대리인의 동의 없음을 사유로 들어 이를 취소하는 것이 신의칙에 위배된 것이라고 할 수 없다. ()

13. 법정대리인이 범위를 정하여 처분을 허락한 재산은 미성년자가 임의로 처분할 수 있으나, 미성년자가 아직 법률행위를 하기 전이라면 법정대리인은 위 허락을 취소할 수 있다. ()

타당한 기술이다. (○)

미성년자가 법정대리인의 동의를 얻지 않고 한 법률행위는 본인(미성년자) 또는 그 법정대리인이 취소할 수 있다. (×)

타당한 기술이다 (○)

미성년자가 월 소득범위 내에서 신용구매계약을 체결한 사안에서, 스스로 얻고 있던 소득에 대하여는 법정대리인의 묵시적 처분허락이 있었다고 보아 위 신용구매계약은 처분허락을 받은 재산범위 내의 처분행위에 해당한다(대법원 2007.11.16. 2005다71659) (×)

타당한 기술이다(대법원 1970.02.24. 69다1568) (○)

근로계약의 체결과 임금의 청구는 미성년자가 단독으로 할 수 있고(근로기준법 제67조·제68조), 임금의 청구에 대하여는 법정대리인의 대리권이 제한된다. (×)

타당한 기술이다 (○)

법정대리인의 동의 없이 신용구매계약을 체결한 미성년자가 사후에 법정대리인의 동의 없음을 사유로 들어 이를 취소하는 것은 신의칙에 반하지 않는다(대법원 2007.11.16. 2005다71659). (○)

타당한 기술이다. (○)

14. 가정법원은 질병, 장애, 노령, 그 밖의 사유로 인한 정신적 제약으로 사무를 처리할 능력이 지속적으로 결여된 사람에 대하여 한정후견개시의 심판을 한다. ()

가정법원은 질병, 장애, 노령, 그 밖의 사유로 인한 정신적 제약으로 사무를 처리할 능력이 부족한 사람에 대하여 한정후견개시의 심판을 한다 (제12조 제1항). (×)

15. 한정후견인의 동이가 필요한 행위에 대하여 피한정후견인의 이익이 침해될 염려가 있음에도 한정후견인이 동의를 하지 아니하는 때에는 가정법원은 피한정후견인의 청구에 의하여 한정후견인의 동의를 갈음하는 허가를 할 수 있다. ()

타당한 기술이다(제13조 제3항). (○)

16. 가정법원은 성년후견개시 심판을 하면서 피성년후견인의 행위 중 취소할 수 없는 법률행위의 범위를 정할 수 있다. ()

가정법원은 취소할 수 없는 피성년후견인의 법률행위의 범위를 정할 수 있다(제10조 제2항). (○)

17. 가정법원이 질병, 장애, 노령 등으로 인한 정신적 제약으로 사무를 처리할 능력이 지속적으로 결여된 사람에 대하여 본인, 배우자, 검사 등의 청구에 의하여 성년후견개시의 심판을 할 때 본인의 의사를 고려하여야 한다. ()

가정법원은 성년후견개시의 심판을 할 때 본인의 의사를 고려하여야 한다(제9조 제2항). (○)

18. 가정법원은 성년후견개시의 경우와는 달리 한정후견개시의 심판을 할 때에는 본인의 의사를 고려하지 않을 수도 있다. ()

가정법원은 성년후견개시의 심판을 할 때 본인의 의사를 고려하여야 한다(제9조 제2항). 한정후견개시의 경우에 제9조 제2항을 준용한다(제12조 제2항). 따라서 가정법원은 성년후견개시의 경우뿐만 아니라 한정후견개시의 심판을 할 때에도 본인의 의사를 고려하여야 한다. (×)

19. 일용품의 구입 등 일상생활에 필요하고 그 대가가 과도하지 아니한 법률행위는 성년후견인이 취소할 수 없고, 가정법원은 위 일상적 법률행위의 범위를 미리 정하여야 한다. ()

가정법원은 취소할 수 없는 피성년후견인의 법률행위의 범위를 정할 수 있으나, 일상적 법률행위의 범위를 미리 정하여야 한다는 명문은 없다(제10조 제2항). (×)

20. 가정법원이 피한정후견인 또는 피특정후견인에 대하여 성년후견개시의 심판을 한 때에는 종전의 한정후견 또는 특정후견은 별도의 심판 없이 종료한다. ()

가정법원이 피한정후견인 또는 피특정후견인에 대하여 성년후견개시의 심판을 할 때에는 종전의 한정후견 또는 특정후견의 종료 심판을 한다. (×)

21. 제한능력자의 단독행위는 추인이 있을 때까지 상대방이 거절할 수 있으나, 상대방이 그 단독행위 당시에 제한능력자임을 알았을 경우에는 거절할 수 없다. ()

제한능력자의 단독행위는 추인이 있을 때까지 상대방이 거절할 수 있으며, 이 때 상대방의 거절권은 악의인 경우에도 인정된다. (×)

22. 미성년자가 속임수(사술)로써 법정대리인의 동의가 있는 것으로 믿게 한 경우에는 그 행위를 취소하지 못한다. ()

타당한 기술이다. (○)

23. 상대방은 제한능력자 측에서 추인하기 전까지 그의 의사표시를 철회할 수 있지만, 제한능력자에 대하여는 능력자로 된 경우에만 철회의 의사표시를 할 수 있다. ()

거절권과 철회권은 제한능력자에게도 행사할 수 있다(제16조 제3항). (×)

24. 미성년자와 부동산매매계약을 체결한 자가 미성년자의 친권자에게 1개월 이상의 기간을 정하여 그 취소할 수 있는 행위에 대한 추인 여부의 응답을 촉구하였으나 친권자가 그 기간 내에 응답을 발송하지 않은 때에는 추인을 거절한 것으로 본다. ()

제한능력자가 아직 능력이 되지 못한 경우에는 그의 법정대리인에게 1개월 이상의 기간을 정하여 그 취소할 수 있는 행위를 추인할 것인지 여부의 응답을 촉구할 수 있고, 법정대리인이 그 정하여진 기간 내에 응답을 발송하지 아니한 경우에는 그 행위를 추인한 것으로 본다(제15조 제2항). (×)

25. 주소는 동시에 두 곳 이상 있을 수 있고, 국내에 주소가 없는 자에 대하여는 국내에 있는 거소를 주소로 본다. ()

타당한 기술이다(제18조, 제19조). (○)

26. 부재자가 사망한 사실이 확인되면 부재자 재산관리인 선임결정이 취소되지 않더라도 관리인의 권한은 당연히 소멸한다. ()

법원이 선임한 부재자의 재산관리인은 그 부재자의 사망이 확인된 후라 하더라도 그 선임결정이 취소되지 않는 한 그 관리인으로서의 권한이 소멸되는 것은 아니다(대법원 1971.03.23. 71다189). (×)

27. 부재자가 위임계약을 통하여 자신의 재산관리인을 선임하였으나 그의 생사가 불분명해진 경우에는 법원은 재산관리인, 이해관계인 또는 검사의 청구에 의하여 재산관리인을 개임할 수 있다. ()

부재자란 종래의 주소나 거소를 떠나서 당분간 돌아올 가망성이 없어서 그의 재산이 관리되지 못하고 있는 상태에 있는 자인데, 부재자가 재산관리인을 정한 경우에 부재자의 생사가 분명하지 아니한 때에는 법원은 예외적으로 재산관리인, 이해관계인 또는 검사의 청구에 의하여 재산관리인을 개임할 수 있다(제23조). (○)

28. 부재자의 1순위 상속인이 따로 있는 경우 제2순위 내지 3순위 상속인은 특별한 사정이 없는 한 실종선고를 청구할 수 있는 이해관계인에 해당하지 않는다. ()

부재자의 제1순위 재산상속인이 있는 경우에 제2순위의 재산상속인은 부재자에 대한 실종선고를 청구할 이해관계인이 될 수 없다(대법원 1980.09.08. 80스27). (○)

29. 실종선고를 받은 자가 실종기간 동안 생존했던 사실이 확인된 경우, 실종선고의 취소 없이도 이미 개시된 상속은 부정된다. ()

실종선고에 의한 사망의 효과를 번복하려면 반증으로서는 안 되고, 그 선고의 취소가 있어야 한다(대법원 1995.2.17. 94다52751). (×)

30. 실종선고가 취소되더라도 실종기간 만료 후 실종선고 취소 전에 선의로 한 행위의 효력에는 영향을 미치지 아니한다. ()

실종선고가 취소되더라도 '실종선고 후 그 취소 전'에 선의로 한 행위의 효력에는 영향을 미치지 아니한다. 선의란 실종선고가 사실과 다르다는 사실을 알지 못하는 것을 말한다. (×)

31. 실종선고의 청구권자와 실종선고 취소의 청구권자는 동일하다. ()

실종선고의 청구권자는 이해관계인이나 검사이나, 실종선고 취소의 청구권자는 본인·이해관계인 또는 검사이다. (×)

32. 잠수장비를 착용하고 바다에 입수하여 부상하지 아니한 채 행방불명되었다면 1년의 특별실종기간이 진행된다. ()

잠수장비를 착용한 채 바다에 입수하였다가 부상하지 아니한 채 행방불명되었다 하더라도, 이는「사망의 원인이 될 위난」이라고 할 수 없다(대법원 2011.1.31. 2010스165), 따라서 특별실종(위난실종)이 아니라 보통실종이다. (×)

33. 실종선고를 직접원인으로 하여 재산권을 취득한 자가 실종선고취소의 결과 이득을 반환해야 할 경우, 그 반환범위는 이득자의 선·악에 관계없이 그 받은 이익이 현존하는 한도이다. ()

실종선고의 취소가 있을 때 실종의 선고를 직접원인으로 하여 재산을 취득한 자가 선의인 경우에는 그 받은 이익이 현존하는 한도에서 반환할 의무가 있고 악의인 경우에는 그 받은 이익에 이자를 붙여서 반환하고 손해가 있으면 이를 배상하여야 한다(제29조 제2항). (×)

34. 부재자재산관리인의 권한초과행위에 대한 법원의 허가는 과거의 처분행위를 추인하는 방법으로도 할 수 있다. ()

부재자 재산관리인에 의한 부재자 소유의 부동산 매매행위에 대한 법원의 허가결정은 그 허가를 받은 재산에 대한 장래의 처분행위뿐만 아니라 과거의 처분행위(기왕의 매매)에 대한 추인으로도 할 수 있다(대법원 2000.12.26. 99다19278). (○)

◎ 단원별 출제경향

구 분	28회	29회	30회	31회	32회	33회	34회
권리의 주체(법인)	2	3	2	2	3	3	3

제1절 사단법인과 재단법인의 비교

설 립 행 위	정관의 필요적 기 재 사 항	① 목 적 ② 명 칭 ③ 사무소의 소재지 ④ 자산에 관한 규정 ⑤ 이사의 임면에 관한 규정 ⑥ 사원자격 득실에 관한 규정 ⑦ 존립시기나 해산사유를 정하는 경우 시기 또는 사유	① ~ ⑤
정 관 변 경	요 건	① 사원총회의 결의 : 원칙적으로 총사원의 3분의 2 이상의 동의 ② 주무관청의 허가를 받아야 효력발생	원칙적으로 변경이 불가하나 다음의 경우에 가능 ① 설립자가 정관에서 그 변경방법을 정하고 있는 경우 ② 명칭·사무소의 소재지 변경 ③ 목적달성이 불가능한 경우 주무관청의 허가를 얻어 정관변경 ④ 주무관청의 허가를 받아야 효력발생
해 산 사 유	공 통	① 존립시기의 만료 기타 정관에서 정한 해산사유의 발생 ② 법인의 목적달성 또는 달성불능 ③ 파 산 ④ 설립허가의 취소	
	사 단 법 인 특 수	① 사원이 없게 된 때 ② 총회의 해산결의(임의해산 : 총사원의 4분의 3 이상의 동의)	

제2절 권리능력없는 사단과 재단

구분	권리능력 없는 사단	권리능력 없는 재단
의 의	사단으로서의 실체를 가지나 주무관청의 허가나 설립등기를 하지 않아 법인격이 없는 단체를 말한다. ex) 종중, 문중, 교회 등	재단으로서의 실체를 가지나 주무관청의 허가나 설립등기를 하지 않아 법인격이 없는 단체를 말한다. ex) 재단저당의 목적재산, 상속인 없는 상속재산
내부 관계	① 비영리사단법인의 규정을 유추적용 ② 재산소유형태는 총유(부채도 총유적으로 귀속한다. 따라서 개인 재산에는 그 영향을 미치지 않는 유한책임)	① 재단법인에 관한 규정을 유추적용 ② 재산소유형태는 재단의 단독소유
외부 관계	① 대표자가 있을 때 민사소송법상 당사자능력을 인정 ② 부동산등기능력을 인정 ③ 단체에 불법행위능력을 인정	左同

제3절 재단법인의 출연재산의 귀속시기

1. 민법의 규정

- (1) 출연재산의 종류는 불문하며 출연재산의 귀속시기에 대한 민법의 규정은
생전행위(증여의 규정을 준용)인 경우에는 법인의 설립등기시에 귀속(제48조 제1항)하며,
(2) 유언(유증의 규정을 준용)인 경우에는 유언자의 사망시에 귀속(제48조 제2항)한다고 규정하고 있다.

2. 출연재산(소유권) 귀속시기에 대한 학설의 대립과 판례

- ① 법률의 규정에 의한 물권변동으로 보아 등기나 인도를 요하지 않고 당연히 설립등기시 또는 유언의 효력발생시에 법인에 귀속한다(다수설).
- ② 인도청구권만이 법인설립시 또는 유언효력발생시에 법인에 귀속하고 현실적으로 재산권이 법인에 귀속되는 것은 일정한 형식(등기 또는 인도)을 갖춘 때이다(소수설).
- ③ 출연자와 법인 사이에서는 다수설의 입장을 따르나 법인이 제3자에게 대항하기 위해서는 일정한 형식(등기 또는 인도)을 갖추어야 한다는 입장을 취한다(판례).

제4절 법인의 능력

법인도 권리의 주체로서 권리능력·행위능력 및 불법행위능력이 있다. 다만, 민법은 권리능력(제34조)과 불법행위능력(제35조)에 관한 규정만을 두고 있으며, 행위능력에 대하여는 명문이 없다.

1. 법인의 권리능력

법인의 권리능력은 법률의 규정과 정관으로 정한 목적에 의하여 제한된다(제34조).
그 외에도 자연인과 다른 성질상의 제한이 있다.

2. 법인의 행위능력

목적범위 내에서 활동하며 법인의 행위능력의 범위는 권리능력의 범위와 같다.
따라서 그 권리능력의 범위 내에서 모든 행위를 할 수 있다.

(1) 이사, 임시이사, 특별대리인, 청산인 등의 행위는 곧 법인의 행위로 본다.

(2) 대표행위의 방식에 관해서는 대리의 규정을 준용한다(제59조 제2항).
따라서 현명주의(顯名主義), 표현대리에 관한 규정을 준용한다.

(3) 법인의 대표기관의 대표권을 제한하는 경우에는 이를 등기하여야 하고
대표권제한을 등기하지 않은 경우에는 선의·악의를 불문하고 제3자에게 대항할 수 없다(판례).

3. 법인의 불법행위능력

법인은 대표기관이 그 직무에 관하여 타인에게 가한 손해를 배상할 책임이 있다고 규정(제35조 제1항)함으로써 법인의 불법행위능력을 인정한다.

성립요건

(1) 대표기관의 행위

- ① 이사, 임시이사, 특별대리인, 청산인, 직무대행자의 행위이어야 한다.
- ② 사원총회, 감사, 이사의 임의대리인 등은 대표기관이 아니므로 법인의 불법행위는 성립될 수 없다.
단, 사용자배상책임은 성립할 수 있다.

(2) 대표기관의 직무에 관한 행위

- ① 외형상 직무행위로 볼 수 있는 행위와 직무행위와 사회통념상 견련성을 가지는 행위도 포함한다는 것이 판례의 태도이다.
- ② 대표기관이 개인적인 목적으로 권한을 남용하여 부정한 대표행위를 행한 경우에도 법인의 직무에 관한 행위로 보아 법인의 불법행위책임을 인정한다(판례).

(3) 민법 제750조의 불법행위의 요건 구비



불법행위의 효과

- ① 법인은 대표자의 선임·감독상의 과실 없음을 가지고 항변하지 못한다(무과실책임).
- ② 피해자는 그가 받은 손해의 충분한 전보(填補)를 받을 때까지 법인이나 대표기관에 대하여 동시에 또는 선택적으로 손해배상청구를 할 수 있다(부진정연대채무).
- ③ 법인이 배상한 경우에는 기관 개인에 대하여 선량한 관리자의 주의의무(제61조)의 위반을 이유로 구상권을 행사할 수 있다(제65조).
- ④ 법인의 불법행위가 성립하지 않는 경우에는 기관 개인만이 제750조에 의한 불법행위의 책임을 진다. 다만 민법은 피해자보호를 위하여 그 사항의 의결에 찬성한 사원과 이사 그리고 그것을 집행한 이사, 기타 대표기관은 언제나 연대하여 손해배상책임을 진다(제35조 제2항).

제5절 법인의 기관

01 이사와 감사

기관	성격	임무
이사	① 사단·재단법인에 공통한 기관이다. ② 필수기관이다(제57조).	① 대외적으로 법인을 대표하고 대내적으로 법인의 업무를 집행한다(제58조, 제59조). ② 선량한 관리자의 주의의무로서 사무집행을 하여야 한다. ③ 이사의 성명·주소는 등기사항이며 등기하지 않으면 이사의 선임·해임·퇴임을 가지고 제3자에게 대항할 수 없다(대항요건). ④ 각자 법인을 대표하며 대표의 방식은 대리의 규정을 준용한다(제59조 제2항). ⑤ 정관에 다른 규정이 없으면 법인의 사무집행은 이사의 과반수로서 결정한다(제58조 제2항).
감사	① 사단·재단법인에 공통한 기관이다. ② 임의기관이다(제6조).	① 법인의 재산 및 사무상태를 감독한다(제67조). ② 선관주의의무를 지며 각자 단독으로 업무를 집행한다.
사원 총회	사단법인에만 존재한다.	① 사단법인의 최고 의사결정기관이다(제68조). ② 통상총회와 임시총회가 있다.

구분	선임하여야 할 경우	선임기관
임시이사	이사가 없거나 결원이 된 때에 이해관계인이나 감사의 청구로 선임한다(제63조).	법 원
특별대리인	법인과 이사의 이익이 상반될 때에 다른 이사가 없는 경우에 이해관계인 또는 감사의 청구로 선임한다(제64조).	법 원

제6절 법인의 소멸

1. 법인의 청산

청산절차에 관한 규정은 강행규정이다.

청산인이 될 수 있는 자는 정관 또는 총회의 결의로 정한 바가 없으면 이사가 청산인이 된다.

2. 청산인의 청산사무

(1) 채무의 변제(제87조 제1항)

- ① 청산인은 채권신고기간 내에는 채권자에 대하여 변제하지 못한다.
- ② 청산기간 내에는 변제기에 이르지 않은 채권에 대하여도 변제할 수 있으며(제91조), 청산인이 알고 있는 채권자는 신고가 없더라도 변제하여야 한다.

(2) 잔여재산의 인도(제80조): 잔여재산의 귀속순서

- ① 정관에서 정한 자가 있을 때에는 그 자에게
- ② 지정한 자가 없는 경우에는 유사목적법인에게 귀속시키며
(사단법인의 경우에는 총회의 결의절차를 요한다)
- ③ 최종적으로는 국고에 귀속시킨다.

제7절 법인의 등기

1. 등기의 성질

법인등기 중에서 설립등기는 성립요건(제33조)으로서의 등기이나

기타의 등기는 모두 제3자에게 대항하기 위한 대항요건(제54조 제1항)으로서의 등기이다.

2. 설립등기

법인의 설립등기사항은 다음과 같다(제49조 제2항).

- ① 목 적
- ② 명 칭
- ③ 사무소
- ④ 설립허가의 연월일
- ⑤ 존립시기와 해산사유를 정한 때에는 그 시기 또는 사유
- ⑥ 자산의 총액
- ⑦ 출자의 방법을 정한 때에는 그 방법
- ⑧ 이사의 성명, 주소
- ⑨ 이사의 대표권을 제한한 때에는 그 제한

제8절 법인의 감독

법인의 업무감독은 주무관청이 하고(제37조), 법인의 해산·청산의 감독은 법원이 행한다(제95조).

주무관청과 법원의 법인에 관한 권한사항	
주 무 관 청	법 원
① 비영리법인의 설립허가(제32조) ② 법인의 사무에 대한 검사·감독(제37조) ③ 법인의 설립허가의 취소(제38조) ④ 정관변경의 허가(제42·45·46조) ⑤ 청산인의 해산신고(제86조) ⑥ 청산인의 청산종결의 신고(제94조)	① 임시이사의 선임(제63조) ② 특별대리인의 선임(제64조) ③ 청산인의 선임·해임(제83·84조) ④ 해산·청산의 검사·감독(제95조) ⑤ 법인의 파산선고(파산법 제115조 이하)



핵심 판례 정리

- 01.** 소집절차에 하자가 있어 그 효력을 인정할 수 없는 중중총회의 결의라도 후에 적법하게 소집된 중중총회에서 이를 추인하면 처음부터 유효로 된다.
- 02.** 법인의 목적달성이 불능하게 되었다는 것으로는 법인의 해산사유에 해당될지 몰라도 그 사유만으로 설립허가를 취소할 사유에 해당된다 할 수 없다.

[판례해설] 법인의 설립허가의 취소사유

- ① 허가조건의 위배
- ② 목적이외의 사업(영리추구)
- ③ 공익저해행위

03. 법인 아닌 사단에 대하여는 사단법인에 관한 민법규정 가운데서 법인격을 전제로 하는 것을 제외하고는 이를 유추적용하여야 할 것인 바, 사단법인에 있어서는 사원이 없게 된다고 하더라도 이는 해산사유가 될 뿐 권리능력이 소멸하는 것은 아니다.

04. 법인 아닌 사단의 총회에서 회의 소집 통지에 목적 사항으로 기재하지 않은 사항에 관하여 결의한 때에는 구성원 전원이 회의에 참석하여 그 사항에 의하여 의결한 경우가 아닌 한 그 결의가 원칙적으로 무효이다.

05. 공동주택의 입주자대표회의는 단체로서의 조직을 갖추고 의사결정기관과 대표자가 있을 뿐만 아니라, 또 현실적으로는 자치관리기구를 지휘, 감독하는 등 공동주택의 관리업무를 수행하고 있으므로 특별한 다른 사정이 없는 한 법인아닌 사단으로서 당사자능력이 있다.

06. 정관변경 “허가”는 법률상의 표현이 허가로 되어 있기는 하나, 그 성질에 있어 법률행위의 효력을 보충해 주는 것이지 일반적 금지를 해제하는 것이 아니므로, 그 법적 성격은 인가라고 보아야 한다.

07. 법인설립에서의 주무관청의 허가는 그 본질상 주무관청의 자유재량에 속하는 행위로서 그 허가여부는 다툴 수 없으므로 그에 대한 불허가처분은 행정소송의 대상이 되지 아니한다.

08. 사단법인의 정관은 이를 작성한 회원뿐만 아니라 그 후에 가입한 회원이나 사단법인의 기관 등도 구속하는 점에 비추어보면 그 법적 성질은 계약이 아니라 자치법규로 보는 것이 타당하다.

09. 출연재산이 부동산인 경우에 있어서도 위 양 당사자간의 관계에 있어서는 위 요건(법인의 성립) 외에 등기를 필요로 하는 것이 아니나, 제3자에 대한 관계에 있어서는 출연행위가 법률행위이므로 출연재산의 법인내의 귀속에는 부동산의 권리에 관해서는 법인성립외에 등기를 필요로 한다.

10. 재단법인의 출연자가 착오를 원인으로 출연을 한 경우에는 출연자는 재단법인의 성립 여부나 출연된 재산의 기본재산인 여부와 관계없이 그 의사표시를 취소할 수 있다.

11. 재단법인의 기본재산의 변경은 정관의 변경을 초래하기 때문에 주무관청의 허가를 받아야 하고, 따라서 기존의 기본재산을 처분하는 행위는 물론 새로이 기본재산으로 편입하는 행위도 주무관청의 허가가 있어야만 유효하다.

- 12.** 법인의 권리능력은 법인의 설립근거가 된 법률과 정관상의 목적에 의하여 제한되나 그 목적 범위 내의 행위라 함은 법률이나 정관에 명시된 목적 그 자체에 국한되는 것이 아니라 그 목적을 수행하는데 있어 직접, 간접으로 필요한 행위는 모두 포함된다.
- 13.** 행위의 외형상 법인의 대표자의 직무행위라고 인정할 수 있는 것이라면 설사 그것이 대표자 개인의 사리를 도모하기 위한 것이었거나 혹은 법령의 규정에 위배된 것이었다 하더라도 직무에 관한 행위로 보아 법인의 불법행위책임을 인정한다.
- 14.** 대표이사가 그 대표권의 범위 내에서 한 행위는 설사 대표이사가 회사의 영리목적과 관계없이 자기 또는 제3자의 이익을 도모할 목적으로 그 권한을 남용한 것이라 할지라도 일단 회사의 행위로서 유효하고, 다만 그 행위의 상대방이 대표이사의 진의를 알았거나 알 수 있었을 때에는 회사에 대하여 무효가 되는 것이다.
- [판례해설]** 대표기관이 대표권을 남용한 경우에 관하여 현재의 판례의 입장은 제107조 제1항 단서의 유추적용설에 입각하여, 상대방이 그 사실을 알았거나 알 수 있었을 때에는 법인에 대하여 무효가 된다고 한다.
- 15.** 법인의 대표자의 행위가 직무에 관한 행위에 해당하지 아니함을 피해자 자신이 알았거나 또는 중대한 과실로 인하여 알지 못한 경우에는 법인에게 손해배상책임을 물을 수 없다.
- 16.** 법인에 관한 등기사항의 변경이 있을 때 그 변경등기는 효력발생요건이 아니고 제3자에 대한 대항요건이다.
- 17.** 법인의 정관에 법인대표권의 제한에 관한 규정이 있으나 그와 같은 취지가 등기되어 있지 않다면 법인은 그와 같은 정관의 규정에 대하여 선의나 악의나에 관계없이 제3자에 대하여 대항할 수 없다.
- 18.** 사단법인의 대표자가 채무를 인수함에 있어 사원총회와 이사회 결의를 따로 거치도록 되어 있다면 이와 같은 총회나 이사회 결의는 법인대표권에 대한 제한으로서 이러한 제한은 등기하지 않으면 제3자에게 대항할 수 없다.
- 19.** 대표자의 임기만료 후에 개임하지 않았을 경우 그 유임 내지 중임을 금한 계약이 없는 한 임기만료와 동시에 묵시적으로 다시 대표자를 선출한 것으로 보아야 할 것이다.
- 20.** 대표기관의 고의적인 불법행위라 하더라도 법인자체의 불법행위책임을 묻고 있는 피해자들에게 그 불법행위 내지 손해발생에 과실이 있다면 법원은 과실상계의 법리에 좇아 손해배상의 책임 및 그 금액을 정함에 있어 이를 참작하여야 한다.

21. 사단법인의 사원의 지위는 양도 또는 상속할 수 없다고 규정한 민법 제56조의 규정은 강행규정이라고 할 수 없으므로, 비법인사단에서도 사원의 지위는 규약이나 관행에 의하여 양도 또는 상속될 수 있다.

[판례해설] 공익권이 강한 비영리법인의 경우에는 회원권을 양도 또는 상속할 수 없음이 원칙이나(일신전속권;제56조), 규약이나 관행에 의하여 예외적으로 양도 또는 상속될 수 있다.

22. 청산절차에 관한 규정은 모두 제3자의 이해관계에 중대한 영향을 미치기 때문에 이른바 강행규정이다.

23. 법인에 대한 청산종결등기가 경료된 때에도 청산사무가 종료되었다 할 수 없는 경우에는 청산법인으로 존속한다.

24. 대표자를 선임하기 위하여 개최되는 중종총회의 소집권을 가지는 연고항존자를 확정함에 있어서 여성을 제외할 아무런 이유가 없으므로, 여성을 포함한 전체 종원 중 항렬이 가장 높고 나이가 가장 많은 사람이 연고항존자가 된다.

중요 지문 정리

01. 영리재단법인이란 존재할 수 없다. ()

민법상의 재단법인은 언제나 비영리법인이다. (○)

02. 사단법인의 하부조직의 하나라 하더라도 스스로 단체로서의 실체를 갖추고 독자적인 활동을 하고 있다면 사단법인과는 별개의 독립된 비법인사단으로 볼 수 있다. ()

대법원 2009.1.30. 2006다60908 (○)

03. 법인 아닌 사단은 사단의 실질은 가지고 있으나 아직 권리능력을 취득하지 못한 것이므로, 법인 아닌 사단의 사원은 집합체로서 재산을 소유할 수 없고, 법인 아닌 사단은 대표자가 있더라도 그 사단의 이름으로 소송의 당사자가 될 수 없다. ()

법인이 아닌 사단의 사원이 집합체로서 물건을 소유할 때에는 총유로 하며, 법인이 아닌 사단이나 재단은 대표자 또는 관리인이 있는 경우에는 그 사단이나 재단의 이름으로 소송의 당사자가 될 수 있다. (×)

04. 대표자의 행위가 직무에 관한 행위에 해당하지 아니함을 피해자 자신이 알았거나 또는 과실로 인하여 알지 못한 경우에는 비법인사단에게 손해배상 책임을 물을 수 없다. ()

대표자의 행위가 직무에 관한 행위에 해당하지 아니함을 피해자 자신이 알았거나 또는 중대한 과실로 인하여 알지 못한 경우에는 비법인사단에게 손해배상책임을 물을 수 없다(대법원 2008.1.18. 2005다34711), (×)

05. 법인의 대표자로 등기되거나 대표자라는 명칭을 사용하지 않는 자라도 당해 법인을 실질적으로 운영하면서 사실상 법인을 대표하여 법인의 사무를 집행하는 자가 그 직무에 관하여 타인에게 손해를 가한 경우에는 그 법인이 손해배상책임을 부담하는데, 이런 법리는 비법인사단에도 동일하게 적용된다. ()

06. 적법한 대표자 자격이 없는 비법인사단의 대표자가 한 소송행위는 후에 대표자 자격을 적법하게 취득한 대표자가 그 소송행위를 추인하더라도 이를 유효하게 할 수는 없다. ()

07. 비법인사단에 해산사유가 발생하면 곧바로 당사자능력이 소멸하게 되고, 청산사무가 완료될 때까지 청산의 목적범위 내에서 권리·의무의 주체가 된다고 볼 수는 없다. ()

08. 법인 아닌 사단인 종중이 그 총유재산에 대한 보존행위로서 소송을 하는 경우에 특별한 사정이 없는 한 종중총회의 결의를 거쳐야 한다. ()

09. 법인 아닌 사단에 대하여는 사단법인에 관한 민법규정 가운데서 법인격을 전제로 하는 것을 제외하고는 이를 유추적용하여야 한다. ()

10. 권리능력 없는 사단은 부동산등기능력이 있어 그 소유 재산을 사단 명의로 등기할 수 있다. ()

11. 비법인사단인 종중의 토지에 대한 수용보상금은 종원의 총유에 속하고, 그 수용보상금의 분배는 총유물의 처분에 해당하므로, 정관 기타 규약에 아무런 정함이 없다면 종중총회의 결의에 의하여는 그 수용보상금을 분배할 수 없다. ()

12. 법인은 그 주된 사무소의 소재지에서 설립등기를 함으로써 성립하고, 법률의 규정에 좇아 정관으로 정한 목적의 범위 내에서 권리와 의무의 주체가 된다. ()

법인의 대표자에는 그 명칭이나 직위 여하, 또는 대표자로 등기되었는지 여부를 불문하고 당해 법인을 실질적으로 운영하면서 법인을 사실상 대표하여 법인의 사무를 집행하는 사람을 포함한다. 그리고 이러한 법리는 비법인사단에도 마찬가지로 적용된다(대법원 2011.4.28. 2008다15438). (○)

적법한 대표자 자격이 없는 비법인사단의 대표자가 한 소송행위를 후에 적법한 대표자가 추인한 경우에는 행위시에 소급하여 효력을 가진다(대법원 2019.9.10. 2019다208953). (×)

비법인사단에 해산사유가 발생하였다고 하더라도 곧바로 당사자능력이 소멸하는 것이 아니라 청산사무가 완료될 때까지 청산의 목적범위 내에서 권리·의무의 주체가 된다(대법원 2007.11.16. 2006다41297). (×)

법인 아닌 사단인 종중이 그 총유재산에 대한 보존행위로서 소송을 하는 경우에도 특별한 사정이 없는 한 종중 총회의 결의를 거쳐야 한다(대법원 2010.2.11. 2009다83650). (○)

법인 아닌 사단에 대하여는 사단법인에 관한 민법규정 가운데서 법인격을 전제로 하는 것을 제외하고는 이를 유추적용하여야 한다(대법원 2001다32687). (○)

부동산등기법 제26조 (○)

비법인사단인 종중의 토지에 대한 수용보상금은 종원의 총유에 속하고, 그 수용보상금의 분배는 총유물의 처분에 해당하므로, 정관 기타 규약에 달리 정함이 없는 한 종중총회의 결의에 의하여 그 수용보상금을 분배할 수 있다(대법원 2010.9.30. 2007다74775). (×)

법인은 법률의 규정에 좇아 정관으로 정한 목적의 범위내에서 권리와 의무의 주체가 된다(제34조). (○)

13. 사단법인의 사원들이 정관의 규범적인 의미 내용과 다른 해석을 사원총회의 결의라는 방법으로 표명하였다면 그 결의에 의한 해석은 그 사단법인의 구성원인 사원들을 구속한다. ()

정관의 규범적인 의미 내용과는 다른 해석이 사원총회의 결의에 의하여 표명된 경우, 그 결의에 의한 해석은 사원들을 구속하지 아니한다(대법원 2000.11.24 99다12437). (×)

14. 유언으로 재단법인을 설립하는 경우 재단법인이 출연재산인 부동산에 관하여 소유권이전등기를 마치지 아니하였다면 유언자의 상속인의 한 사람으로부터 부동산의 지분을 취득하여 이전등기를 마친 선의의 제3자에 대하여 대항할 수 없다. ()

대법원 1993.9.14. 93다8054 (○)

15. 법인의 목적범위 외의 행위로 인하여 타인에게 손해를 가한 때에는 그 사항의 의결에 찬성하거나 그 의결을 집행한 사원, 이사 및 기타 대표자가 연대하여 배상하여야 한다. ()

제35조 (○)

16. 민법 제35조에서 말하는 이사 기타 대표자는 법인의 대표기관을 의미하며, 이사에 의하여 선임된 특정 행위에 대한 대리인, 지배인, 사원총회, 감사 등은 대표기관에 해당하지 않는다. ()

타당한 기술이다. (○)

17. 대표권이 없는 이사의 행위에 의하여도 민법 제35조 제1항의 불법행위가 성립한다. ()

대표권이 없는 이사는 법인의 기관이기는 하지만 대표기관은 아니므로, 그의 행위에 의하여는 제35조 제1항의 불법행위가 성립하지 않으며, 756조의 사용자의 배상책임이 성립할 수 있을 뿐이다(대법원 2003다30159). (×)

18. 대표자 개인의 사리를 도모하기 위한 것이었거나 법령의 규정에 위배된 것이었다면, 이러한 행위는 직무에 관한 행위에 해당하지 않으므로 법인은 그 대표자의 불법행위로 인한 손해배상의무를 부담하지 않는다. ()

외형상 법인의 대표자의 직무행위라고 인정할 수 있는 것이라면 설사 그것이 대표자 개인의 사리를 도모하기 위한 것이었거나 혹은 법령의 규정에 위배된 것이었다 하더라도 위의 직무에 관한 행위에 해당한다고 보아야 한다(대법원 2004.2.27. 2003다15280). (×)

19. 대표자의 행위가 직무에 관한 행위에 해당하지 아니함을 피해자 자신이 알았거나 또는 중대한 과실로 인하여 알지 못한 경우에는 법인에게 손해배상 책임을 물을 수 없다. ()

대법원 2004.3.26 2003다34045 (○)

20. 법인의 불법행위가 성립하는 경우에는 피해자에 대하여 법인과 대표기관이 배상할 책임을 지며, 양자의 책임은 부진정연대채무의 관계에 있고, 법인이 배상한 경우에는 대표기관에 대하여 구상권을 행사할 수 없다. ()

법인의 불법행위가 성립하는 경우에는 피해자에 대하여 법인과 대표기관이 배상할 책임을 지며, 양자의 책임은 부진정연대채무의 관계에 있고, 법인이 배상한 경우에는 대표기관에 대하여 구상권을 행사할 수 있다. (×)

- 21.** 이사는 법인의 사무에 관하여 법인을 각자 대표함이 원칙이다. ()
- 22.** 이사의 대표권에 대한 제한은 이를 정관에 기재하지 않으면 그 효력이 없다. ()
- 23.** 법원의 직무집행정지 가처분결정에 의하여 회사를 대표할 권한이 정지된 대표이사가 그 정지기간 중에 체결한 계약은 절대적으로 무효이다. ()
- 24.** 법인의 이사는 선량한 관리자의 주의로 그 직무를 행하여야 한다. ()
- 25.** 이사는 정관이나 총회의 결의로 금지되지 않은 이상 타인으로 하여금 포괄적 대리를 하게 할 수 있다. ()
- 26.** 법인의 정관에 법인 대표권의 제한에 관한 규정이 있으나 그와 같은 취지가 등기되어 있지 않다면 법인은 그와 같은 정관의 규정에 대하여 선의나 악의나에 관계없이 제3자에 대하여 대항할 수 없다. ()
- 27.** 법인이 정관에서 이사의 사임절차나 사임의 의사표시의 효력발생시기 등에 관하여 특별한 규정을 둔 경우, 이사가 사임의 의사표시를 하였고 그 의사표시가 법인의 대표자에게 도달하였다고 하더라도 정관에 따라 사임의 효력이 발생하기 전에는 그 사임의사를 자유롭게 철회할 수 있다. ()
- 28.** 사단법인의 사원의 지위는 양도 또는 상속할 수 없다고 규정한 민법 제56조의 규정은 강행규정이므로, 비법인사단에서도 사원의 지위는 규약이나 관행에 의하여 양도 또는 상속될 수 없다. ()
- 29.** 비영리사단법인의 정관 중 해산시 잔여재산의 귀속권리자를 직접 정하지 않고 사원총회나 이사회 결의에 따라 이를 정하도록 한 조항은 무효이다. ()
- 30.** 재단법인의 기본재산의 변경은 정관의 변경을 초래하기 때문에 주무관청의 허가를 받아야 하는 데, 기존의 기본재산을 처분하는 행위는 물론 새로이 기본재산으로 편입하는 행위도 주무관청의 허가가 있어야 유효하다. ()

제59조 제1항 (○)

제41조 (○)

법원의 직무집행정지 가처분결정에 의해 회사를 대표할 권한이 정지된 대표이사가 그 정지기간 중에 체결한 계약은 절대적으로 무효이다(대법원 2008.5.29. 2008다4537). (○)

제61조 (○)

이사는 정관 또는 총회의 결의로 금지하지 아니한 사항에 한하여 타인으로 하여금 특정한 행위를 대리하게 할 수 있다(제62조). (×)

대법원 1992.2.14. 91다24564 (○)

대법원 2008.9.25 2007다17109 (○)

사단법인의 사원의 지위는 양도 또는 상속할 수 없다고 규정한 56조의 규정은 강행규정이라고 할 수 없으므로, 비법인사단에서도 사원의 지위는 규약이나 관행에 의하여 양도 또는 상속될 수 있다(대법원 1997.9.26. 95다6205). (×)

법인해산시 잔여재산의 귀속권리자를 직접 정하지 아니하고 사원총회나 이사회 결의에 따라 이를 정하도록 하는 등 간접적으로 그 귀속권리자의 지정방법을 정해 놓은 정관 규정도 유효하다(대법원 1995.2.10 94다13473). (×)

대법원 1982.9.28. 82다카499 (○)

◎ 단원별 출제경향

구 분	28회	29회	30회	31회	32회	33회	34회
권리의 객체(물건)	1	1	1	1	1	1	1

제1절 물건의 의미

물건이라 함은 유체물 및 전기 기타 관리가능(배타적 지배)한 자연력을 말한다(제98조).

제2절 물건의 요건

1. 관리가능한 유체물 또는 자연력

2. 독립된 존재일 것

- (1) 용익물권의 객체는 토지나 건물의 일부 위에 설정이 가능하다.
- (2) 명인방법을 갖춘 수목의 집단은 독립하여 소유권의 객체가 된다.
- (3) 소유권보존등기를 한 수목의 집단은 독립하여 소유권과 저당권의 객체가 된다.

제3절 물건의 분류(부동산과 동산)

사 항	부동산	동산
의 의	토지와 그 정착물(제99조 제1항)	부동산 이외의 물건(제99조 제2항)
공시방법	등기(제186조)	점유(인도)(제188조)

사 항	부동산	동 산
상린관계	적용(제215조 이하)	적용배제
취득시효	① 등기부취득시효 : 10년(제245조제2항) ② 점유취득시효 : 20년(제245조 제1항)	① 선의취득시효 : 5년(제246조 제2항) ② 일반취득시효 : 10년(제246조 제1항)
공 신 력	없음(등기).	있음(점유).
선의취득	적용배제	적용(제249조)
선 점	무주의 부동산은 국유(제252조 제2항)	무주의 동산은 선점자의 소유(제252조 제1항)
제한물권	① 지상권·지역권·전세권·저당권의 설정 ② 유치권의 성립	① 질권의 설정 ② 유치권의 성립
환매기간	5년	3년
부합의 효 력	□ 부동산에의 부합 부동산소유자가 부합한 동산의 소유권을 취득(제256조)	□ 동산 간의 부합 ① 부합한 동산 사이에 주종을 구별할 수 있는 때: 주된 동산의 소유자가 합성물의 소유권을 취득 ② 주종을 구별할 수 없는 때: 각 동산의 소유 자는 부합 당시의 가격의 비율로 합성물을 공유(제257조)
가공의 효 력	가공은 인정되지 않음.	타인의 동산에 가공한 때에는 그 물건의 소유 권은 원칙적으로 원재료의 소유자에게 속함 (제259조 제1항).

제4절 물건의 분류(주물과 종물)

1. 종물의 요건

(1) 주물의 상용에 공(供)하는 것일 것

- ① 사회관념상 주된 물건의 경제적 효용을 보조하기 위하여 계속적으로 이바지되어야 하는 관계가 있어야 한다.
- ② 주물 그 자체의 효용과 직접 관계가 없는 물건은 종물이 아니다.
식기·침구·난로·텔레비전·책상 등은 건물의 종물의 아니다.

(2) 독립한 물건일 것

- ① 종물은 주물의 구성부분이 아니고, 독립한 물건이어야 한다.
- ② 주물과 종물 모두 부동산이든 동산이든 불문한다.

(3) 장소적으로 밀접한 위치에 있을 것

주물에 부속시킨 것으로 인정할 만한 정도의 밀접한 장소적 관계가 있어야 한다.

(4) 주물·종물 모두 동일한 소유자에게 속할 것

2. 종물의 효과

(1) 종물은 주물의 처분에 따른다(제100조 제2항).

- ① 주물 위에 저당권이 설정된 경우에는 그 저당권의 효력은 저당권설정 전후를 불문하고 종물에도 그 효력이 미친다(제358조 참조).
- ② 제100조 제2항의 규정은 임의규정이다. 따라서 당사자의 특약으로 달리 약정할 수 있다.

(2) 종물이론의 준용

종물을 주물의 처분에 따르도록 한 법리는 권리 상호간에도 적용된다. 즉 주된 권리(피담보채권)가 이전하면 종된 권리(담보물권)도 따라서 이전함이 원칙이다. 또한 물건과 권리 간에도 준용될 수 있다.

제5절 물건의 분류(원물과 과실)

1. 천연과실

(1) 의 의

- ① 천연과실이란 물건의 용법에 따라 산출되는 산출물을 말한다(제101조 제1항).
- ② 과수에 맺힌 열매, 가축의 새끼, 광산의 광물, 석재, 토사 등이 이에 해당한다.
- ③ 천연과실은 원물로부터 분리하는 때에 이를 수취할 권리자에게 귀속한다(제102조 제1항).

(2) 천연과실의 수취권자

- ① 원물의 소유자(제211조)
- ② 선의의 점유자(제201조)
- ③ 지상권자(제279조)
- ④ 전세권자(제303조)
- ⑤ 유치권자(제323조)
- ⑥ 질권자(제343조)
- ⑦ 압류한 후의 저당권자(제359조)

- ⑧ 목적물인도 전의 매도인(제587조)
- ⑨ 사용차주(제609조)
- ⑩ 임차인(제618조)

* 유치권자와 질권자는 원칙적으로는 수취권자가 될 수 없으나, 예외적으로 담보물에서 파생되는 과실로서 변제에 충당할 수 있다. 그리고 저당권의 효력도 목적물의 과실에는 원칙적으로 미치지 아니하나, 압류 후에는 그 효력이 미친다.

2. 법정과실

(1) 의의

- ① 법정과실이란 물건의 사용대가로 받는 금전 기타의 물건을 말한다(제101조 제2항).
임대차에 있어서의 사용료, 즉 차임(집세)이나 지료 등 이다.
- ② 원물과 과실은 모두 물건이어야 하므로
노동의 대가(임금)·권리사용의 대가(주식의 배당금·특허권의 사용료) 등은 법정과실이 아니다.

(2) 법정과실의 귀속

- ① 법정과실은 이를 수취할 권리의 존속기간 일수의 비율로 취득한다(제102조 제2항).
- ② 제102조 제2항은 임의규정이며 당사자의 특약이 있으면 그에 의한다.



핵심 판례 정리

- 01.** 독립된 부동산으로서의 건물이라고 함은 최소한의 기둥과 지붕 그리고 주벽이 이루어지면 법률상 건물이라고 할 수 있다.
- 02.** 임야에 있는 자연석을 조각하여 제작한 석불이라도 그 임야의 일부분을 구성하는 것이라고는 할 수 없고 임야와 독립된 소유권의 대상이 된다.
- 03.** 온천에 관한 권리(온천권)는 관습법상의 물건이라고 볼 수 없다.
- 04.** 구분건물이 되기 위하여는 객관적, 물리적인 측면에서 구분건물이 구조상, 이용상의 독립성을 갖추어야 하고, 그 건물을 구분소유권의 객체로 하려는 의사표시 즉 구분행위가 있어야 한다.
- 05.** 정화조는 건물의 대지가 아닌 다른 필지의 지하에 설치되어 있다 하더라도 독립한 물건인 중물이라기보다는 건물의 구성부분이다.

- 06.** 횃집으로 사용할 점포건물에 거의 붙여서 횃감용 생선을 보관하기 위하여, 즉 위 점포건물의 상용에 공하기 위하여 신축한 수족관건물은 위 점포건물의 종물이다.
- 07.** 건물에 대한 저당권의 효력은 그 건물에 종된 권리인 건물의 소유를 목적으로 하는 지상권에도 미친다.
- 08.** [1] 주유소의 지하에 매설된 유류저장탱크는 토지에 부합된 것으로 본다.
[2] 주유소의 주유기는 계속해서 주유소 건물 자체의 경제적 효용을 다하게 하는 작용을 하고 있으므로 주유소건물의 상용에 공하기 위하여 부속시킨 종물이다.
- 09.** 백화점 건물의 지하 2층 기계실에 설치되어 있는 전화교환설비는 백화점의 효용과 기능을 다하기에 필요 불가결한 시설들로서, 위 건물의 상용에 제공된 종물이라 할 것이다.
- 10.** 국립공원의 입장료는 토지의 사용대가라는 민법상 과실이 아니라 수익자 부담의 원칙에 따라 국립공원의 유지·관리비용의 일부를 국립공원 입장객에게 부담시키는 것이다.
- 11.** 부동산의 상용에 공하여진 물건일지라도 그 물건이 부동산의 소유자가 아닌 다른 사람의 소유인 때에는 이를 종물이라고 할 수 없으므로 부동산에 대한 저당권의 효력에 미칠 수 없어 부동산의 낙찰자가 당연히 그 소유권을 취득하는 것은 아니다.
- 12.** 피상속인이 생전행위 또는 유언으로 자신의 유체·유골을 처분하거나 매장장소를 지정한 경우에, 선량한 풍속 기타 사회질서에 반하지 않는 이상 그 의사는 존중되어야 하고 이는 제사주재자로서도 마찬가지이지만, 피상속인의 의사를 존중해야 하는 의무는 도의적인 것에 그치고, 제사주재자가 무조건 이에 구속되어야 하는 법률적 의무까지 부담한다고 볼 수는 없다.



중요 지문 정리

- 01.** 부동산으로 취급되는 토지의 정착물에는 건물, 입목에 관한 법률에 의하여 등기된 입목 등이 있으며, 독립된 건물이라고 하기 위해서는 최소한의 기둥과 지붕 그리고 주벽이 이루어져야 한다. ()
- 02.** 부동산에 부합된 물건이 사실상 분리복구가 불가능하여 거래상 독립한 권리의 객체성을 상실하고 그 부동산과 일체를 이루는 부동산의 구성부분이 된 경우에는 타인이 권원에 의하여 이를 부합시켰더라도 그 물건의 소유권은 부동산의 소유자에게 귀속된다. ()

건물이라고 함은 최소한의 기둥과 지붕 그리고 주벽이 이루어지면 이를 법률상 건물이라 할 수 있다(대법원 1986.11.11. 86누173), (○)

대법원 2008.5.8. 2007다36933 (○)

03. 주물과 다른 사람의 소유에 속하는 물건은 종물이 될 수 없다. ()

대법원 2008.5.8. 2007다36933 (○)

04. 횡집으로 사용할 점포 건물에 거의 붙여서 횡감용 생선을 보관하기 위하여 신축한 수족관 건물은 독립한 부동산이지만 점포 건물의 종물에 해당한다. ()

대법원 1993.2.12 92도3234 (○)

05. 종물은 주물의 처분에 수반된다는 민법 제100조 제2항은 강행규정이므로, 당사자는 주물을 처분할 때에 특약으로 종물을 제외할 수 없고 종물만을 별도로 처분할 수 없다. ()

종물은 주물의 처분에 수반된다는 100조 2항은 임의규정이므로, 당사자는 주물을 처분할 때에 특약으로 종물을 제외할 수 있고 종물만을 별도로 처분할 수도 있다(대법원 2012.1.26. 2009다76546). (×)

06. 구분건물의 전유부분에 대한 소유권보존등기만 경료되고 대지지분에 대한 등기가 경료되기 전에 전유부분만에 대해 내려진 가압류결정의 효력은, 그 대지권에 미치지 아니한다. ()

구분건물의 전유부분에 대한 소유권보존등기만 경료되고 대지지분에 대한 등기가 경료되기 전에 전유부분만에 대해 내려진 가압류결정의 효력은, 대지사용권의 분리처분이 가능하도록 규약으로 정하였다는 등의 특별한 사정이 없는 한, 종물 내지 종된 권리인 그 대지권에까지 미친다(대법원 2006다29020). (×)

07. 4번지문과 중복으로 삭제

08. 건물에 대한 저당권의 효력은 그 건물소유를 목적으로 하는 지상권에도 미친다. ()

대법원 1996.04.26. 95다52864 (○)

09. 권한 없이 타인의 토지에 농작물을 심은 경우, 수확기에 이른 농작물의 소유권은 토지 소유자에게 귀속된다. ()

권한 없이 타인의 토지에 경작·재배한 경우에 명인방법을 갖출 필요 없이 성숙한 농작물의 소유권은 언제나 그 경작자에 있다(대법원 1978.3.14. 77다2396). (×)

10. 주물과 종물의 법리는 물건 상호간에 적용되고, 권리 상호간에는 적용되지 않는다. ()

종물이론은 권리와 권리, 물건과 권리 간에도 준용될 수 있다. (×)

11. 국립공원의 입장료는 법정과실이다. ()

국립공원의 입장료는 토지의 사용대가라는 민법상 과실이 아니라 수익자 부담의 원칙에 따라 국립공원의 유지·관리비용의 일부를 국립공원 입장객에게 부담시키고자 하는 것이어서 토지의 소유권이나 그에 기한 과실수취권과는 아무런 관련이 없다(대법원 2001. 12.28. 2000다27749). (×)

12. 저당권의 효력은 저당부동산의 종물에 미치므로 경매를 통하여 저당부동산의 소유권을 취득한 자는 특별한 사정이 없는 한 종물의 소유권을 취득한다. ()

타당한 기술이다.. (○)

13. 건물임대차에 있어서의 차임과 같이「물건의 사용대가로 받는 금전 기타의 물건」이 법정과실이며, 법정과실은 수취할 권리의 존속기간 일수의 비율로 취득한다. 따라서 임대 중인 건물이 매매된 경우에 그 차임은 임대인들, 즉 그 건물의 매도인과 매수인에게 그 소유기간 일수의 비율로 귀속한다. ()

타당한 기술이다.. (○)

◎ 단원별 출제경향

구 분	28회	29회	30회	31회	32회	33회	34회
법률행위	10	10	8	9	10	10	10

제1절 법률행위의 종류

1. 기본적 분류

표 준	세 분	내 용	예
의 사 표 시	단독행위	상대방 있는 단독행위	동의, 철회, 상계, 추인, 해제, 해지, 취소, 채무면제 등
		상대방 없는 단독행위	권리의 포기, 재단법인의 설립행위, 유언 등
	계 약	-	매매, 교환, 임대차, 사용대차, 증여, 소비대차, 위임, 도급, 화해, 조합, 현상광고, 고용, 임치, 종신통기금, 여행계약
	합동행위	-	사단법인의 설립행위
법 률 효 과	채권행위	채권을 발생시키며 이행의 문제를 남김(원인, 약속: 14종의 계약); <u>의무부담행위</u>	
	물권행위	물권변동이 일어나며 더 이상의 이행의 문제는 없음 (결과, 이행: 소유권이전, 전세권설정 등); <u>처분행위</u>	
	준물권행위	물권 이외의 권리의 종국적 변동을 일으키고 이행의 문제는 없음 (채권양도, 채무면제 등); <u>처분행위</u>	

- (1) 권리의 포기 중 기한이익의 포기, 시효이익의 포기, 제한물권의 포기는 상대방 있는 단독행위에 해당한다.
- (2) 계약의 합의해제와 매매의 일방예약은 계약이며, 채권행위(매매, 임대차, 주택분양계약 등)는 의무부담행위이고 물권행위(지상권 및 저당권설정행위 등)는 처분행위에 해당한다.

2. 기타의 분류

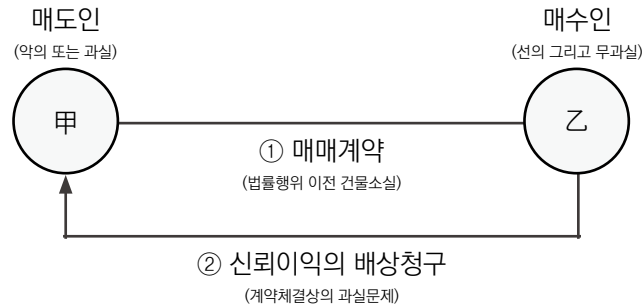
- (1) 재산행위와 신분행위(혼인, 이혼, 입양, 파양 등)
- (2) 요식행위(법인설립행위, 혼인 등의 신분행위, 어음·수표행위 등)와 불요식행위
- (3) 생전행위와 사후행위(유증, 사인증여 등)
- (4) 유상행위와 무상행위(사용대차, 증여 등)
- (5) 유인행위와 무인행위(어음·수표행위)
- (6) 독립행위와 보조행위(동의, 추인, 대리권 수여 등)
- (7) 주된 행위(소비대차계약)와 종된 행위(담보설정계약)

제2절 법률행위의 목적

1. 목적의 가능과 불능

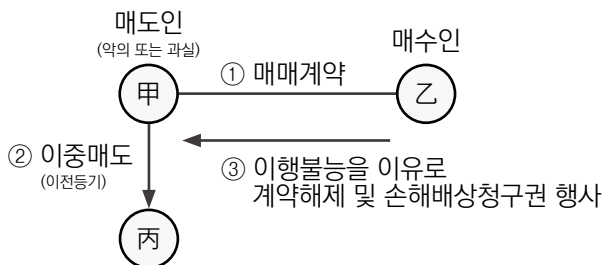
목적의 원시적 불능은 당연 무효이나, 목적의 후발적 불능은 법률행위를 무효로는 보지 않고 (원칙적으로 유효), 이행불능과 위험부담의 문제로 나누어 판단한다.

◎ 원시적 불능의 효과

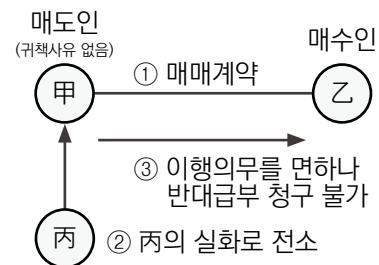


◎ 후발적 불능의 효과

(1) 이행불능



(2) 위험부담



2. 사회질서위반의 실질적 유형

법률행위의 목적이 적법하고 가능하더라도 그것이 선량한 풍속 기타 사회질서에 위반되는 것을 내용으로 할 때에는 무효이다.

유 형	구체적인 예
정의의 관념에 반하는 행위	① 매도인의 배임행위에 적극 가담한 이중매매 ② 법정에서 허위진술을 대가로 금전의 교부약정 ③ 경매나 입찰에서의 담합행위 ④ 불법행위를 하거나 하지 않을 것을 내용으로 하는 계약 ⑤ 피보험자를 살해하여 보험금을 편취할 목적으로 체결한 생명보험계약 ⑥ 밀수자금의 소비대차, 공무원의 청탁과 수뢰약정
인륜에 반하는 행위	① 첩계약은 처의 동의유무를 불문하고 무효 단, 첩관계의 단절을 목적으로 위자료 지급계약이나 첩관계에서 태어난 자(子)의 양육비 지급계약은 유효 ② 자식의 부모에 대한 불법행위를 이유로 한 손해배상청구
개인의 자유를 극도로 제한하는 행위	① 개인의 정신 또는 신체의 자유를 극도로 제한하는 행위 □ 평생 혼인하지 않겠다는 계약 □ 혼인하면 퇴직하겠다는 각서를 써 준 경우 □ 어떠한 일이 있어도 이혼하지 않겠다는 약정 ② 개인의 경제활동의 자유를 지나치게 제한하는 행위
생존의 기초가 되는 재산의 처분행위	① 사찰이 그 존립에 없어서는 안 될 임야를 증여하는 행위 ② 장래에 취득하게 될 모든 재산을 양도하는 계약
도박 등의 사행행위	① 도박계약이나 도박자금을 대여하는 계약 ② 도박채무의 변제로 토지의 양도계약

3. 부동산의 이중매매

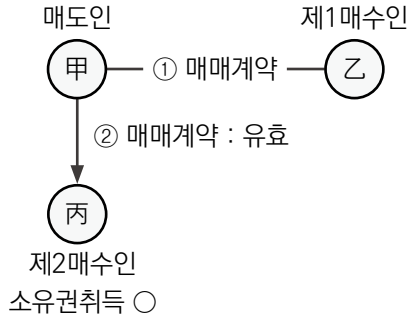
(1) 이중매매의 유효성

이중매매는 원칙적으로 유효하다. 제2매수인이 소유권을 취득하는 경우 제1매매행위는 이행불능이 되어 제1매수인은 매도인에게 채무불이행의 책임을 물을 수 있다.

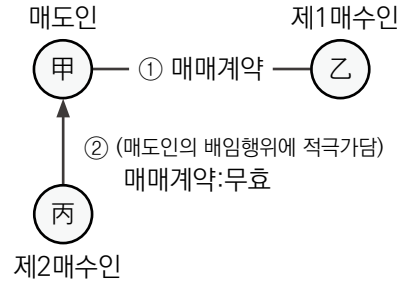
(2) 이중매매가 무효인 경우

- ① 제1매수인은 매도인을 대위하여 제2매수인에게 등기의 말소를 청구할 수 있다(채권자대위권).
- ② 제1매수인의 채권자취소권은 부정된다는 것이 판례의 태도이다
 (채권자취소권의 피보전채권은 금전채권에 한함).

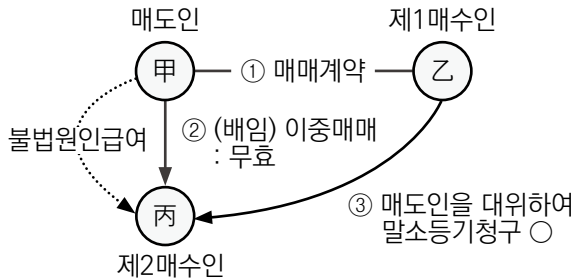
◆ 이중매매(유효인 경우)



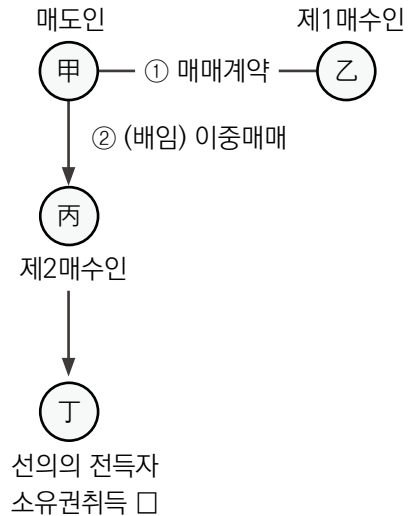
◆ 이중매매(무효인 경우)



◆ 이중매매(무효인 경우)



◆ 이중매매(무효인 경우)



4. 불공정한 법률행위

(1) 요건

① 주관적 요건

- ㉠ 가해자가 피해자의 공박·경솔 또는 무경험을 이용하였어야 한다.

공박이란 경제적인 공박상태 뿐만 아니라 물리적·정신적 공박도 포함된다.

그리고 당사자의 공박·경솔·무경험 중 어느 하나라도 갖추어지면 된다.

아울러 무경험이란 특정영역에서의 경험부족을 말하는 것이 아니라, 거래 일반의 경험부족을 뜻하는 것이라는 것이 판례이다.

- ㉡ 폭리자가 피해자에게 위와 같은 사정이 있음을 알고서 그것을 이용하려는 의사, 즉 악의를 가지고 있어야 한다는 것이 판례의 태도이다.

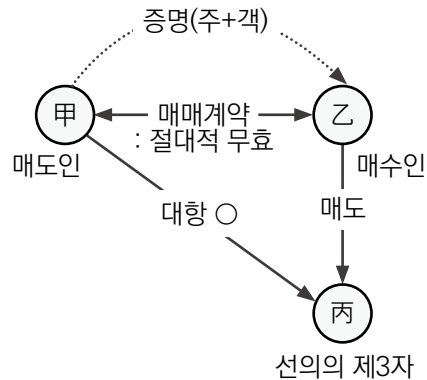
- ㉢ 불공정한 법률행위가 성립하기 위한 객관적 요건과 주관적 요건은 그 법률행위의 무효를 주장하는 자가 이를 증명하여야 한다.

불균형을 판정하는 시기에 대하여 판례는 법률행위시를 기준으로 한다.

폭리행위는 무효이다.

```

graph LR
    A((甲)) -- 매매계약 --> B((乙))
    B -- 대금(1500만)지급 --> A
    A --- AInfo[매도인  
(공박·경찰·무경험)]
    B --- BInfo[매수인  
(폭리자)]
    A --- TopInfo[토지(1억)이전]
  
```



01. 양도소득세의 일부를 회피할 목적으로 매매계약서에 실제로 거래한 가액을 매매대금으로 기재하지 아니하고 그보다 낮은 금액을 매매대금으로 기재한 경우에도 그 매매계약이 사회질서에 반하는 법률행위에 해당하지 않는다.

02. 주택매매계약에 있어서 매도인으로 하여금 주택의 보유기간이 3년 이상으로 되게 함으로써 양도소득세를 부과 받지 않게 할 목적으로 소유권이전등기는 3년 후에 넘겨받기로 특약을 하였다고 하더라도, 위 특약 자체가 사회질서나 신의칙에 위반한 것이라고는 볼 수 없다.

03. 부채관계의 종료를 해제조건으로 하는 증여계약은 그 조건만이 무효인 것이 아니라 증여계약 자체가 무효이다.

04. 처(妻)에게 부동산을 양도하되, 부부관계가 유지되는 동안에는 처가 임의로 처분할 수 없다는 제한을 붙인 약정은 선풍한 풍속 기타 사회질서에 위반되는 것이라고 볼 수 없다.

- 05.** 법률행위의 성립과정에 강박이라는 불법적 방법이 사용된 데에 불과한 때에는 강박에 의한 의사표시의 하자나 의사의 흠결을 이유로 효력을 논의할 수는 있을지언정 반사회질서의 법률행위로서 무효라고 할 수는 없다.
- 06.** 증언하여 주는 대가로 용인될 수 있는 정도를 초과하는 급부를 제공받기로 한 약정은 반사회질서행위에 해당하여 무효이다.
- 07.** 공무원의 직무에 관하여 특별한 청탁을 하게하고 그에 대한 보수로 돈을 지급할 것을 내용으로 한 약정은 반사회질서행위에 해당하여 무효이다.
- 08.** 해외에 파견된 근로자가 귀국일로부터 일정기간 소속회사에 근무하여야 한다는 사규나 약정은 민법 제103조 또는 제104조에 위반된다고 할 수 없다.
- 09.** 반사회적 행위에 의하여 조성된 재산인 이른바 비자금을 소극적으로 은닉하기 위하여 임치한 것은 사회질서에 반하는 법률행위로 볼 수 없다.
- 10.** 종래 이루어진 형사사건에서의 성공보수약정의 경우에는 보수약정이 성공보수라는 명목으로 되어 있다는 이유만으로 민법 제103조에 의하여 무효라고 단정하기는 어렵다. 그러나 대법원이 이 판결을 통하여 형사사건에 관한 성공보수약정이 선량한 풍속 기타 사회질서에 위배되는 것으로 평가할 수 있음을 명확히 밝혔음에도 불구하고 향후에도 성공보수약정이 체결된다면 이는 민법 제103조에 의하여 무효로 보아야 한다(대법원 2015.7.23. 2015다200111 전원합의체).
- 11.** 이중매매가 반사회적 법률행위로서 무효가 되기 위하여는 매수인이 다른 사람에게 매매목적물이 매도된 것을 안다는 것만으로는 부족하고, 적어도 그 매도사실을 알고도 매도를 요청(적극 권유)하여 매매계약에 이르는 정도가 되어야 한다.
- 12.** 매도인의 매수인에 대한 배임행위에 가담하여 증여를 받아 이를 원인으로 소유권이전등기를 경료한 수증자에 대하여 매수인은 매도인을 대위하여 위 등기의 말소를 청구할 수는 있으나 직접 청구할 수는 없다.
- 13.** 이중매매에서 제1의 법률행위 또는 제2의 법률행위가 반드시 매매일 것을 요하지 아니한다.
- 14.** 반사회적 법률행위에 해당하는 경우의 이중매매는 절대적으로 무효이므로, 부동산을 제2매수인으로부터 다시 취득한 제3자는 설사 제2매수인이 당해 부동산의 소유권을 유효하게 취득한 것으로 믿었더라도 이중매매계약이 유효하다고 주장할 수 없다.

15. 땅 소유자가 문맹에다 농사일 외의 다른 사회경험이 없고 부동산시세가 어두운 고령인 점을 이용, 현시가 1억 원이상 짜리의 땅을 감정가격의 30%에도 미치지 못하는 1천5백만 원에 토지매매계약을 체결했다면 그 계약은 무효이다.

16. 불공정한 법률행위가 성립하기 위하여는 법률행위의 당사자 일방이 공박, 경솔 또는 무경험의 상태에 있고, 상대방이 이러한 사정을 알고서 이를 이용하려는 의사가 있어야 하며, 나아가 급부와 반대급부 사이에 현저한 불균형이 있어야 하는 바, 위 당사자 일방의 공박, 경솔, 무경험은 모두 구비하여야 하는 요건이 아니고 그 중 어느 하나만 갖추어져도 충분하다.

17. 대리인에 의하여 법률행위가 이루어진 경우 경솔과 무경험은 대리인을 기준으로 하여 판단하고, 공박은 본인의 입장에서 판단하여야 한다.

18. 민법 제104조에서 정하는 '불공정한 법률행위'에 해당하여 무효인 경우에도 무효행위의 전환에 관한 민법 제138조가 적용되어 당사자 쌍방이 위와 같은 무효를 알았다더라면 대금을 다른 액으로 정하여 매매계약에 합의하였을 것이라고 예외적으로 인정되는 경우에는 그 대금액을 내용으로 하는 매매계약이 유효하게 성립할 수 있다.

19. '불공정한 법률행위'에 해당하여 무효라고 한다면, 그 계약으로 인하여 불이익을 입는 당사자로 하여금 위와 같은 불공정성을 소송 등 사법적 구제수단을 통하여 주장하지 못하도록 하는 부제소합의 역시 다른 특별한 사정이 없는 한 무효이다.

20. 불공정 법률행위에 해당하는지는 법률행위가 이루어진 시점을 기준으로 약속된 급부와 반대급부 사이의 객관적 가치를 비교 평가하여 판단하여야 한다.

21. 계약분 아니라 권리의 포기과 같은 단독행위에서도 불공정한 법률행위는 발생한다. 그러나 부담 없는 증여나 기부행위와 같은 무상행위, 그리고 경매는 일반매매와 달라서 제104조가 적용되지 않는다.

22. '공박'이라 함은 '급박한 곤궁'을 의미하는 것으로서 경제적 원인에 기인할 수도 있고 정신적 또는 심리적 원인에 기인할 수도 있으며, '무경험'이라 함은 어느 특정영역에 있어서의 경험부족이 아니라 거래일반에 대한 경험부족을 뜻하고, 피해당사자가 공박, 경솔 또는 무경험의 상태에 있었다고 하더라도 그 폭리자에게 그와 같은 피해 당사자 측의 사정을 알면서 이를 이용하려는 의사, 즉 폭리행위의 악의가 없었거나 또는 객관적으로 급부와 반대급부 사이에 현저한 불균형이 존재하지 아니한다면 불공정한 법률행위는 성립하지 않는다.

23. 불공정한 법률행위로서 무효인 경우에는 추인에 의하여 무효인 법률행위가 유효로 될 수 없다.

- 24.** 금융기관이 예금 명의자의 주민등록증을 통하여 실명 확인을 하고 그 명의의 예탁금계좌를 개설한 경우에는 그 예탁금의 예금주는 예금 명의자인 것으로 보아야 한다.
- 25.** 계약을 체결하는 행위자가 타인의 이름으로 법률행위를 한 경우에, 우선 행위자와 상대방의 의사가 일치한 경우에는 그 일치한 의사대로 행위자 또는 명의인을 계약의 당사자로 확정하여야 한다.
- 26.** 부동산의 경매절차에서 경매목적 부동산을 경락받은 경락인이 실질적인 권리자가 아니라 단순히 타인을 위하여 그 명의만을 빌려준 것에 불과하더라도 경매목적 부동산의 소유권은 경락대금을 실질적으로 부담한 자가 누구인가에 상관없이 그 명의인이 적법하게 취득한다고 할 것이다.



중요 지문 정리

01. 계약체결의 요건을 규정하고 있는 강행법규에 위반한 계약은 무효이므로 그 경우에 계약상대방이 선의·무과실이더라도 민법 제107조의 비진의표시의 법리 또는 표현대리법리가 적용될 여지는 없다. ()

대법원 2016.5.12. 2013다4938 (○)

02. 강행법규 위반으로 무효인 경우에는 당사자의 추인이 있더라도 유효로 되지 않는다. ()

절대적 무효는 추인할 수 없다. (○)

03. 관련 법령에서 정한 한도를 초과하는 부동산 중개수수료 약정은 그 약정 전체를 무효로 한다. ()

관련 법령(공인중개사법)에서 정한 한도를 초과하는 부동산 중개수수료 약정은 그 한도를 초과하는 범위 내에서 무효이다. (×)

04. 표시되거나 상대방에게 알려진 법률행위의 동기가 반사회질서적인 경우라도 법률행위의 내용 자체가 반사회질서적인 것이 아니라면 그 법률행위는 무효로 볼 수 없다. ()

103조에서 정하는 반사회질서의 법률행위는 법률행위의 목적인 권리의 무의 내용이 선량한 풍속 기타 사회질서에 위반되는 경우뿐만 아니라, 그 내용 자체는 반사회질서적인 것이 아니라고 하여도 법적으로 이를 강제하거나 법률행위에 사회질서의 근간에 반하는 조건 또는 금전적인 대가가 결부됨으로써 그 법률행위가 반사회질서적 성질을 띠게 되는 경우 및 표시되거나 상대방에게 알려진 법률행위의 동기가 반사회질서적인 경우를 포함한다(대법원 2009.9.10. 2009다37251). (×)

05. 당사자의 일방이 상대방에게 공무원의 직무에 관한 사항에 관하여 특별한 청탁을 하게 하고 그에 대한 보수로 돈을 지급할 것을 내용으로 한 약정은 사회질서에 반하는 무효의 계약이다. ()

당사자의 일방이 상대방에게 공무원의 직무에 관한 사항에 관하여 특별한 청탁을 하게 하고 그에 대한 보수로 돈을 지급할 것을 내용으로 한 약정은 사회질서에 반하여 무효이다(대법원 1971.10.11. 71다1645). (○)

06. 급부의 상당성 여부를 판단할 필요 없이 수사기관에서 허위 진술을 해 주는 대가로 작성된 각서에 기한 급부의 약정은 민법 제103조 소정의 반사회질서행위로 무효이다. ()

대법원 2001.4.24 2000다71999 (○)

07. 형사사건에 관한 변호사의 성공보수약정은 그 체결시기를 불문하고 모두 선량한 풍속 기타 사회질서에 위배되어 무효이다. ()

대법원이 이 판결을 통하여 형사사건에 관한 성공보수약정이 선량한 풍속 기타 사회질서에 위배되는 것으로 평가할 수 있음을 명확히 밝혔음에도 불구하고 향후에도 성공보수약정이 체결된다면 이는 103조에 의하여 무효로 보아야 한다(대법원 2015.7.23., 2015다200111 전원합의체). (×)

08. 강제집행을 면할 목적으로 부동산에 허위의 근저당권설정등기를 경료하는 행위는 민법 제103조의 선량한 풍속 기타 사회질서에 위반한 사항을 내용으로 하는 법률행위에 해당한다. ()

강제집행을 면할 목적으로 부동산에 허위의 근저당권설정등기를 경료하는 행위는 103조의 선량한 풍속 기타 사회질서에 위반한 사항을 내용으로 하는 법률행위로 볼 수 없다(대법원 2004.5.28. 2003다70041). (×)

09. 주택매매계약에 있어서 매도인으로 하여금 양도소득세를 면탈케 할 목적으로 소유권이전등기는 3년 후에 넘겨 받기로 한 특약은 사회질서에 반하는 것으로서 무효이다. ()

주택매매계약에 있어서 매도인으로 하여금 주택의 보유기간이 3년 이상으로 되게 함으로써 양도소득세를 부과받지 않게 할 목적으로 매매를 원인으로 한 소유권이전등기는 3년 후에 넘겨 받기로 특약을 하였다고 하더라도, 그와 같은 목적은 위 특약의 연유나 동기에 불과한 것이어서 위 특약 자체가 사회질서나 신의칙에 위반한 것이라고는 볼 수 없다(대법원 1991.5.14. 91다6627). (×)

10. 소송사건에 증인으로 출석하여 증언하는 것과 연계하여 어떤 급부를 하기로 약정한 경우 그 급부의 내용이 전체적으로 통상 용인될 수 있는 수준을 넘는 것이라면, 그 약정은 민법 제103조가 규정한 반사회질서행위에 해당하여 전부가 무효이다. ()

소송사건에 증인으로 출석하여 증언하는 것과 연계하여 어떤 급부를 하기로 약정한 경우 전체적으로 통상 용인될 수 있는 수준을 넘는 급부를 하기로 한 것이라면, 그 약정은 반사회질서행위에 해당하여 전부가 무효이다. (○)

11. 행정기관에 진정서를 제출하여 상대방을 공지에 빠뜨린 다음 이를 취하하는 조건으로 거액의 급부를 제공받기로 약정한 경우, 민법 제103조 소정의 반사회질서의 법률행위에 해당한다. ()

대법원 2000.2.11. 99다56833 (○)

12. 피해 당사자가 공박, 경솔 또는 무경험의 상태에 있었다면, 그 상대방 당사자에게 폭리행위의 악의가 없었다 하더라도 불공정한 법률행위가 성립한다. ()

피해 당사자가 공박한 상태에 있었다고 하더라도 그 상대방 당사자에게 그와 같은 피해 당사자 측의 사정을 알면서 이를 이용하려는 의사, 즉 폭리행위의 악의가 없었다거나 또는 객관적으로 급부와 반대급부 사이에 현저한 불균형이 존재하지 아니한다면 104조에 규정된 불공정 법률행위는 성립하지 않는다(대법원 2002다38927). (×)

13. 어떠한 법률행위가 불공정한 법률행위에 해당하는지는 계약 체결 당시가 아니라 계약당사자 일방에게 손해가 발생한 때를 기준으로 판단하여야 한다. ()

공정 법률행위에 해당하는지는 법률행위가 이루어진 시점을 기준으로 약속된 급부와 반대급부 사이의 객관적 가치를 비교 평가하여 판단하여야 한다(대법원 2013.09.26. 2010다42075). (×)

14. 보험계약자가 다수의 보험계약을 통하여 보험금을 부정취득할 목적으로 보험계약을 체결한 경우 이러한 보험계약은 선량한 풍속 기타 사회질서에 위반하여 무효이다. ()

대법원 2009.5.28. 2009다12115 (○)

15. 부동산의 이중매매가 반사회적행위로서 무효가 된다는 법리는 이중으로 임대차계약을 체결한 경우에도 적용될 수 있다. ()

대법원 2013.6.27 2011다5813 (○)

16. 사회질서에 반하는 법률행위는 절대적으로 무효이고, 선의의 제3자에게 대항할 수 있으며, 그 무효인 법률행위에 따라 이행을 한 경우에는 이행된 급부의 반환을 청구할 수 있다. ()

불법의 원인으로 인하여 재산을 급여하거나 노무를 제공한 때에는 그 이익의 반환을 청구하지 못한다. (×)

17. 도박채무의 변제를 위하여 채무자로부터 부동산의 처분을 위임받은 도박채권자가 그 부동산을 제3자에게 매도한 경우, 그 제3자가 도박 채권자를 통하여 그 부동산을 매수한 행위는 그 제3자가 계약 당시 위와 같은 사정을 알지 못하였더라도 반사회질서의 법률행위로서 무효이다. ()

도박채무 부담행위 및 그 변제약정이 선량한 풍속 기타 사회질서에 위반되어 무효라 하더라도, 그 무효는 변제약정의 이행행위에 해당하는 위 부동산을 제3자에게 처분한 대금으로 도박채무의 변제에 충당한 부분에 한정되고, 위 변제약정의 이행행위에 직접 해당하지 아니하는 부동산 처분에 관한 대리권을 도박 채권자에게 수여한 행위 부분까지 무효라고 볼 수는 없으므로, 위와 같은 사정을 알지 못하는 거래 상대방인 제3자가 도박 채무자부터 그 대리인인 도박 채권자를 통하여 위 부동산을 매수한 행위까지 무효가 된다고 할 수는 없다(대법원 1995.7.14. 94다40147). (×)

제3절 의사표시

1. 비진의 의사표시

(1) 의의

표의자가 내심의 의사와 표시가 일치하지 않는다는 것을 알면서 하는 의사표시를 말한다.
진의아닌 의사표시, 심리유보라고도 한다.

(2) 요건

사법상의 의사표시가 존재하여야 한다. 따라서 공법상의 의사표시에는 제107조의 적용이 없다.
진의와 표시가 불일치하여야 하고, 불일치를 표의자가 인식하고 있어야 한다.

(3) 효과

① 원칙

표시주의이론에 따라 의사표시는 표시된 대로 효력이 발생한다(제107조 제1항 본문).
즉 상대방이 선의이며 무과실인 경우에는 유효하다.

② 상대방에 대한 효력

① 상대방이 표의자의 진의 아님을 알았거나(악의) 알 수 있었을 경우(과실)에는
그 의사표시는 무효로 한다(제107조 제1항 단서).

② 상대방의 악의 또는 과실유무에 대한 주장·증명책임은 무효를 주장하는 자에게 있다.

③ 제3자에 대한 효력

“선의의 제3자에게는 대항하지 못한다.”(제107조 제2항).

2. 통정허위표시

(1) 의의

허위표시란 상대방과 통정하여 하는 허위의 의사표시를 말하며,
‘통정허위표시’ 또는 ‘가장행위’, ‘통모’라고도 한다.

(2) 요건

① 표의자가 불일치를 인식하고 있어야 한다.

② 상대방과의 사이에 통정이 있어야 한다.

(3) 효과

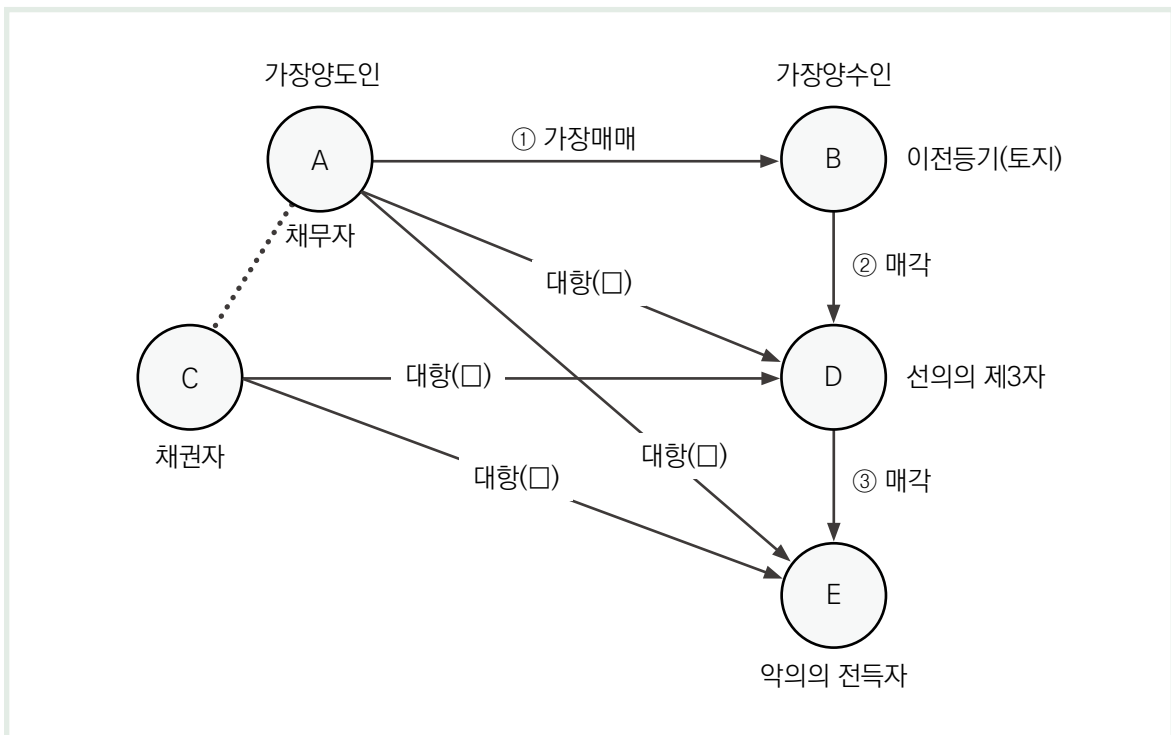
① 당사자 사이에는 언제나 무효이다(제108조 제1항).

② 허위표시 자체가 사회적 타당성에 반하는 것은 아니므로 불법원인급여(제746조)의 적용은 되지 않는다는
것이 판례이다.

③ 가장양도인의 채권자는 채권자취소권의 요건을 구비한 때에는 채권자취소권(제406조)을 행사할 수 있다.

(4) 제3자에 대한 효력

- ① 허위표시의 무효를 가지고 선의의 제3자에게는 대항하지 못한다(제108조 제2항).
선의에 대한 과실유무는 불문한다.
- ② 선의의 제3자에게 대항하지 못한 결과, 가장양도인에게 손해가 있을 때에는
가장양도인은 가장양수인에 대하여 불법행위를 이유로 한 손해배상청구권 또는
부당이득반환청구권을 행사할 수 있다.
- ③ 선의의 제3자로부터 악의의 전득자에게 양도되었을 때에도 대항하지 못한다.
- ④ 선의의 제3자가 당사자에게 무효를 주장하는 것은 무방하다.
- ⑤ 증명책임은 제3자가 악의라는 사실(무효)을 주장하는 자에게 있다.
- ⑥ 제3자라 함은 통정허위표시를 기초로 하여 새로운 법률상의 이해관계를 맺은 자를 말한다.



*** 통정허위표시에 있어서의 제3자에 해당하는 자**

- ㉠ 가장매매의 매수인으로부터 가등기를 취득한 자, 저당권을 설정 받은 자, 목적물의 임대차계약을 체결한 자
- ㉡ 가장저당권설정행위에 기한 저당권의 실행으로 경락 받은 자
- ㉢ 가장매매에 기한 대금채권의 양수인
- ㉣ 가장소비대차에 기한 채권의 양수인
- ㉤ 허위표시에 의한 채권을 가압류한 자
- ㉥ 가장매매의 매수인에 대한 압류채권자
- ㉦ 가장전세권설정에 기한 전세권저당권자
- ㉧ 파산자와는 독립한 지위에서 파산채권자 전체의 공동의 이익을 위하여 직무를 행하게 된 파산관재인

*** 통정허위표시에 있어서의 제3자에 해당하지 않는 자**

- ㉠ 가장매매에 기한 손해배상청구권의 양수인
- ㉡ 채권의 가장양도에 있어서의 채무자
- ㉢ 주식이 가장양도된 경우의 그 회사
- ㉣ 가장매매의 매수인으로부터 그 지위를 상속받은 자
- ㉤ 저당권을 가장포기한 경우의 후순위저당권자
- ㉥ 제3자를 위한 계약에서의 제3자(수익자)
- ㉦ 채권의 가장 양수인으로부터 '추심'을 위하여 채권을 양수한 자

3. 착오로 인한 의사표시

(1) 의 의

표시와 내심의 효과의사가 일치하지 않는 경우로서 그 불일치를 표의자 자신이 알지 못하는 것을 말한다.

(2) 착오의 유형

① 표시상의 착오

표시행위 자체를 잘못하여 의사와 표시가 불일치한 경우를 말한다(매매계약서에 69만원이라고 기재하려 했으나 오키하여 96만원으로 기재한 경우).

② 내용상의 착오

표시행위 자체에는 착오가 없으나 표시행위가 가지는 법적 의미(내용)에 관하여 착오가 있는 것을 말한다(평균 m^2 를 같은 단위로 생각하고 100평이라고 기재할 것을 $100m^2$ 로 기재한 경우).

③ 표시기관의 착오

본인의 착오와 동일하게 다룬다.

④ 전달기관의 착오

착오의 문제로 다루지 않으며 의사표시의 불도달의 문제로 다룬다(제111조).

⑤ 동기의 착오

의사표시를 하게 된 동기(연유)에 착오가 있는 경우를 말하며, 동기의 착오가 취소의 대상이 되는 착오인가에 대하여 다수설과 판례는 원칙적으로 제109조를 적용하지 않지만 표의자 본인의 보호와 거래안전의 조화를 위하여, 동기의 착오는 ㉠ 동기가 표시된 경우 ㉡ 표시되지 않아도 상대방으로부터 제공되었거나 유발된 경우에 한하여 제109조를 적용하여 취소할 수 있다고 한다.

(3) 효 과

① 원 칙

법률행위의 내용의 중요부분에 착오가 있는 때에는 취소할 수 있다(제109조 제1항).

중요부분에 관한 것이라는 점에 대하여는 표의자가 증명책임을 부담한다.

② 예외

㉠ 표의자에게 중대한 과실이 있는 경우에는 취소하지 못한다(제109조 제1항 단서).

㉡ 중대한 과실이란 표의자의 직업·행위의 종류·목적 등에 따라서 보통 기울여야 할 주의를 현저하게 결여한 것을 말한다.

㉢ 표의자에게 중대한 과실이 있다 하더라도 상대방이 표의자의 착오를 악용하는 경우에는 표의자는 그 의사표시를 취소할 수 있는 것으로 본다.

㉣ 중대한 과실이 있다는 점에 대한 증명책임을 표의자의 상대방이 부담한다.

4. 하자있는 의사표시



사기에 의한 의사표시

(1) 의 의

타인의 기망행위에 의하여 착오에 빠지고 그 결과로써 한 의사표시를 말한다.

(2) 성립요건

① 2단의 고의가 있어야 한다.

② 위법한 기망행위가 있어야 한다.

㉠ 적극적 기망이란 허위사실을 날조 또는 유포하는 것을 의미한다.

㉡ 소극적 기망이란 진실을 은폐하거나 또는 침묵을 지키는 것

(소극적 기망이 사기가 되기 위해서는 사기자에게 일정한 고지의무가 있었어야 한다)을 말한다.

㉢ 기망의 정도

기망행위는 사회통념상 위법성이 있다고 할 정도의 행위를 의미한다.

③ 인과관계가 있어야 한다.



강박에 의한 의사표시

(1) 의 의

타인의 강박행위에 의해 공포심에 빠지고, 그 해(害)를 피하기 위하여 한 의사표시를 말한다.

(2) 성립요건

- ① 2단의 고의가 있어야 한다.
- ② 위법한 강박행위가 있어야 한다.
 - ㉠ 강박에 의하여 의사결정의 자유가 배제될 정도에 이른 경우 그 의사표시는 무효이다.
 - ㉡ 불법행위를 한 자를 고발·고소하여 형사상 소추를 하겠다고 하는 경우에 대하여 다수설과 판례는 단순히 소추를 하겠다고 할 뿐이고 그것이 부정한 이익을 목적으로 하지 않을 때는 강박이 되지 않으나, 어떤 부정한 이익의 취득을 목적으로 하거나 목적이 정당하더라도 행위나 수단 등이 부당한 때에는 위법성이 있다고 한다.
- ③ 인과관계가 있어야 한다.



하자 있는 의사표시의 효과

(1) 상대방의 사기·강박의 경우

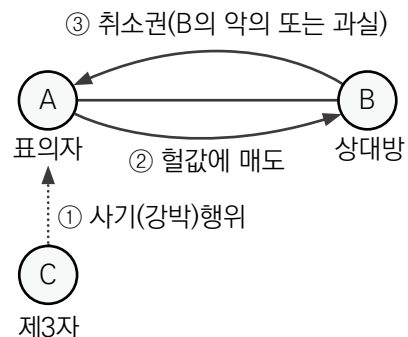
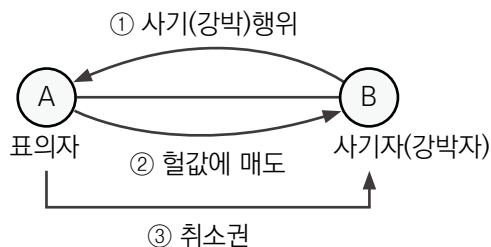
표의자는 언제든지 법률행위를 취소할 수 있다(제110조 제1항).

(2) 제3자의 사기·강박의 경우

- ① 상대방 없는 의사표시
표의자는 언제든지 그 법률행위를 취소할 수 있다.
- ② 상대방 있는 의사표시
 - ㉠ 상대방이 제3자의 사기나 강박을 알았거나(악의), 알 수 있었을 경우(과실)에 한하여 취소할 수 있다(제110조 제2항).
 - ㉡ 상대방의 악의·과실에 대한 증명책임은 표의자가 부담한다.

(3) 제3자와의 관계

선의의 제3자에게는 대항하지 못한다(제110조 제3항).



5. 의사표시의 효력발생

(1) 도달주의의 원칙

민법 제111조에서는 '상대방 있는 의사표시는 그 통지가 상대방에게 도달한 때에 효력이 생긴다.' 라고 규정함으로써 도달주의원칙을 취하고 있다.

- ① 도달의 개념은 사회통념상 요지할 수 있는 상태에 달한 때를 말한다.
- ② 의사표시의 연착 또는 불착은 표의자의 불이익으로 돌아간다.
- ③ 의사표시의 철회는 도달 전에 한하여 행할 수 있으며 늦어도 본래의 의사표시와 동시에 도달되어야 한다.
- ④ 발신 후 도달 전의 사정의 변화(표의자의 사망, 행위능력상실)는 의사표시의 효력에 영향을 미치지 아니한다(제111조 제2항).

* 민법상 발신주의 적용의 예

- ① 격지자 사이에서의 계약의 승낙의 통지(제531조)
- ② 제한능력자의 상대방의 최고에 대한 법정대리인의 확답(제15조)
- ③ 무권대리인의 상대방의 최고에 대한 본인의 확답(제131조)
- ④ 사원총회소집의 통지(제71조)
- ⑤ 채권자의 채무인수자에 대한 승인의 통지(제455조 제2항)

(2) 의사표시의 공시송달(제113조)

- ① 상대방 또는 상대방의 주소를 모르는 데 대하여 표의자의 과실이 없었어야 한다(무과실).
- ② 법원사무관 등이 공시송달할 서류를 보관하고, 그 사유를 법원게시판에 게시하며 법원게시판에 게시한 날로부터 2주일이 경과한 때에는 도달로 간주한다(민사소송법 제196조).

(3) 의사표시의 수령능력

- ① 민법상 모든 제한능력자는 의사표시의 수령능력이 없다(제112조).
따라서 의사표시를 제한능력자가 수령한 때에는 상대방은 도달을 주장하지 못한다.
- ② 제한능력자가 도달을 주장하는 것은 무방하며, 법정대리인이 의사표시의 도달을 인식한 때에는 표의자는 도달을 주장할 수 있다.



핵심 판례 정리

- 01.** 근로자가 회사의 경영방침에 따라 사직원을 제출하고 회사가 이를 받아들여 퇴직처리를 하였다가 즉시 재입사하는 형식을 취함으로써 근로자가 그 퇴직전후에 걸쳐 실질적인 근로관계의 단절이 없이 계속 근무하였다면 그 사직원제출은 비진의의사표시에 해당하고 회사 또한 진의 아님을 알고 있었다고 볼 수 있으므로 사직원제출은 무효이고, 퇴직의 효과는 생기지 아니한다.
- 02.** 진의 아닌 의사표시에 있어서의 '진의'란 특정한 내용의 의사표시를 하고자 하는 표의자의 생각을 말하는 것이지 표의자가 진정으로 마음 속에서 바라는 사항을 뜻하는 것은 아니므로 표의자가 의사표시의 내용을 진정으로 마음 속에서 바라지는 아니하였다고 하더라도 당시의 상황에서는 그것이 최선이라고 판단하여 그 의사표시를 하였을 경우에는 비진의 의사표시라고 할 수 없다.
[판례해설] 판례는 진심(본심)이 없다하여 진의(효과 의사)까지 없다고는 볼 수 없다고 한다.
- 03.** 표의자가 강박에 의하여서나마 증여를 하기로 하고 그에 따른 증여의 의사표시를 한 이상 증여의 내심의 효과의사가 결여된 것이라고 할 수는 없다.
- 04.** 진의 아닌 의사표시가 대리인에 의하여 이루어지고 그 대리인의 진의가 본인의 이익이나 의사에 반하여 자기 또는 제3자의 이익을 위한 배임적인 것임을 그 상대방이 알거나 알 수 있었을 경우에는 민법 제107조 제1항 단서의 유추해석상 그 대리인의 행위는 본인의 행위로 성립할 수 없으므로 본인은 대리인의 행위에 대하여 아무런 책임이 없다.
[판례해설] 대리인의 대리권남용에 관한 판례의 태도는 제107조 제1항 단서를 유추적용한다.
- 05.** 통정한 허위표시에 의하여 외형상 형성된 법률관계로 생긴 채권을 가압류한 경우, 그 가압류권자는 제108조 제2항의 제3자에 해당하고, 제3자는 선의이면 족하고 무과실은 요건이 아니다.
- 06.** 강제집행을 면할 목적으로 부동산에 허위의 근저당권설정등기를 경료하는 행위는 민법 제103조의 선량한 풍속 기타 사회질서에 위반한 사항을 내용으로 하는 법률행위로 볼 수 없다.
- 07.** 채무자의 법률행위가 통정허위표시인 경우에도 채권자취소권의 대상이 될 수 있다.
- 08.** 통정허위표시에 의한 매수인으로부터 부동산의 권리를 취득한 제3자는 선의로 추정되므로 제3자가 악의라는 사실의 증명책임은 그 무효를 주장하는 자에게 있다.
- 09.** 파산관재인은 그 허위표시에 따라 외형상 형성된 법률관계를 토대로 실질적으로 새로운 법률상 이해관계를 가지게 된 민법 제108조 제2항의 제3자에 해당한다.

- 10.** 증여를 하면서 증여세를 탈세하기 위하여 매매로 가장하여 소유권이전등기를 하는 것과 같이 허위표시(가장행위)뒤에 감추어진 행위를 은닉행위라 하고, 은닉행위라는 것만으로 당연히 무효라고 할 수 없다.
- 11.** 착오를 이유로 취소하는 자는 법률행위의 내용에 착오가 있었다는 사실과 함께 그 착오가 의사표시에 결정적인 영향을 미쳤다는 점, 즉 만약 그 착오가 없었더라면 의사표시를 하지 않았을 것이라는 점을 증명하여야 한다.
- 12.** 착오로 인하여 표의자가 경제적인 불이익을 입은 것이 아니라고 한다면 이를 법률행위 내용의 중요 부분의 착오라고 할 수 없다.
[판례해설] 가압류등기가 없다고 믿고 보증하였더라도 그 가압류가 원인무효인 것으로 밝혀진 경우, 착오를 이유로 보증계약을 취소할 수 없다.
- 13.** 동기의 착오가 법률행위의 내용의 중요부분의 착오에 해당함을 이유로 표의자가 법률행위를 취소하려면 그 동기를 당해 의사표시의 내용으로 삼을 것을 상대방에게 표시하고 의사표시의 해석상 법률행위의 내용으로 되어 있다고 인정되면 충분하고 당사자들 사이에 별도로 그 동기를 의사표시의 내용으로 삼기로 하는 합의까지 이루어질 필요는 없다.
- 14.** 토지매매에 있어서 시가에 관한 착오는 토지를 매수하려는 의사를 결정함에 있어 그 동기의 착오에 불과할 뿐 법률행위의 중요부분에 관한 착오라 할 수 없다.
- 15.** 당사자의 합의로 착오로 인한 의사표시 취소에 관한 민법 제109조 제1항의 적용을 배제할 수 있다.
- 16.** 토지의 현황·경계에 관한 착오는 법률행위의 중요부분에 관한 착오라고 볼 수 있다.
- 17.** 매매대상 토지 중 20~30평 가량만 도로에 편입될 것이라는 중개인의 말을 믿고 주택신축을 위하여 토지를 매수하였고 그와 같은 사정이 계약체결과정에서 현출되어 매도인도 이를 알고 있었는데 실제로는 전체면적의 약 30%에 해당하는 197평이 도로에 편입된 경우, 동기의 착오를 이유로 매매계약을 취소할 수 있다.
[판례해설] 매매대상 토지 중 도로편입 부분에 대한 매수인의 착오가 중대한 과실이라고 볼 수 없으므로 매매계약을 취소할 수 있다.
- 18.** 토지매매에서 특별한 사정이 없는 한 매수인에게 측량을 하거나 지적도와 대조하는 등의 방법으로 매매목적물이 지적도상의 그것과 정확히 일치하는지 여부를 미리 확인하여야 할 주의의무가 있다고 볼 수 없다.

19. 매도인이 매수인의 중도금 지급채무 불이행을 이유로 매매계약을 적법하게 해제한 후라도 매수인은 착오를 이유로 한 취소권을 행사하여 위 매매계약 전체를 무효로 할 수 있다.

[판례해설] 매도인의 해제권행사와 매수인의 착오로 인한 취소권행사에 관한 판례이다.

20. 상품의 선전 광고에 다소의 과장 허위가 수반되는 것은 그것이 일반 상거래의 관행과 신의칙에 비추어 시인될 수 있는 한 기망성이 결여된다.

[판례해설] 거래에 있어서 중요한 사항에 관하여 구체적 사실을 신의성실의 의무에 비추어 비난받을 정도의 방법으로 허위로 고지한 경우에는 기망행위에 해당한다.

21. 일반적으로 교환계약을 체결하려는 일방 당사자가 자기가 소유하는 목적물의 시가를 허위로 높은 가액을 시가라고 고지하였다 하더라도 이는 상대방의 의사결정에 불법적인 간섭을 한 것이라고 볼 수 없다.

[판례해설] 즉 위법성이 있는 기망이라 볼 수 없다.

22. 법률행위가 사기에 의한 것으로서 취소되는 경우에 그 법률행위가 동시에 불법행위를 구성하는 때에는, 취소의 효과로 생기는 부당이득반환청구권과 불법행위로 인한 손해배상청구권은 경합하여 병존하는 것이므로, 채권자는 어느 것이라도 선택하여 행사할 수 있지만 중첩적으로 행사할 수 없다.

23. 제3자의 사기행위로 인하여 피해자가 주택건설사와 사이에 주택에 관한 분양계약을 체결하였다고 하더라도 제3자의 사기행위 자체가 불법행위를 구성하는 이상, 제3자로서는 그 불법행위로 인하여 피해자가 입은 손해를 배상할 책임을 부담하는 것이므로, 피해자가 제3자를 상대로 손해배상청구를 하기 위하여 반드시 그 분양계약을 취소할 필요는 없다.

24. 강박에 의한 법률행위가 무효로 되기 위하여는 강박의 정도가 극심하여 의사표시자의 의사결정의 자유가 완전히 박탈된 상태에서 이루어져야 한다.

25. 상대방 있는 의사표시에 관하여 제3자가 사기나 강박을 한 경우에는 상대방이 그 사실을 알았거나 알 수 있었을 경우에 한하여 그 의사표시를 취소할 수 있으나, 상대방의 대리인 등 상대방과 동일시할 수 있는 자의 사기나 강박은 제3자의 사기·강박에 해당하지 아니한다.

26. 제110조 제2항에서 정한 제3자에 해당되지 아니한다고 볼 수 있는 자란 그 의사표시에 관한 상대방의 대리인 등 상대방과 동일시할 수 있는 자만을 의미하고, 단순히 상대방의 피용자이거나 상대방이 사용자책임을 져야 할 관계에 있는 피용자에 지나지 않는 자는 제3자에 해당한다.

27. 도달이라 함은 사회관념상 채무자가 통지의 내용을 알 수 있는 객관적 상태에 놓여 졌다고 인정되는 상태를 말한다.

28 우편물이 등기취급(또는 내용증명)의 방법으로 발송된 경우 반송되는 등 특별한 사정이 없는 한 그 무렵 수취인에게 배달되었다고 보아야 한다.

[판례해설] 그러나 보통우편으로 발송된 때에는 비록 반송된 사실이 없다 하더라도 우편제도상 당연히 도달된 것으로 추정되지 않는다는 것이 판례의 태도이다.



중요 지문 정리

01. 진의 아닌 의사표시가 대리인에 의하여 이루어진 경우, 그 대리인의 진의가 본인의 이익이나 의사에 반하여 자기의 이익을 위한 것임을 그 상대방이 알았거나 알 수 있었을 경우라면, 본인은 책임을 지지 않는다. ()

대법원 1999.1.15. 98다39602 (○)

02. 어떠한 의사표시가 비진의 의사표시로서 무효라고 주장하는 경우에 그 증명책임은 그 주장자에게 있다. ()

대법원 1992.5.22. 92다2295 (○)

03. 진의 아닌 의사표시에 있어서의 진의란 표의자가 진정으로 마음 속에서 바라는 사항을 뜻한다. 따라서 표의자가 의사표시의 내용을 진정으로 마음 속에서 바라지는 아니 하였지만 당시의 상황에서는 그것이 최선이라고 판단하여 한 의사표시도 진의 아닌 의사표시에 해당한다. ()

대법원 2015.08.27. 2015다211630 (×)

04. 표의자가 강박에 의하여 내심과 다른 의사표시를 한 경우라면, 강박에 의한 의사표시임을 이유로 취소할 수도 있겠지만, 일반적으로 진의 아닌 의사표시로서 무효가 된다. ()

비진의의사표시에 있어서의 진의란 특정한 내용의 의사표시를 하고자 하는 표의자의 생각을 말하는 것이지 표의자가 진정으로 마음속에서 바라는 사항을 뜻하는 것은 아니라고 할 것이므로, 비록 재산을 강제로 뺏긴다는 것이 표의자의 본심으로 참재되어 있었다 하여도 표의자가 강박에 의하여서나마 증여를 하기로 하고 그에 따른 증여의 의사표시를 한 이상 증여의 내심의 효과의사가 결여된 것이라고 할 수는 없다(대법원2002.12.27. 2000다47361). (×)

05. 법률상 또는 사실상의 장애로 자기 명의로 대출받을 수 없는 자를 위하여 대출금채무자로서의 명의를 빌려준 자에게 그와 같은 채무부담의 의사가 없는 것이라고는 할 수 없을 것이어서 그러한 의사표시를 비진의표시에 해당한다고 볼 수 없다. ()

대법원 1996.9.10. 96다18182 (○)

- 06.** 통정허위표시에 해당하여 무효인 계약에 기해 발생한 채권을 가압류한 자도 민법 제108조 제2항의 '제3자'에 해당한다. ()
- 07.** 민법 제108조 제2항에 규정된 '제3자'는 특별한 사정이 없는 한 선의로 추정된다. ()
- 08.** 통정허위표시의 무효는 선의의 제3자에게 대항하지 못하는데, 여기의 제3자는 선의이면 족하고 무과실은 요건이 아니다. ()
- 09.** 채무자의 법률행위가 통정허위표시인 경우에는 채권자취소권의 대상이 될 수 없다. ()
- 10.** 상대방과 통정한 허위의 의사표시는 무효이고 누구든지 그 무효를 주장할 수 있는 것이 원칙이나, 허위표시의 당사자 및 포괄승계인 이외의 자로서 허위표시에 의하여 외형상 형성된 법률관계를 토대로 실질적으로 새로운 법률상 이해관계를 맺은 선의의 제3자에 대하여는 허위표시의 당사자뿐만 아니라 그 누구도 허위표시의 무효를 대항하지 못한다 할 것이고, 따라서 위와 같은 선의의 제3자에 대한 관계에 있어서는 허위표시도 그 표시된 대로 효력이 있다. ()
- 11.** 무효인 법률행위가 그 법률행위가 성립한 당초부터 당연히 효력이 발생하지 않는 것이라 하더라도, 무효인 법률행위에 따른 법률효과를 침해하는 것처럼 보이는 위법행위나 채무불이행이 있다면 그 손해가 없다고 할 수 없으므로 손해배상을 청구할 수 있다. ()
- 12.** 매매계약 내용의 중요 부분에 착오가 있는 경우 매수인은 매도인의 하자담보 책임이 성립하는지와 상관없이 착오를 이유로 매매계약을 취소할 수 있다. ()
- 13.** 소취하합의의 의사표시는 법률행위의 내용의 중요 부분에 착오가 있더라도 민법 제109조에 따라 취소할 수는 없다. ()

대법원 2004.5.28 2003다70041 (○)

대법원 2006.3.10. 2002다1321 (○)

대법원 2004.5.28 2003다70041 (○)

대법원 1998.2.27. 97다50985 (×)

대법원 1996.4.26 94다12074 (○)

무효인 법률행위는 그 법률행위가 성립한 당초부터 당연히 효력이 발생하지 않는 것이므로, 무효인 법률행위에 따른 법률효과를 침해하는 것처럼 보이는 위법행위나 채무불이행이 있다고 하여도 법률효과를 침해에 따른 손해는 없는 것이므로 그 손해배상을 청구할 수는 없다(대법원 2003.3.28. 2002다72125). (×)

착오로 인한 취소 제도와 매도인의 하자담보책임 제도는 취지가 서로 다르고, 요건과 효과도 구별된다. 따라서 매매계약 내용의 중요 부분에 착오가 있는 경우 매수인은 매도인의 하자담보책임이 성립하는지와 상관없이 착오를 이유로 매매계약을 취소할 수 있다(대법원 2018.9.13. 2015다78703). (○)

법률행위의 내용의 중요 부분에 착오가 있는 경우, 소취하합의의 의사표시도 취소할 수 있다(대법원 2020.10.15. 2020다22752). (×)

- 14.** 하나의 법률행위의 일부분에만 취소사유가 있다고 하더라도 그 법률행위가 가분적이거나 그 목적물의 일부가 특정될 수 있다면, 그 나머지 부분이라도 이를 유지하려는 당사자의 가정적 의사가 인정되는 경우 그 일부만의 취소도 가능하다고 할 것이고, 그 일부의 취소는 법률행위의 일부에 관하여 효력이 생긴다. ()
- 15.** 법률행위 내용의 중요부분에 착오가 있는 경우 표의자는 그 의사표시를 취소할 수 있으나, 그 착오가 표의자의 중대한 과실에 기한 경우에는 취소가 허용되지 않는다. ()
- 16.** 상대방이 표의자의 착오를 알고 이를 이용한 경우에도 착오가 표의자의 중대한 과실로 인한 것이라면 표의자는 의사표시를 취소할 수 없다. ()
- 17.** 착오를 이유로 의사표시를 취소하는 자는 법률행위의 내용에 착오가 있었다는 사실과 함께 착오가 의사표시에 결정적인 영향을 미쳤다는 점, 즉 만일 그 착오가 없었더라면 의사표시를 하지 않았을 것이라는 점을 증명하여야 한다. ()
- 18.** 매도인이 매수인의 중도금 지급채무 불이행을 이유로 매매계약을 적법하게 해제하였다면, 매수인으로서의 착오를 이유로 한 취소권을 행사하여 매매계약 전체를 무효로 돌릴 수 없다. ()
- 19.** 동기의 착오가 법률행위의 내용의 중요부분의 착오에 해당함을 이유로 표의자가 법률행위를 취소하려면 그 동기를 당해 의사표시의 내용으로 삼을 것을 상대방에게 표시하고 의사표시의 해석상 법률행위의 내용으로 되어 있다고 인정되는 외에, 당사자들 사이에 별도로 그 동기를 의사표시의 내용으로 삼기로 하는 합의까지 이루어져야 한다. ()
- 20.** 상대방에 의하여 동기의 착오가 유발된 경우에는 그 의사표시를 취소할 수 있다. ()
- 21.** 아파트 분양자는 인근에 대규모의 공동묘지가 조성되어 있다면, 분양시 그러한 사실을 알려야 할 신의칙상 의무를 부담하고, 이를 고지하지 않을 경우 부작위에 의한 기망행위가 성립한다. ()

대법원 2002.9.10. 2002다21509 (○)

제109조 제1항 (○)

상대방이 표의자의 착오를 알고 이를 이용한 경우에는 착오가 표의자의 중대한 과실로 인한 것이라고 하더라도 표의자는 의사표시를 취소할 수 있다(대법원 2014.11.27. 2013다49794). (×)

대법원 2008.1.17. 2007다74188 (○)

매도인이 매수인의 중도금 지급채무 불이행을 이유로 매매계약을 적법하게 해제한 후라도 매수인으로서의 상대방이 한 계약해제의 효과로서 발생하는 손해배상책임을 지거나 매매계약에 따른 계약금의 반환을 받을 수 없는 불이익을 면하기 위하여 착오를 이유로 한 취소권을 행사하여 매매계약 전체를 무효로 돌리게 할 수 있다(대법원 1996.12.6. 95다24982). (×)

대법원 2000.5.12. 2000다12259 (×)

대법원 1997.8.26 97다6063 (○)

대법원 2007.6.1 2005다5812 (○)

22. 제3자에 의한 사기행위로 계약을 체결한 경우, 그 계약을 취소하지 않고도 제3자에 대하여 불법행위로 인한 손해배상청구를 할 수 있다. ()

대법원 1998.3.10 97다55829 (○)

23. 매도인이 매수인의 기망행위를 이유로 계약을 취소한 경우에 그 기망행위가 불법행위에 해당한다면 매도인은 부당이득반환과 불법행위로 인한 손해배상을 중첩적으로는 청구할 수 없다. ()

대법원 1993.4.27. 92다56087 (○)

24. 강박에 의한 법률행위는 의사표시자로 하여금 의사결정을 스스로 할 수 있는 여지를 완전히 박탈한 상태에서 의사표시가 이루어진 경우라 하더라도 취소하지 않는 한 효력이 있다. ()

의사표시자로 하여금 의사결정을 스스로 할 수 있는 여지를 완전히 박탈한 상태에서 의사표시가 이루어진 경우에는 무효이다(대법원 2002.12.10. 2002다56031). (×)

25. 상대방 있는 의사표시에 관하여 제3자가 사기나 강박을 한 경우에는 상대방이 그 사실을 알았거나 알 수 있었을 경우에 한하여 그 의사표시를 취소할 수 있으나, 상대방의 대리인의 사기나 강박은 여기서 말하는 제3자의 사기·강박에 해당하지 아니한다. ()

상대방의 대리인 등 상대방과 동일시할 수 있는 자의 사기나 강박은 제3자의 사기·강박에 해당하지 아니한다(대법원 1999.2.23. 98다60828). (○)

26. 상대방이 있는 의사표시는 상대방에게 도달한 때에 그 효력이 생기므로, 의사표시자가 그 통지를 발송한 후 사망하는 경우 그 의사표시는 효력이 발생하지 않는다. ()

의사표시자가 그 통지를 발송한 후 사망하거나 제한능력이 되어도 의사표시의 효력에 영향을 미치지 아니한다(제111조 제2항). (×)

27. 최고의 의사표시가 기재된 내용증명 우편물이 발송되고 반송되지 아니하였다면 특별한 사정이 없는 한 이는 그 무렵에 송달되었다고 보는 것이 판례의 태도이다. ()

대법원 2009.12.10. 2007두20140 (○)

28. 표의자가 과실 없이 상대방을 알지 못하거나 상대방의 소재를 알지 못하는 경우에는 의사표시는 민사소송법 공시송달의 규정에 의하여 송달할 수 있다. ()

제113조 (○)

29. 의사표시의 상대방이 의사표시를 받은 때에 제한능력자인 경우에는 의사표시자는 그 의사표시으로써 대항할 수 없다. 다만, 그 상대방의 법정대리인이 의사표시가 도달한 사실을 안 후에는 그러하지 아니하다. ()

제112조 (○)

30. 도달은 사회관념상 채무자가 그 통지를 현실적으로 수령하였거나 그 통지의 내용을 알았을 것까지 필요하다. ()

통지는 사회관념상 채무자가 통지의 내용을 알 수 있는 객관적 상태에 놓여졌을 때를 지칭하고, 그 통지를 채무자가 현실적으로 수령하였거나 그 통지의 내용을 알았을 것까지는 필요하지 않다(대법원 1983.8.23. 82다카439). (×)

제4절 법률행위의 대리

1. 대리권 일반

(1) 의의

타인이 본인을 위한 것을 표시하여 법률행위를 하거나 의사표시를 수령하여 그 효과가 직접 본인에게 귀속되는 제도를 말한다.

(2) 대리의 허용범위

- ① 의사표시를 요소로 하는 법률행위에 인정된다(114조).
- ② 가족법상의 신분행위(혼인, 인지, 입양, 파양, 유언), 불법행위, 사실행위, 준법률행위(의사의 통지와 관념의 통지는 대리를 유추적용 가능)는 대리가 부정된다.

(3) 임의대리권의 발생원인

- ① 상대방의 수령을 요하는 본인의 단독행위로 해석한다.
- ② 불요식행위(통상의 경우 위임장을 교부)이다.
- ③ 기본행위(위임, 고용, 도급, 조합)와는 구별하여야 한다.

(4) 임의대리권의 범위

본인의 수권행위에 의하여 결정되나 명확하지 않을 때에는 제118조를 적용한다.

* 권한이 분명하지 않은 대리인의 대리권(제118조)		
보존행위	무제한 가능	재산의 현상을 유지하는 행위로서 건물의 수선, 기한 도래의 채무변제, 소멸시효의 중단, 미등기부동산의 보존등기, 부패성 있는 물건의 처분행위 등
이용행위	권리나 물건의 성질을 변하지 않는 범위 내에서 가능	수익을 도모하는 행위로서 부동산의 임대차 설정행위, 금전의 이자부대여 등
개량행위		경제적 가치를 증대하는 행위로서 사용대차를 임대차로, 무이자소비대차를 이자부소비대차로 하는 행위 등
처분행위	불가능	매각행위, 담보설정행위(저당권 또는 전세권설정 등)

* 다만, 개량행위에 해당하는 것 중에서 본인의 예금을 인출하여 주식을 매입하는 행위 또는 본인의 농지를 대지로 지목을 변경하는 행위 등은 권리나 물건의 성질을 변하게 하는 행위로서 인정되지 않는다.

(5) 대리권의 제한

- ① 민법은 자기계약과 쌍방대리를 원칙적으로 금하나(제124조) 예외적으로 본인의 승낙 또는 채무의 이행(등기신청)의 경우에는 허용된다. 단, 다툼이 있는 채무의 이행, 기한 미도래의 채무이행, 대물변제 등은 허용하지 아니한다.
- ② 대리인이 수인일 때 각자대리가 원칙이나 공동대리의 예외를 인정한다.
- ③ 자기계약·쌍방대리의 금지규정과 공동대리의 제한에 위반한 경우에는 권한을 넘은 대리행위(제126조의 표현대리)로 본다. 따라서 본인의 추인이 있을 경우에는 유권대리였던 것으로 본다.

(6) 대리권의 소멸

공통 소멸사유(제127조)

- ① 본인의 사망
- ② 대리인의 사망
- ③ 대리인의 성년후견개시
- ④ 대리인의 파산

임의대리의 특유한 소멸사유(제128조)

- ① 수권행위의 철회
- ② 원인된 법률관계의 종료

(7) 현명주의

- ① 본인을 위한 것임을 표시하여야 하며(제114조), 현명의 방식(명시적 또는 묵시적, 서면 또는 구두)에는 제한이 없다. 상행위의 대리과 일상가사대리에서는 대리인의 현명을 요하지 아니한다.
- ② 현명하지 않은 대리행위는 대리인 자신을 위한 행위로 간주한다. 다만 상대방이 대리인으로서 한 것임을 알았거나 알 수 있었을 때에는 본인에게 그 효력이 발생한다(제115조).

(8) 대리행위의 하자

- ① 의사표시의 효력이 의사의 흠결, 사기, 강박 또는 어떤 사정을 알았거나 과실로 알지 못한 것으로 인하여 영향을 받을 경우에 그 사실의 유무는 대리인을 표준으로 결정한다(제116조 제1항).
- ② 특정한 법률행위를 위임한 경우에 대리인이 본인의 지시에 좇아 그 행위를 한때에는 본인은 자기가 안 사정 또는 과실로 인하여 알지 못한 사정에 관하여 대리인의 부지(不知)를 주장하지 못한다(제116조 제2항).

(9) 대리인의 능력

대리인은 행위능력자임을 요하지 아니한다(제117조). 따라서 본인은 대리인의 제한능력을 이유로 상대방에게 그 대리행위를 취소하지 못한다. 그러나 제한능력자는 본인과 기초적 내부관계를 발생시키는 행위(위임계약)를 취소할 수 있다.

2. 복대리

(1) 의의

복대리인이란 대리인이 자기의 이름과 책임으로 선임한 본인의 대리인을 말한다(제123조).

(2) 법률적 성질

- ① 복대리인은 본인의 대리인이며, 복대리인은 언제나 임의대리인이다.
- ② 복대리인은 대리인이 자기의 이름과 책임으로 선임한 자이다.

(3) 복임권

- ① 법정대리인은 언제든지 복임권이 있다(무과실책임).
다만, 부득이한 사유로 복대리인을 선임한 경우에는 그 책임이 경감된다(과실책임).
- ② 임의대리인은 원칙적으로 복임권이 없으나 예외적으로 본인의 승낙 또는 부득이한 사유가 있는 때에 한하여 복임권을 갖는다(과실책임). 임의대리인이 본인의 지명에 의하여 복대리인을 선임한 경우에는 책임이 경감된다. 즉, 본인이 지명한 자가 부적임 또는 불성실함을 알고도 본인에게 그 통지를 하지 않았거나 해임을 태만히 한 때가 아니면 책임지지 아니한다(제121조 제2항).

(4) 복대리인의 지위

- ① 복대리권은 대리권의 범위를 초과할 수 없다(제123조).
- ② 대리인의 대리권이 소멸하면 복대리인의 복대리권도 소멸한다.
- ③ 복대리인 선임 후에도 대리인의 대리권은 존속한다.
- ④ 본인에 대하여는 복대리인도 대리인과 동일한 지위를 가진다.
- ⑤ 복대리인의 복임권에 대하여는 임의대리와 같은 조건하에서 인정된다.

(5) 복대리권의 소멸사유

- ① 대리권 일반의 소멸원인에 의하여 소멸한다.
- ② 대리인의 대리권이 소멸하면 복대리인의 복대리권도 소멸한다.
- ③ 대리인과 복대리인 사이의 선임행위의 철회에 의하여서도 소멸한다.

3. 협의의 무권대리

(1) 계약의 무권대리

- ① 추인은 단독행위이며 형성권으로서, 상대방의 동의를 요하지 않는다. 본인은 추인거절권을 가진다.
- ② 추인의 의사표시는 상대방이나 무권대리인뿐만 아니라 무권대리행위로 인한 권리의 승계인에 대하여도 할 수 있으나, 무권대리인에 대해 추인한 경우에는 상대방이 추인이 있었던 사실을 알지 못한 때에는 추인의 효과를 주장하지 못한다(제132조).
- ③ 본인이 무권대리인이 한 계약의 내용을 변경하여 추인하거나 일부 추인한 경우에는 상대방의 동의가 있어야 추인의 효력이 발생한다.
- ④ 추인하면 무권대리행위는 계약한 때 소급하여 적법한 대리행위(유권대리)가 있는 것으로 된다.
추인의 소급효는 제3자의 권리를 해하지 못한다(제133조 단서).

- ⑤ 상대방은 상당한 기간을 정하여 본인에 대하여 추인여부의 확답을 구하는 최고를 할 수 있다.
그 기간 내에 본인이 확답을 발하지 않는 경우에는 추인을 거절한 것으로 본다.
악의의 상대방에게도 최고권을 인정한다.
- ⑥ 상대방은 계약 당시에 무권대리인임을 알지 못한 경우에(선의) 한하여
본인이 아직 추인하지 않고 있는 동안 본인이나 무권대리인에게 그 계약을 철회할 수 있다.
- ⑦ 무권대리인은 상대방의 선택에 따라서 이행 또는 손해배상(이행이익)의 책임을 져야 한다.
- ⑧ 무권대리인이 책임을 지기 위한 요건은 다음과 같다.
 - ㉠ 본인의 추인이 없을 것
 - ㉡ 상대방의 철회가 없을 것
 - ㉢ 상대방이 선의·무과실일 것
 - ㉣ 대리권을 증명할 수 없을 것
 - ㉤ 무권대리인이 행위능력자일 것

(2) 단독행위의 무권대리

- ① 상대방이 없는 단독행위의 무권대리는 언제나 확정적·절대적으로 무효이다.
- ② 상대방이 있는 단독행위의 무권대리는 계약에 있어서의 무권대리와 동일하게 다룬다.

4. 표현대리

(1) 제125조의 표현대리(대리권수여의 표시에 의한 표현대리)

- ① 대리권수여의 뜻을 본인이 상대방에게 표시하였으나 사실은 대리권을 주고 있지 않은 경우를 말하며,
본조(제125조)의 표현대리는 임의대리에만 적용된다.
- ② 타인에게 명의를 대여하는 것도 대리권수여의 표시가 될 수 있다는 것이 판례의 태도이다.
- ③ 제3자(무권대리인의 상대방)는 대리권의 부존재에 대하여 선의·무과실일 것.
이 때 상대방의 악의 또는 과실에 대한 증명책임은 본인에게 있다.
- ④ 본인은 무권대리인의 행위에 대하여 상대방에 대하여 책임이 있다(제125조 본문).

(2) 제126조의 표현대리(권한을 넘은 표현대리)

- ① 대리인이 권한 밖의 대리행위를 하였을 것.
- ② 대리인의 기본적인 대리권과 월권된 행위가 반드시 동종, 유사일 것을 요하지 않는다는 것이
판례의 태도이다.
- ③ 상대방은 선의 그리고 무과실일 것. 즉, 상대방이 대리권한이 있다고 믿고, 그러한 믿음에 정당한 이유가
있을 것을 요한다. 정당한 이유의 판단시점은 대리행위시를 기준으로 한다는 것이 판례의 태도이다.
- ④ 정당한 이유의 증명책임에 대하여는 견해의 대립이 있으나 상대방이 증명하여야 한다는 것이 판례이다.
- ⑤ 본인은 대리인의 권한 밖의 행위에 대하여 책임이 있다.
- ⑥ 본조는 임의대리 외에도 법정대리에도 적용된다. 일상가사대리권(日常家事代理權)도 법정대리권의
일종으로 그것을 기본대리권으로 하여 본조가 적용된다.

(3) 제129조의 표현대리(대리권소멸 후의 표현대리)

- ① 대리행위를 할 때에는 대리권이 존재하지 않을 것
- ② 상대방은 선의 그리고 무과실일 것. 본인이 상대방의 악의 또는 과실을 증명하여야 한다.
- ③ 본조는 임의대리와 법정대리 양자에 적용된다.

구 분	표현대리(제125조·제126조·제129조)
요건상의 공통점	㉠ 상대방은 선의·무과실이어야 한다. ㉡ 상대방의 악의 또는 과실의 증명책임은 본인에게 있다 (제126조의 표현대리는 상대방이 선의·무과실을 증명하여야 한다는 것이 판례). ㉢ 제3자란 대리행위의 상대방만을 의미한다. ㉣ 제125조의 표현대리는 임의대리에만 적용된다. 제126조·제129조의 표현대리는 임의대리, 법정대리의 양자 모두에 적용된다.
효과상의 공통점	㉠ 상대방은 최고권·철회권을 행사할 수 있다. ㉡ 본인은 추인권을 행사할 수 있다. ㉢ 본인은 표현대리인에 대하여 손해배상을 청구할 수 있다.



핵심 판례 정리

- 01.** 부동산의 소유자로부터 매매계약을 체결할 대리권을 수여받은 대리인은 특별한 사정이 없는 한 그 매매 계약에서 약정한 바에 따라 중도금이나 잔금을 수령할 권한도 있다고 보아야 하고, 매매계약의 체결과 이행에 관하여 포괄적으로 대리권을 수여받은 대리인은 특별한 사정이 없는 한 상대방에 대하여 약정된 매매대금지급기일을 연기하여 줄 권한도 가진다.
- 02.** 계약을 대리하여 체결하였던 대리인이 체결된 계약의 해제 등 일체의 처분권까지 가지고 있다고 볼 수는 없다.
- 03.** 대여금의 영수권한만을 위임받은 대리인이 그 대여금 채무의 일부를 면제하기 위하여는 본인의 특별수권이 필요하다.
- 04.** 매매위임장을 제시하고 매매계약을 체결하는 자는 특단의 사정이 없는 한 소유자를 대리하여 매매행위 하는 것이라고 보아야 한다.

- 05.** 임의대리인은 본인의 승낙이 있거나 부득이한 사유가 있지 아니하면 복대리인을 선임할 수 없는 것인 바, 아파트 분양업무는 그 성질상 분양위임을 받은 수임인의 능력에 따라 그 분양사업의 성공 여부가 결정되는 사무로서, 본인의 명시적인 승낙 없이는 복대리인의 선임이 허용되지 아니하는 경우로 보아야 한다.
- [판례해설]** 본인의 승낙은 본래 명시적이거나 묵시적이거나를 불문한다. 그러나 대리인의 능력을 중시하여 대리권이 수여된 경우에는 복대리인의 선임시 본인의 명시적인 승낙을 요한다.
- 06.** 무권대리행위의 추인은 일정한 방식이 요구되는 것은 아니나, 그 무권대리행위를 안 직후에 그것이 자기에게 효력이 없다고 이의를 제기하지 않았거나 상당기간 방치하였다고 하여 그 무권대리행위를 추인한 것으로 볼 수 없다.
- 07.** 무권대리인 乙이 甲으로부터 부동산을 상속받아 소유권이전등기이행의무를 이행하는 것이 가능하게 된 시점에서 자신이 소유자라고 하여 자신으로부터 부동산을 매수한 丙에게 원래 자신의 매매행위가 무권대리행위였다는 이유로 丙 앞으로 경료된 소유권이전등기가 무효의 등기라고 주장하여 그 등기의 말소를 청구하는 것(거절권 행사)은 금반언의 원칙이나 신의성실의 원칙에 반하여 허용될 수 없다.
- 08.** 대리권수여의 표시에 의한 표현대리에서의 본인에 의한 대리권수여의 표시는 반드시 대리권 또는 대리인이라는 말을 사용하여야 하는 것이 아니라 사회통념상 대리권을 추단할 수 있는 직함이나 명칭 등의 사용을 승낙 또는 묵인한 경우에도 대리권수여의 표시가 있는 것으로 볼 수 있다.
- 09.** 본인이 무권대리행위의 상대방에게 의무를 이행하겠다는 의사를 적극적으로 표명한 경우에는 특별한 사정이 없으면 무권대리행위를 추인한 것으로 본다.
- 10.** 부동산매도에 관하여 인장 및 등기서류를 교부한 때에는 일반적으로 대리권을 수여한 것으로 해석되나, 인감증명서만의 교부는 일반적으로 어떤 대리권을 부여하기 위한 행위라고 볼 수 없다.
- 11.** 처가 남편의 승낙 없이 그의 부동산에 대해 담보목적의 가등기를 설정하는 것은 일상가사대리권의 범위를 벗어난 것이지만, 일상가사대리권에도 제126조의 적용이 있으므로, 제3자(상대방)가 처에게 그 권한이 있다고 믿는 것에 정당한 이유가 있다면 남편은 그에 관해 책임을 져야 한다.
- 12.** 권한을 넘은 표현대리에 있어 대리인에게 그 권한이 있다고 믿을 만한 정당한 이유가 있는지 여부는 행위 당시를 기준으로 판단하여야 한다.
- 13.** 본인의 성명을 모용하여 자기가 마치 본인인 것처럼 기망하여 본인 명의로 직접 법률행위를 한 경우에는 특별한 사정이 없는 한 제126조의 표현대리는 성립될 수 없다.

14. 기본대리권이 등기신청행위라도 표현대리인이 그 권한을 초과하여 매매라는 사법행위를 한 경우에는 표현대리의 법리가 적용된다.

[판례해설] 기본행위가 공법행위인 경우에도 제126조의 표현대리가 성립될 수 있다.

15. 권한을 넘은 표현대리에 관한 민법 제126조의 규정에서 제3자라 함은 당해 표현대리행위의 직접 상대방이 된 자만을 지칭하는 것이다.

[판례해설] 표현대리의 규정에서의 제3자란 대리행위의 직접 상대방을 의미하는 것이며, 그로부터 전득한 자는 제3자에 해당하지 않는다.

16. 표현대리가 성립함으로써 본인에게 그 효과가 발생한다고 하여 무권대리의 성질이 유권대리로 전환되는 것은 아니다.

17. 비법인사단인 교회의 대표자는 총유물인 교회 재산의 처분에 관하여 교인총회의 결의를 거치지 아니하고는 이를 대표하여 행할 권한이 없다. 그리고 교회의 대표자가 권한 없이 행한 교회 재산의 처분행위에 대하여는 민법 제126조의 표현대리에 관한 규정이 준용되지 아니한다.

18. 표현대리행위가 성립하는 경우에 그 본인은 표현대리행위에 의하여 전적인 책임을 져야 하고, 상대방에게 과실이 있다고 하더라도 과실상계의 법리를 유추적용하여 본인의 책임을 경감할 수 없다.

19. 대리인이 대리권소멸 후 복대리인을 선임하여 복대리인으로 하여금 상대방과 사이에 대리행위를 하도록 한 경우에도, 상대방이 대리권소멸 사실을 알지 못하여 복대리인에게 적법한 대리권이 있는 것으로 믿었고 그와 같이 믿은 데 과실이 없다면 민법 제129조에 의한 표현대리가 성립할 수 있다.



중요 지문 정리

01. 대리인에 의하여 법률행위가 이루어진 경우 그 법률행위가 민법 제104조의 불공정한 법률행위에 해당하는지 여부를 판단함에 있어서 경솔과 무경험은 본인을 기준으로 하여 판단하고, 공박은 대리인의 입장에서 판단하여야 한다. ()

대법원 2002.10.22. 2002다38927 (×)

02. 대리권이 법률행위에 의하여 부여된 경우에는 대리인은 본인의 승낙이 있거나 부득이한 사유있는 때가 아니면 복대리인을 선임하지 못한다. ()

임의대리권의 복임권 (○)

03. 매매계약의 체결과 이행에 관하여 포괄적으로 대리권을 수여받은 대리인은 특별한 다른 사정이 없는 한 상대방에 대하여 약정된 매매대금 지급기일을 연기하여 줄 권한도 가진다. ()

대법원 1992.4.14 91다43107 (○)

04. 부동산의 소유자로부터 매매계약을 체결할 대리권을 수여받은 대리인은 특별한 다른 사정이 없는 한 그 매매계약에서 약정한 바에 따라 중도금이나 잔금을 수령할 수도 있다. ()

대법원 1994.2.8 93다39379 (○)

05. 어떠한 계약의 체결에 관한 대리권을 수여받은 대리인은 자신이 대리하여 체결하였던 계약의 해제 등 일체의 처분권과 상대방의 의사를 수령할 권한도 있다. ()

어떠한 계약의 체결에 관한 대리권을 수여받은 대리인이 수권된 법률행위를 하게 되면 그것으로 대리권의 원인인 법률관계는 원칙적으로 목적을 달성하여 종료하는 것이고, 법률행위에 의하여 수여된 대리권은 그 원인인 법률관계의 종료에 의하여 소멸하는 것이므로, 그 계약을 대리하여 체결하였던 대리인이 체결된 계약의 해제 등 일체의 처분권과 상대방의 의사를 수령할 권한까지 가지고 있다고 볼 수는 없다(대법원 2008.6.12. 2008다11276). (×)

06. 대리인이 본인을 위한 것임을 표시하지 아니하였는데, 상대방이 대리인으로서 한 것임을 알 수 있었을 때에는 본인에 대하여 효력이 생긴다. ()

제115조 단서 (○)

07. 대리인의 기망에 의해 의사표시를 하게 된 상대방은 본인의 선의, 악의나 과실의 유무를 묻지 않고 그 의사표시를 취소할 수 있다. ()

대리인의 기망행위는 본인의 기망행위로 본다. (○)

08. 부동산 입찰절차에서 동일한 물건에 관하여 1인이 이해관계를 달리하는 2인 이상의 대리인이 된 경우에도, 그 대리인이 한 입찰행위는 원칙적으로 유효하다. ()

부동산 입찰절차에서 동일한 물건에 관하여 1인이 이해관계를 달리하는 2인 이상의 대리인이 된 경우, 그 대리인이 한 입찰행위는 원칙적으로 무효이다(대법원 2004.2.13. 2003마44). (×)

- 09.** 무권대리행위의 추인은 무권대리인, 무권대리행위의 직접 상대방 및 그 무권대리행위로 인한 권리 또는 법률관계의 승계인에 대하여도 할 수 있다. ()
- 10.** 의사표시의 효력이 의사의 흠결, 사기, 강박 또는 어느 사정을 알았거나 과실로 알지 못한 것으로 인하여 영향을 받을 경우에 그 사실의 유무는 본인을 표준하여 결정한다. ()
- 11.** 권한을 정하지 아니한 대리인은 보존행위 및 대리의 목적인 물건이나 권리의 성질을 변하지 아니하는 범위 내에서 그 이용 또는 개량하는 행위만을 할 수 있다. ()
- 12.** 법정대리인은 그 책임으로 복대리인을 선임할 수 있으나 부득이한 사유로 인한 때에는 본인에게 대하여 책임지지 않는다. ()
- 13.** 대리인은 행위능력자임을 요하지 아니하고, 대리인이 수인인 때에는 원칙적으로 각자가 본인을 대리한다. ()
- 14.** 무권대리인은 상대방에게 계약을 이행하거나 손해를 배상할 책임이 있는데, 그 선택은 계약 상대방에게 있다. ()
- 15.** 표현대리가 성립하는 경우라도, 과실상계의 법리를 유추적용하여 본인의 책임을 경감할 수 있다. ()
- 16.** 무권대리인에 대하여 한 무권대리행위 추인은 아무런 효력이 없다. ()
- 17.** 무권대리행위가 범죄가 되는 경우에 대하여 그 사실을 알고도 장기간 형사고소를 하지 아니하였다 하더라도 그 사실만으로 묵시적인 추인이 있었다고 할 수는 없다. ()

대법원 1981.4.14. 80다2314 (○)

대리인을 표준으로 결정한다(제116조 제1항). (×)

제118조 (○)

법정대리인은 그 책임으로 복대리인을 선임할 수 있으나 부득이한 사유로 인한 때에는 본인에게 대하여 그 선임감독에 관한 책임만이 있다(제122조). (×)

제117조 (○)

제135조 제1항 (○)

표현대리행위가 성립하는 경우에 그 본인은 표현대리행위에 의하여 전적인 책임을 져야 하고, 상대방에게 과실이 있다고 하더라도 과실상계의 법리를 유추적용하여 본인의 책임을 경감할 수 없다(대법원 1996.7.12. 95다49554). (×)

무권대리행위의 추인에 특별한 방식이 요구되는 것이 아니므로 명시적인 방법만 아니라 묵시적인 방법으로도 할 수 있고, 그 추인은 무권대리인, 무권대리행위의 직접 상대방 및 그 무권대리행위로 인한 권리 또는 법률관계의 승계인에 대하여도 할 수 있다(대법원 1981.4.14. 80다2314). (×)

대법원 1998.2.10 97다31113 (○)

18. 대리행위의 표시를 하지 아니하고 단지 본인의 성명을 모용하여 자기가 마치 본인인 것처럼 기망하여 본인 명의로 직접 법률행위를 한 경우에는 특별한 사정이 없는 한 민법 제126조의 표현대리는 성립될 수 없다. ()

대법원 2002.6.28. 2001다49814 (○)

19. 비법인사단인 교회의 대표자는 총유물인 교회재산의 처분에 관하여 교인 총회의 결의를 거치지 아니하고는 이를 대표하여 행할 권한이 없는 것이지만, 교회의 대표자가 권한없이 행한 교회재산의 처분행위에 대하여는 민법 제126조의 표현대리에 관한 규정이 준용될 수 있다. ()

대법원 2009.2.12 2006다23312 (×)

20. 권한을 넘은 표현대리에 있어서 대리인에게 그 권한이 있다고 믿을 만한 정당한 이유가 있는지의 여부는 행위 당시를 기준으로 판단하여야 한다. ()

대법원 1981.12.8 81다322 (○)

21. 표현대리행위와 기본대리권은 동종 내지는 유사한 것이어야 하므로, 기본대리권이 등기신청행위임에도 표현대리인이 대물변제를 한 경우와 같이 전혀 별개의 행위를 한 경우에는 제126조의 표현대리가 성립할 수 없다. ()

대법원 1978.3.28 78다282 (×)

제5절 무효와 취소

1. 법률행위의 무효

(1) 무효와 취소의 구별

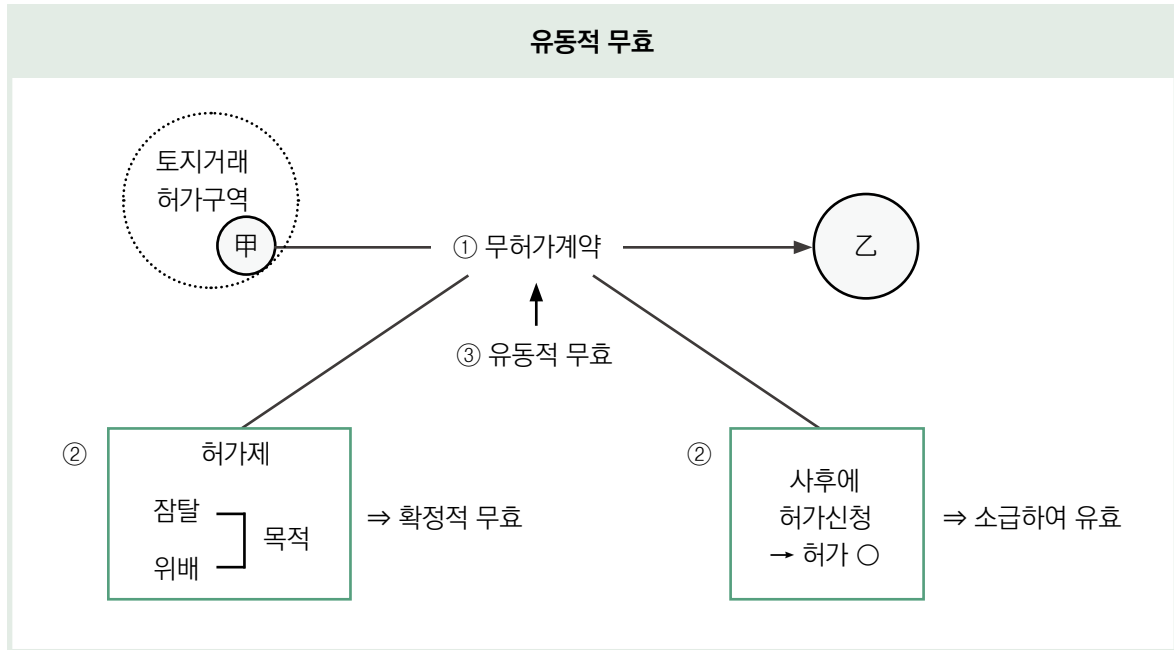
표 준	무 효	취 소
특정인의 주장	특정인의 주장을 필요로 하지 않고 당연 무효이다.	특정인(취소권자)의 주장이 있으면 소급하여 무효가 된다.
성립시의 효력	처음부터 효력이 없다.	취소를 하기 전에는 일단은 유효하다.
추인의 차이	새로운 법률행위로 본다. (비소급적 추인)	취소권의 포기과 같다.
시간의 경과와 보정(補正)	시간의 경과에 의하여 효력에 변동이 생기지 않고 언제나 무효이다.	① 일정한 시간이 경과하면 취소권이 소멸한다. ② 취소권을 행사하면 무효, 방치하면 유효가 된다.

(2) 무효인 법률행위와 취소할 수 있는 법률행위

무효인 법률행위	취소할 수 있는 법률행위
① 의사무능력자의 법률행위 ② 원시적 불능인 법률행위 ③ 강행법규(효력규정)에 위반한 법률행위(제105조) ④ 반사회질서의 법률행위(제103조) ⑤ 불공정한 법률행위(제104조)	① 제한능력자의 행위(제5조·제10조 등) ② 착오에 의한 의사표시(제109조) ③ 사기·강박에 의한 의사표시(제110조)
⑥ 비진의 의사표시(상대방의 악의, 과실)(제107조) ⑦ 통정허위표시(제108조)	
① ~ ⑤ : 절대적 무효(추인不可) ⑥⑦ : 상대적 무효(추인 가능)	① : 절대적 취소(추인 가능) ②③ : 상대적 취소(추인 가능)

(3) 유동적 무효

현재는 무효이나 추후에 허가 또는 추인이 있게 되면 소급하여 유효한 것으로 될 수 있는 것을 유동적 무효라고 한다.



① 확정적 무효사유

- ㉠ 불허가 처분을 받은 경우
- ㉡ 허가신청에 대한 이행거절의 의사를 명백히 한 경우
- ㉢ 처음부터 허가를 배제하거나 잠탈(潛脫)하는 내용의 계약을 체결한 경우 등

② 확정적 유효사유

- ㉠ 허가구역지정이 해제된 경우
- ㉡ 허가구역지정의 기간 만료 후 재지정이 없는 경우 등

(4) 무효행위의 추인

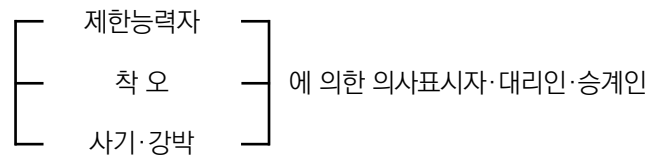
- ① 당사자가 법률행위의 무효임을 알고서 추인한 경우에는 그 때부터 새로운 법률행위를 한 것으로 본다. 따라서 무효행위의 추인은 소급효가 없는 것이 원칙이나(제139조), 예외적으로 당사자 사이에서만 소급효를 인정하는 것은 무방하다(통설).
- ② 절대적 무효에 해당하는 법률행위는 추인하여도 유효로 될 여지가 없다.
- ③ 추인은 명시적 또는 묵시적으로도 할 수 있다.

(5) 무효행위의 전환

- ① 무효행위의 전환이란 법률행위의 당사자가 본래 의욕한 대로 법률효과가 발생하지 못하는 무효인 행위이지만 그 행위가 다른 법률행위로서의 요건을 갖추고, 당사자가 그러한 무효를 알았다더라면 다른 법률행위를 하는 것을 의욕하였으리라고 인정될 때에는 다른 법률행위로서의 효력발생을 인정하는 것을 말한다(제138조).
- ② 불요식행위로서 무효인 것을 다른 요식행위로의 전환은 인정되지 않는다.

2. 법률행위의 취소

(1) 취소권자



- ① 임의대리인이 취소권을 행사하려면 본인으로부터 취소에 대한 별도의 수권이 있어야 한다.
- ② 특정승계인의 경우 취소권만의 승계는 인정되지 않는다.
- ③ 취소권은 형성권으로서 권리자의 일방적 의사표시로 하며, 취소의 상대방은 본래의 법률행위의 상대방이 된다.
- ④ 취소권의 행사는 특별한 방식을 요하지 않으며 명시적으로 하든 묵시적으로 하든 무방하다.

(2) 취소할 수 있는 법률행위의 추인

- ① 취소할 수 있는 법률행위를 취소하지 않겠다는 의사표시로서 상대방 있는 단독행위이며, 형성권이다.
- ② 추인은 취소의 원인이 종료한 후에 행사하여야 하며(법정대리인은 이러한 제한이 없다), 취소할 수 있는 법률행위임을 알고서 행사하여야 한다.
- ③ 일단 추인한 후에는 다시는 취소할 수 없으며 그 법률행위는 유효한 것으로 확정된다.

(3) 법정추인

- ① 추인이라고 인정할 수 있는 일정한 사실이 있을 때 법률상 당연히 추인이 있었던 것으로 간주되는 것을 말한다.
- ② 법정추인 역시 추인으로 간주되므로 다시는 취소권을 행사하지 못한다. 단, 이의의 유보가 없어야 한다.

법정추인사유	내 용
전부나 일부의 이행	취소권자가 이행한 경우 또는 취소권자가 상대방의 이행을 수령한 경우에는 추인으로 본다.
이행의 청구	취소권자가 상대방에게 청구한 경우에 한한다.
경 개	취소권자가 채권자 또는 채무자로서 경개계약을 체결한 경우를 말한다.
강제집행	취소권자가 채권자로 집행하는 경우 또는 취소권자가 채무자로서 집행을 받는 경우를 포함한다.
담보의 제공	취소권자가 채무자로서 담보를 제공하거나 채권자로서 담보의 제공을 받는 경우가 이에 해당한다.
취소할 수 있는 행위로 취득한 권리의 전부나 일부의 양도	취소권자가 취소할 수 있는 행위로 취득한 권리의 전부나 일부를 양도하는 것을 말한다.

(4) 취소권의 단기소멸

- ① 추인할 수 있는 날로부터 3년 내, 법률행위를 한 날로부터 10년 내에 취소권을 행사하지 아니하면 취소권은 소멸한다(제146조). 이 기간은 제척기간이라는 것이 판례의 태도이다.
- ② 취소권 행사로 인하여 발생하는 부당이득반환청구권은 10년의 소멸시효에 걸린다.
- ③ 두 기간 중 어느 것이든 먼저 경과하면 취소권은 소멸한다.

제6절 조건과 기한

1. 조건부 법률행위

(1) 정지조건과 해제조건

- ① 불능조건 + 정지조건 : 무효
- ② 불능조건 + 해제조건 : 유효(= 무조건)
- ③ 기성조건 + 정지조건 : 유효(= 무조건)
- ④ 기성조건 + 해제조건 : 무효

(2) 조건을 붙일 수 없는 법률행위(조건과 친하지 않은 법률행위)

- ① 가족법상 신분행위(혼인·이혼·입양·파양 등)
- ② 어음행위, 수표행위(기한과는 친함). 단 어음보증에는 조건을 허용한다.
- ③ 조건을 붙이는 것이 강행법규 또는 사회질서에 반하는 경우에는 허용되지 않는다.
따라서 불법조건은 조건만이 무효가 아니라 그 법률행위 전부를 무효로 한다.
- ④ 단독행위(해제·해지·취소·상계 등)는 조건을 붙일 수 없으나 채무면제나 유증은 상대방만을 유리하게 하는 것으로 허용되며 상대방의 동의가 있는 경우에는 조건을 붙이는 것이 허용된다.

(3) 조건성취와 불성취의 의제

- ① 조건의 성취로 불이익을 받을 당사자가 신의성실에 반하여 조건의 성취를 방해한 때에는 상대방은 그 조건이 성취된 것으로 주장할 수 있다(제150조 제1항).
- ② 조건의 성취로 이익을 받을 당사자가 신의성실에 반하여 조건을 성취시킨 때에는 상대방은 그 조건이 성취되지 않은 것으로 주장할 수 있다(제150조 제2항).

(4) 조건부 법률행위의 효력

- ① 조건부 권리의 의무자는 조건의 성부가 미정인 동안에 조건의 성취로 인하여 생길 상대방의 이익을 해하지 못한다(제148조).
- ② 조건부 권리·의무는 일반규정에 따라 이를 처분·상속·보존·담보로 할 수 있다(제149조).
- ③ 조건성취의 효력은 원칙적으로 소급효가 없으나 예외적으로 당사자의 특약으로 소급효를 부여할 수 있다. 기한도래의 효력에는 절대적으로 소급효를 부여할 수 없다.

2. 기한부 법률행위

(1) 기한을 붙일 수 없는 법률행위

기한을 붙일 수 없는 법률행위는 조건을 붙일 수 없는 법률행위와 대체로 같으며, 어음행위와 수표행위에는 시기를 붙이는 것이 허용된다.

(2) 기한의 이익

- ① 당사자의 특약이나 반대의 취지가 없는 한 기한의 이익은 채무자의 이익을 위한 것으로 추정한다
(제153조 제1항).
- ② 기한의 이익은 포기할 수 있으나 상대방의 이익을 해하지 못한다.
- ③ 기한의 이익이 상대방을 위해서 존재하는 경우에는 상대방의 손해를 배상하고 포기할 수 있다.

(3) 기한이익의 상실

- ① 채무자가 담보를 손상·감소·멸실하게 한 때(제388조 제1항), 인적·물적 담보를 불문하며,
채무자의 고의·과실을 요하지 아니한다.
- ② 채무자가 담보제공의무를 이행하지 않은 때(제388조 제2항)
- ③ 채무자가 파산한 때(채무자회생 및 파산에 관한 법률)

* 소급효 있는 행위와 소급효 없는 행위

소급효 있는 행위	소급효 없는 행위
① 실종선고의 취소(제29조) ② 제한능력자의 법률행위의 취소 ③ 착오·사기·강박에 의한 의사표시의 취소(제109조·제110조) ④ 무권대리행위의 추인(제133조) ⑤ 소멸시효의 완성(제167조) ⑥ 선택채권에 있어서의 선택(제386조) ⑦ 계약의 해제(제548조) ⑧ 상계(제493조)	① 미성년자의 영업허락의 취소(제8조) ② 성년후견종료의 심판(제11조) ③ 한정후견종료의 심판(제14조) ④ 부재자재산관리명령의 취소(제22조) ⑤ 법인설립허가의 취소(제38조) ⑥ 무효행위의 추인(제139조) ⑦ 기한부 법률행위의 효력(제152조) ⑧ 공유물의 분할(제269조) ⑨ 계약의 해지(제550조) ⑩ 조건의 성취(제147조)



01. 토지거래허가구역내의 일정한 거래계약은 관할 관청의 허가를 받아야만 그 효력이 발생하고 허가를 받기 전에는 물권적 효력은 물론 채권적 효력도 발생하지 아니하여 무효라고 보아야 할 것인바, 다만 허가를 받기 전의 거래계약이 처음부터 허가를 배제하거나 잠탈하는 내용의 계약일 경우에는 확정적으로 무효로서 유효화될 여지가 없으나 이와 달리 허가받을 것을 전제로 한 거래계약일 경우에는 일단 허가를 받으면 그 계약은 소급하여 유효한 계약이 되고 이와 달리 불허가가 된 때에는 무효로 확정되므로 허가를 받기까지는 유동적 무효의 상태에 있다고 보는 것이 타당하므로 허가받을 것을 전제로 한 거래계약은 허가받기 전의 상태에서는 거래계약의 채권적 효력도 전혀 발생하지 않으므로 권리의 이전 또는 설정에 관한 어떠한 내용의 이행청구도 할 수 없으나 일단 허가를 받으면 그 계약은 소급해서 유효화되므로 허가 후에 새로이 거래계약을 체결할 필요는 없다.
02. 유동적 무효상태에서는 계약이 효력 있는 것으로 완성될 수 있도록 서로 협력할 의무가 있으므로, 이러한 의무에 위반하여 허가신청절차에 협력하지 않는 당사자에 대하여 상대방은 협력의무의 이행을 소송으로써 구할 수 있다.
03. 허가받기 전의 매매계약이 유동적 무효라고 하여 매매계약에 관한 계약금을 교부한 상태에 있는 계약당사자 일방이 언제든지 계약의 무효를 주장하여 부당이득으로 계약금의 반환을 구할 수는 없다.
04. 유동적 무효 상태 하에서 당사자 일방이 허가신청협력의무의 이행거절의사를 명백히 표시한 경우에는 계약의 유동적 무효상태가 더 이상 지속한다고 볼 수는 없고 그 계약관계는 확정적으로 무효가 된다.
05. 무허가계약은 유동적 무효이나, 그 토지거래가 당사자의 비진의표시, 허위표시, 착오 또는 사기, 강박에 의하여 이루어진 경우에는, 이들 사유에 의하여 그 거래의 무효 또는 취소를 주장할 수 있는 당사자는 그러한 거래허가를 신청하기 전 단계에서 이러한 사유를 주장하여 거래허가신청 협력에 대한 거절의사를 일방적으로 명백히 함으로써 그 계약을 확정적으로 무효화시키고 자신의 거래허가절차에 협력할 의무를 면할 수 있다.
06. 유동적 무효상태에서도 당사자 사이의 매매계약은 매도인이 계약금의 배액을 상환하고 계약을 해제함으로써 적법하게 해제된다.
07. 허가구역 지정기간 중에 토지거래허가를 받지 아니하고 토지거래계약을 체결한 후 허가구역 지정해제 등이 된 때에는 그 토지거래계약이 허가구역 지정이 해제되기 전에 확정적으로 무효로 된 경우를 제외하고는, 더 이상 토지거래허가를 받을 필요가 없이 확정적으로 유효로 된다.

- 08.** 토지거래허가구역에서 최종 매수인이 자신과 최초 매도인을 매매당사자로 하는 토지거래허가를 받아 자신 앞으로 소유권이전등기를 경료하였다더라도 그러한 이전등기는 적법한 토지거래허가 없이 경료된 등기로서 무효이다.
- 09.** 무효행위의 추인은 무효행위를 사후에 유효로 하는 것이 아니라 새로운 의사표시에 의하여 새로운 행위가 있는 것으로 하여 그 때부터 유효하게 되는 것이므로, 원칙적으로 소급효가 인정되지 않는다.
- 10.** 불공정한 법률행위로서 무효인 경우에는 추인에 의하여 무효인 법률행위가 유효로 될 수 없다.
- 11.** 법률행위의 취소는 상대방에 대한 의사표시로 하여야 하나, 법률행위의 취소를 당연한 전제로 한 소송상의 이행청구나 이를 전제로 한 이행거절 가운데는 취소의 의사표시가 포함되어 있다고 볼 수 있다.
- 12.** 조건의 성취로 인하여 불이익을 받을 당사자가 신의성실에 반하여 조건의 성취를 방해한 경우, 조건이 성취된 것으로 의제되는 시점은 이러한 신의성실에 반하는 행위가 없었더라면 조건이 성취되었으리라고 추산되는 시점이다.
- 13.** 정지조건부 법률행위에 있어서 조건이 성취되었다는 사실은 이에 의하여 권리를 취득하고자 하는 측에서 그 증명책임이 있다.



중요 지문 정리

- 01.** 무효인 법률행위가 다른 법률행위의 요건을 구비하고 당사자가 그 무효를 알았더라면 다른 법률행위를 하는 것을 의욕하였으리라고 인정될 때에는 다른 법률행위로서 효력을 가진다. ()
- 무효행위의 전환(제138조) (○)
- 02.** 무효인 법률행위는 처음부터 무효라는 것이 확정되어 있으나 취소할 수 있는 법률행위는 취소권자의 주장이 있어야 비로소 그 효력이 없게 된다. ()
- 타당한 기술이다. (○)
- 03.** 무효인 법률행위에 따른 법률효과를 침해하는 것처럼 보이는 위법행위나 채무불이행이 있다고 하여도 법률효과의 침해에 따른 손해는 없는 것이므로 그 손해배상을 청구할 수는 없다. ()
- 대법원 2003.3.28 2002다72125 (○)
- 04.** 무효인 법률행위는 어느 경우에도 추인을 허용하지 않으나, 취소할 수 있는 법률행위는 추인을 허용한다. ()
- 상대적 무효는 추인할 수 있다. (×)

- 05.** 법률행위의 일부분이 무효인 때에는 그 전부를 무효로 하지만, 그 무효 부분이 없더라도 법률행위를 하였을 것이라고 인정될 때에는 나머지 부분은 무효가 되지 아니한다. ()
- 06.** 무효인 법률행위는 당사자가 무효임을 알고 추인한 때에는 소급하여 유효한 행위로 되는 것이 원칙이다. ()
- 07.** 법정추인으로서의 '이행의 청구' 는 취소권자가 상대방으로부터 청구를 당한 경우도 포함한다. ()
- 08.** 취소권의 단기소멸(제146조)에서의 기간은 소멸시효에 해당한다는 것이 판례의 태도이다. ()
- 09.** 조건부 법률행위에 있어 조건의 내용 자체가 불법적인 것이어서 무효일 경우 또는 조건을 붙이는 것이 허용되지 아니하는 법률행위에 조건을 붙인 경우 그 조건만을 분리하여 무효로 할 수 있다. ()
- 10.** 단독행위는 어떠한 경우에도 조건을 붙이는 것을 인정하지 않는다. ()
- 11.** 토지거래허가제도가 폐지되지 않고 존치되어 있는 이상, 토지거래허가구역 지정기간 중에 허가구역 안의 토지에 관하여 체결된 매매계약은 허가구역 지정해제 등이 된 이후에도 여전히 허가를 받아야 유효로 된다. ()
- 12.** 무효인 법률행위는 당사자가 무효임을 알고 추인할 경우 새로운 법률행위를 한 것으로 간주할 뿐이고 소급효가 없는 것이므로 무효인 가등기를 유효한 등기로 전용기로 한 약정은 그때부터 유효하고 이로써 위 가등기가 소급하여 유효한 등기로 전환될 수 없다. ()
- 13.** 당사자가 불확정한 사실이 발생한 때를 이행기한으로 정한 경우, 그 사실이 발생한 때는 물론 그 사실의 발생이 불가능하게 된 때에도 그 이행기한은 도래한 것으로 보아야 한다. ()
- 14.** 해제조건이 법률행위 당시에 이미 성취할 수 없는 것인 경우 그 법률행위는 무효로 한다. ()
- 15.** 기한의 이익은 상대방의 이익을 해하지 않는 한 포기할 수 있다. ()

제137조 (○)

무효행위의 추인은 소급효가 없는 것이 원칙이다(제139조). (×)

법정추인으로서의 '이행의 청구' 는 취소권자가 상대방에 대하여 하는 경우만을 말한다. (×)

소멸시효가 아니라 제척기간에 해당한다는 것이 판례이다. (×)

조건부 법률행위에 있어 조건의 내용 자체가 불법적인 것이어서 무효일 경우 또는 조건을 붙이는 것이 허용되지 아니하는 법률행위에 조건을 붙인 경우 그 조건만을 분리하여 무효로 할 수는 없고 그 법률행위 전부가 무효로 된다. (×)

상대방만을 유리하게 하는 단독행위인 채무면제나 유증에는 조건을 붙일 수 있다. (×)

허가구역의 지정이 해제된 때에는 유동적 무효인 계약은 모두 확정적 유효가 된다. (×)

대법원 1992.5.12 91다26546 (○)

대법원 2002.3.29 2001다41766 (○)

조건이 법률행위 당시에 이미 성취할 수 없는 것인 경우에는 그 조건이 해제조건이면 조건 없는 법률행위로 하고 정지조건이면 그 법률행위는 무효로 한다. (×)

제153조 (○)

◎ 단원별 출제경향

구 분	28회	29회	30회	31회	32회	33회	34회
기간과 소멸시효	2	3	3	3	2	2	2

제1절 기간

(1) 자연적 계산법

- ① 정확하나 불편한 단점이 있으며 주로 단기간에 적용한다.
- ② 시·분·초를 단위로 하는 계산법으로서 즉시로부터 기산하여 정해진 시·분·초가 만료한 때를 만료점으로 한다(제156조).
- ex) 오전 10시 15분부터 10시간은 오후 8시 15분이 만료점이다.

(2) 역법적 계산법

- ① 부정확하나 편리하다는 장점이 있으며 주로 장기간에 적용한다.
- ② 일·주·월·년을 단위로 하는 계산법이다.

기산점	① 초일불산입의 원칙이 적용된다(제157조). ② 초일산입의 경우 ㉠ 기간이 오전 0시부터 시작하는 경우(제157조) ㉡ 연령계산의 경우(제158조) ① 2023년 3월 5일 오후 2시부터 10일간이라면 3월 15일 24시에 기간이 만료한다(기산점은 3월 6일 오전 0시). ② 앞으로 도래할 9월 5일로부터 일주일이라면 9월 11일 24시에 기간이 만료한다(9월 5일 오전 0시부터 기산하므로 초일을 산입한 결과). ③ 2004년 7월 14일 오전 11시에 출생한 자의 성년이 되는 시기는 2023년 7월 14일 오전 0시에 성년이 된다(연령계산은 초일을 산입한 결과).
-----	--

만료점	① 기간을 일·주·월·년으로 정한 때에는 기간 말일의 종료로 기간이 만료한다(제159조). ② 주 월 년의 처음으로부터 기산하지 않는 때에는 최후의 주 월 년에서 기산일에 해당한 날의 전일로 기간이 만료한다(제160조 제2항). ■ 2월 13일에 앞으로 1개월이라고 한 때에는, 기산일은 2월 14일이며 그로부터 1개월 후인 3월 14일의 전일, 즉 3월 13일로 기간이 만료한다. ③ 월·년으로 정한 경우에 최종의 월에 해당일이 없는 때에는 그 월의 말일로 기간이 만료한다(제160조 제3항). ■ 1월 31일 오전10시부터 1개월이라면 2월 31일 24시가 만료점이지만, 2월은 28일(윤년의 경우에는 29일)까지 뿐이므로 2월 28일 24시로 기간이 만료한다. ④ 기간의 말일이 토요일 또는 공휴일에 해당하는 때에는 기간은 그 익일로 만료한다. ⑤ 일정한 기산일로부터 거꾸로 소급하여 계산하는 기간의 역산의 경우에도 민법의 기간계산의 방법이 준용된다(다수설·판례). ■ 사단법인의 사원총회 소집일시가 2023년 9월 16일 오전 10시라고 한다면, 초일불산입의 원칙에 의해 16일을 뺀 15일부터 역으로 기산하여 1주일 전날인 9월 8일 자정까지는 발신을 완료하여야 한다(사단법인의 사원총회 소집의 통지는 발신주의).
-------------------	--

제2절 소멸시효

1. 시효의 의의

- ① 일정한 사실상태가 일정한 기간 동안 계속됨으로써 권리의 취득 또는 소멸을 일어나게 하는 법률요건으로서 취득시효(물권편에서 규정)와 소멸시효(민법총칙에서 규정)가 있다.
- ② 재산권에 대한 제도로써 강행규정성을 띠고 있다.

2. 소멸시효에 걸리지 않는 재산권

(1) 점유권

(2) 소유권 및 소유권에 의존하는 권리

- ① 상린권(제215조 이하)
- ② 공유물분할청구권
- ③ 대리권

(3) 담보물권

피담보채권이 소멸시효로 인해 소멸하면 담보물권은 따라서 소멸하며, 담보물권이 독립하여 소멸시효에 걸리지는 않는다.

(4) 소유권

(5) 신분권

(6) 물건적 청구권

소유권에 기한 물건적 청구권은 소멸시효에 걸리지 않으나, 제한물권에 기한 물건적 청구권은 소멸시효에 걸린다는 것이 판례이다.

(7) 형성권

형성권은 소멸시효가 아니라 제척기간에 걸린다는 것이 판례이다.

(8) 인격권

3. 소멸시효기간

(1) 보통의 채권: 10년(제162조 제1항), 단, 채권 및 소유권 이외의 재산권은 20년

(2) 상행위로 인한 채권: 5년

(3) 근로기준법상의 임금채권: 3년

(4) 3년의 단기소멸시효에 걸리는 권리(제163조)

- ① 이자, 부양료, 급료, 사용료 기타 1년 이내의 기간으로 정한 금전 또는 물건의 지급을 목적으로 한 채권(1년 이내의 정기로 지급되는 채권, 1개월 단위로 지급되는 집합건물의 관리비채권 등)
- ② 의사, 조산사, 간호사 및 약사의 치료, 근로 및 조제에 관한 채권
- ③ 도급받은 자, 기사 기타 공사의 설계 또는 감독에 종사하는 자의 공사에 관한 채권
- ④ 변호사, 변리사, 공증인, 공인회계사 및 법무사에 대한 직무상 보관한 서류의 반환을 청구하는 채권
- ⑤ 변호사, 변리사, 공증인, 공인회계사 및 법무사의 직무에 관한 채권
- ⑥ 생산자 및 상인이 판매한 생산물 및 상품의 대가
- ⑦ 수공업자 및 제조업자의 업무에 관한 채권

(5) 1년의 단기소멸시효에 걸리는 권리(제164조)

- ① 여관, 음식점, 대석(貸席), 오락장의 숙박료, 음식료, 대석료, 입장료, 소비물의 대가 및 체당금(替當金)의 채권
- ② 의복, 침구, 장구(葬具) 기타 동산의 사용료의 채권
- ③ 노역인·연예인의 임금 및 그에 공급한 물건의 대금채권
- ④ 학생 및 수업자의 교육, 의식, 유숙에 관한 교주(校主), 숙주(塾主), 교사의 채권

(6) 판결 등으로 확정된 채권

- ① 판결에 의해서 확정된 채권은 단기의 소멸시효에 해당하는 것이라도 그 소멸시효는 10년이다
(제165조 제1항).
- ② 파산절차에 의하여 확정된 채권 및 재판상의 화해 또는 조정 기타 판결과 동일한 효력이 있는 것에
의하여 확정된 채권도 10년이다(제165조 제2항).

4. 소멸시효의 기산점

(1) 의 의

소멸시효는 권리를 행사할 수 있는 때로부터 진행한다(제166조 제1항).

(2) 각종 권리의 소멸시효의 기산점

확정기한부 채권	기한이 도래한 때, 기한이 연기된 경우에는 그 연기된 기한이 새로운 기산점이 된다.
불확정기한부 채권	① 객관적으로 그 기한이 도래한 때부터 소멸시효가 진행한다. ② 채권자의 기한도래사실에 대한 知不知는 불문한다.
기한의 정함이 없는 채권	채권이 성립한 때로부터 소멸시효가 진행한다.
청구 또는 해지통고 후 상당기간이나 일정기간이 지나야 청구할 수 있는 권리	그 기간(유예기간)이 경과한 때로부터 소멸시효가 진행한다.
동시이행의 항변권이 붙은 채권	이행기의 도래시부터 진행한다.
정지조건부 권리	조건성취시부터 소멸시효가 진행한다.
부작위채권	위반행위시부터 소멸시효가 진행한다.
채무불이행으로 인한 손해배상청구권	학설은 대립이 있으며, 판례는 채무불이행시부터 소멸시효가 진행된다고 한다. 다만, 시효기간은 본래 채권의 시효기간과 같다(통설·판례).
구 상 권	보증인의 구상권은 그 권리가 발생되어 행사할 수 있는 때로부터 소멸시효가 진행한다.

5. 소멸시효의 중단

(1) 청구

① 재판상의 청구(제170조)

- ㉠ 訴의 제기를 의미한다. 상대방이 제기한 訴에 대하여 응소하는 경우를 포함한다.
- ㉡ 청구는 민사재판이어야 하고 행정소송·행정심판·형사재판의 경우에는 중단사유가 되지 않는다.
시효중단의 효력이 발생하는 시기는 訴 제기시로 본다.
- ㉢ 訴의 기각·각하·취하의 경우에는 중단의 효력이 없으나 6월 내에 다시 재판상의 청구, 파산절차참가, 압류, 가압류, 가처분을 행한 때에는 최초의 訴 제기시에 중단된 것으로 본다.

② 파산절차참가(제171조)

③ 지급명령신청(제172조)

④ 화해를 위한 소환(제173조)

⑤ 임의출석(제173조)

⑥ 최고(제174조)

최고 후 6월 내에 재판상의 청구 등 보다 강력한 방법을 취하지 않으면 시효중단의 효력이 없다.

(2) 압류·가압류·가처분(제168조 제2호)

(3) 승인(제168조 제3호)

- ① 시효의 이익을 받을 당사자가 시효로 인해 권리를 잃을 자에 대하여 상대방의 권리를 인정한다는 일방적인 관념의 통지에 해당한다. 승인을 할 수 있는 자는 시효이익을 받을 자와 그 대리인이다.
- ② 일정한 방식을 요하지 않으며 채권자의 대리인에 대해서도 행할 수 있다.
- ③ 승인을 함에 있어서는 상대방의 권리에 관하여 처분의 능력이나 권한이 있음을 요하지 아니한다(제177조).
- ④ 승인은 시효의 완성 전에만 있을 수 있다.

* 시효의 중단은 당사자 및 승계인 사이에서만 그 효력이 발생한다(제169조).

6. 소멸시효의 정지

(1) 제한능력자의 권리의 경우

소멸시효의 기간만료 전 6개월 내에 제한능력자의 법정대리인이 없는 때에는 그가 능력자로 되거나 또는 법정대리인이 취임한 때로부터 6개월 내에는 시효가 완성되지 않는다(제179조).

(2) 재산관리자에 대한 제한능력자의 권리의 경우

재산을 관리하는 부모 또는 후견인에 대한 제한능력자의 권리는 그가 능력자로 되거나 또는 후임의 법정대리인이 취임한 때로부터 6개월 내에는 소멸시효가 완성하지 않는다(제180조 제1항).

(3) 부부간의 권리의 경우

부부의 한쪽이 다른 쪽에 대하여 가지는 권리는 혼인관계가 종료한 때로부터 6개월 내에는 소멸시효가 완성하지 않는다(제180조 제2항).

(4) 상속재산에 관한 권리의 경우

상속재산에 속한 권리나 상속재산에 대한 권리는 상속인의 확정, 관리인의 선임 또는 파산선고가 있는 때로부터 6개월 내에는 소멸시효가 완성하지 않는다(제181조).

(5) 천재·사변의 경우

천재 기타 사변으로 인하여 소멸시효를 중단할 수 없을 때에는 그 사유가 종료한 때로부터 1개월 내에는 시효가 완성하지 않는다(제182조).

7. 소멸시효완성의 효과

- ① 소멸시효의 완성으로 권리는 소급적으로 소멸한다(제167조).
소멸시효로 채무를 면하게 되는 자는 기산일 이후의 이자지급을 요하지 아니한다.
- ② 주된 권리의 소멸시효가 완성한 때에는 종속된 권리에도 그 효력이 미친다(제183조).
- ③ 소멸시효가 완성된 채권이 그 완성 전에 상계적상에 있는 때에는 채권자는 이를 자동채권으로 하여 상계할 수 있다(제495조).
- ④ 소멸시효의 이익은 미리 포기할 수 없다(제184조 제1항). 그러나 소멸시효완성 후에는 포기할 수 있다.
- ⑤ 당사자 사이에 시효요건을 가중, 배제 그리고 기간을 연장하는 특약은 무효이나, 단축 또는 경감하는 특약은 유효하다(제184조).
- ⑥ 시효이익의 포기는 일종의 의사표시이며, 상대방 있는 단독행위에 해당한다.
- ⑦ 시효이익의 포기는 명시적일 것을 요하지 않으며, 반드시 재판상으로 행사하여야 할 것을 요하지 아니한다. 그러나 시효이익의 포기를 위해서는 처분능력이나 처분권한을 필요로 한다.
- ⑧ 시효이익의 포기의 효과는 상대적이다. 따라서 시효이익을 받을 자가 수인 있는 경우에 그 중 1인의 포기는 다른 자에게 그 효과가 미치지 아니한다.

8. 소멸시효와 제척기간

소멸시효와 제척기간의 비교

구 분	소 멸 시 효	제 척 기 간
소급효	소멸시효로 인한 권리소멸은 소급한다.	권리소멸의 효과는 소급하지 않고 장래에 향하여 발생한다.
중단제도	인 정	불인정
정지제도	인 정	불인정
법원의 직권고려 여부	재판의 기초로 하기 위하여는 당사자의 원용이 있어야 한다.	법원은 당사자의 원용이 없어도 이를 직권으로 고려하여야 한다.
이익의 포기	시효 완성 후 시효이익의 포기가 가능하다.	포기가 인정되지 않는다.
기간의 단축	법률행위에 의하여 이를 단축 또는 경감할 수 있다.	단축 또는 경감할 수 없다.



핵심 판례 정리

- 01.** 기간계산에 관한 민법의 규정은 임의규정으로서 당사자의 특약이나 관습, 그리고 영업시간의 규칙이나 타 법률의 규정이 있을 때에는 그에 따르며, 널리 공·사법을 불문하고 적용되는 보충적인 규정이다.
- 02.** 4월 3일부터 10일간이란 기간을 4월 1일에 공고하였다면 4월 12일에 기간이 종료한다. 초일산입의 결과이다.
- 03.** 민법 제161조가 정하는 기간의 말일이 공휴일에 해당할 때에는 기간은 그 익일로 만료한다는 규정의 취지는 명문이 정하는 바와 같이 기간의 말일이 공휴일인 경우를 정하는 것이고, 이는 기간의 만료일이 공휴일에 해당함으로써 발생할 불이익을 막자는 것이므로 기간 계산의 초일은 이의 적용이 되지 않는다.
- 04.** 정년이 60세라 함은 만 60세에 도달하는 날을 말하는 것이지만 60세가 만료되는 날을 의미하지 않는다.
- 05.** 소유권이전등기청구권은 채권적 청구권이므로 10년의 소멸시효에 걸리지만 매수인이 매매목적물인 부동산을 인도받아 점유하고 있는 이상 매매대금의 지급 여부와는 관계없이 그 소멸시효가 진행되지 아니한다.

06. 부동산의 매수인이 그 부동산을 인도받은 이상 이를 사용·수익하다가 그 부동산에 대한 보다 적극적인 권리 행사의 일환으로 다른 사람에게 그 부동산을 처분하고 그 점유를 승계하여 준 경우에도 그 이전등기청구권의 행사 여부에 관하여 그가 그 부동산을 스스로 계속 사용·수익만 하고 있는 경우와 다를 바 없으므로 이전등기청구권의 소멸시효는 진행되지 않는다.

07. 권리의 존재나 권리행사 가능성을 알지 못하였거나 알지 못함에 있어서의 과실유무 등은 시효진행에 영향을 미치지 아니한다.

08. [1] 기한이익 상실의 특약은 그 내용에 의하여 일정한 사유가 발생하면 채권자의 청구 등을 요함이 없이 당연히 기한의 이익이 상실되어 이행기가 도래하는 것으로 하는 정지조건부 기한이익 상실의 특약과 일정한 사유가 발생한 후 채권자의 통지나 청구 등에 의해 이행기가 도래하는 것으로 하는 형성권적 기한이익 상실의 특약의 두 가지로 대별할 수 있고, 기한이익 상실의 특약이 채권자를 위하여 둔 것인 점에 비추어 형성권적 기한이익 상실의 특약으로 추정한다.

[2] 형성권적 기한이익 상실의 특약이 있는 경우에는 그 특약은 채권자의 이익을 위한 것으로서 기한이익의 상실 사유가 발생하였다고 하더라도 채권자가 나머지 전액을 일시에 청구할 것인가 또는 종래대로 할부변제를 청구할 것인가를 자유로이 선택할 수 있으므로, 이와 같은 기한이익 상실의 특약이 있는 할부채무에 있어서는 1회의 불이행이 있더라도 각 할부금에 대해 그 각 변제기의 도래시마다 그 때부터 순차로 소멸시효가 진행하고 채권자가 특히 잔존 채무 전액의 변제를 구하는 취지의 의사를 표시한 경우에 한하여 전액에 대하여 그 때부터 소멸시효가 진행한다.

09. 매매로 인한 부동산소유권 이전채무가 이행불능이 됨으로써 매수인이 매도인에 대하여 갖게 되는 손해배상청구권은 그 부동산소유권의 이전채무가 이행불능이 된 때에 발생하는 것이고, 그 계약체결일에 생기는 것은 아니므로 위 손해배상채권의 소멸시효는 계약체결일이 아닌 소유권이전채무가 이행불능된 때로부터 진행한다.

10. 불법행위에 기한 손해배상채권에 있어서 민법 제766조 제2항에 의한 소멸시효의 기산점이 되는 ‘불법행위를 한 날’이란 가해행위가 있었던 날이 아니라 가해행위로 인한 손해가 현실적인 것으로 되었다고 볼 수 있는 때로부터 진행한다.

11. 교통사고의 피해자들에게 손해배상을 한 공동불법행위자인 1인의 다른 공동불법행위자에 대한 구상금채권은 일반채권과 같이 구상권자가 현실로 피해자들에게 손해금을 지급한 때로부터 10년간 이를 행사하지 아니하면 시효로 소멸한다.

12. 민법 제163조 제1호 규정의 1년 이내의 기간으로 정한 채권이라 함은 1년 이내의 정기에 지급되는 채권을 의미하는 것이고, 변제기가 1년 내의 채권이라는 의미가 아니다.
13. 집합건물의 관리비채권은 민법 제163조 제1호에서 3년의 단기소멸시효에 걸리는 것으로 규정한 '1년 이내의 기간으로 정한 채권'에 해당한다.
14. 공유물분할청구권은 공유관계에서 수반되는 형성권이므로 공유관계가 존속하는 한 그 분할청구권만이 독립하여 시효로 소멸될 수 없다.
15. 민법 제165조의 규정은 단기의 소멸시효에 걸리는 것이라도 확정판결을 받은 권리의 소멸시효는 10년으로 한다는 뜻일 뿐 10년보다 장기의 소멸시효를 10년으로 단축한다는 의미도 아니고 본래 소멸시효의 대상이 아닌 권리가 확정판결을 받음으로써 10년의 소멸시효에 걸린다는 뜻도 아니다.
16. 민법 제163조 제2호 소정의 '의사의 치료에 관한 채권'에 있어서는, 특약이 없는 한 그 개개의 진료가 종료될 때마다 각각의 당해 진료에 필요한 비용의 이행기가 도래하여 그에 대한 소멸시효가 진행된다고 해석함이 상당하고, 장기간 입원치료를 받는 경우라 하더라도 다른 특약이 없는 한 입원치료 중에 환자에 대하여 치료비를 청구함에 아무런 장애가 없으므로 퇴원시부터 소멸시효가 진행된다고 볼 수는 없다.
17. 민법 제168조에서 가압류를 시효중단사유로 정하고 있는 것은 가압류에 의하여 채권자가 권리를 행사하였다고 할 수 있기 때문인데 가압류에 의한 집행보전의 효력이 존속하는 동안은 가압류채권자에 의한 권리행사가 계속되고 있다고 보아야 할 것이므로 가압류에 의한 시효중단의 효력은 가압류의 집행보전의 효력이 존속하는 동안은 계속된다.
18. 1개의 채권 중 일부에 대하여 가압류·압류를 하였는데, 채권의 일부에 대하여만 소멸시효가 중단되고 나머지 부분은 이미 시효로 소멸한 경우, 가압류·압류의 효력은 시효로 소멸하지 않고 잔존하는 채권 부분에 계속 미친다.
19. 재판상 청구라 함은 시효취득의 대상인 목적물의 인도 내지는 소유권존부확인이나 소유권에 관한 등기 청구소송은 말할 것도 없고 소유권침해의 경우에 그 소유권을 기초로 하여 방해배제 및 손해배상 또는 부당이득금반환청구소송도 이에 포함된다.
20. 채권 시효중단사유로서의 승인은 시효이익을 받을 당사자인 채무자가 그 시효의 완성으로 권리를 상실하게 될 자 또는 그 대리인에 대하여 그 권리가 존재함을 인식하고 있다는 뜻을 표시함으로써 성립한다고 할 것이며, 이 때 그 표시의 방법은 아무런 형식을 요구하지 아니하고, 또한 명시적이건 묵시적이건 불문한다.

- 21.** 시효완성 전에 채무의 일부를 변제한 경우에는, 그 수액에 관하여 다툼이 없는 한 채무승인으로서의 효력이 있어 시효중단의 효과가 발생한다.
- [판례해설]** 시효중단사유로서의 승인은 반드시 명시적일 것을 요하지 않는다. 원금의 일부변제, 이자의 지급, 증서의 재작성 등도 묵시적 승인으로 볼 수 있다.
- 22.** 소멸시효의 중단사유로서 채무자에 의한 채무승인이 있었다는 사실은 이를 주장하는 채권자 측에서 증명하여야 한다.
- 23.** 시효중단의 효력은 당사자 및 그 승계인에게만 미치는 바, 승계인이라 함은 포괄승계인은 물론 특정승계인도 이에 포함된다.
- 24.** 소멸시효 중단사유인 채무의 승인은 시효이익을 받을 당사자나 대리인만 할 수 있으므로 이행인수인이 채권자에 대하여 채무자의 채무를 승인하더라도 다른 특별한 사정이 없는 한 시효중단 사유가 되는 채무승인의 효력은 발생하지 않는다.
- 25.** 일반적으로 위법한 행정처분의 취소, 변경을 구하는 행정소송은 시효중단사유가 되지 못하는 것이나, 다만 오납한 조세에 대한 부당이득반환청구권을 실현하기 위한 수단이 되는 과세처분의 취소 또는 무효확인을 구하는 소는 비록 행정소송이라고 할지라도 조세환급을 구하는 부당이득반환청구권의 소멸시효중단사유인 재판상 청구에 해당한다.
- 26.** 시효의 이익을 받는 자가 원고가 되어 소를 제기한 데 대하여 피고로서 응소하여 그 소송에서 적극적으로 권리를 주장하고 그것이 받아들여진 경우도 시효의 중단사유가 되는 재판상의 청구에 해당한다.
- 27.** 한 개의 채권 중 일부에 관하여만 판결을 구한다는 취지를 명백히 하여 소송을 제기한 경우에는 소 제기에 의한 소멸시효중단의 효력이 그 일부에 관하여만 발생하고, 나머지 부분에는 발생하지 아니하지만 비록 그 중 일부만을 청구한 경우에도 그 취지로 보아 채권 전부에 관하여 판결을 구하는 것으로 해석된다면 그 전부에 관하여 시효중단의 효력이 발생한다.
- 28.** 최고를 여러번 거듭하다가 재판상 청구 등을 한 경우에 있어서의 시효중단의 효력은 항상 최초의 최고시에 발생하는 것이 아니라 재판상 청구 등을 한 시점을 기준으로 하여 이로부터 소급하여 6월 이내에 한 최고시에 발생한다.
- 29.** 소송이 취하된 경우에는 그로부터 6월내에 다시 재판상의 청구를 하지 않는 한 시효중단의 효력이 없고 다만 재판외의 최고의 효력만 있다.

30. 어음할인의 원인채권에 관하여 소를 제기한 것만으로는 그 할인된 어음상의 채권 그 자체를 행사한 것으로 볼 수 없어 이는 어음채권에 관한 소멸시효 중단사유인 재판상 청구에 해당하지 않는다.

[판례해설] 원인채권의 소멸시효의 중단은 어음채권의 소멸시효를 중단시키지 못하나, 어음채권의 소멸시효의 중단은 원인채권의 소멸시효를 중단시킨다.

31. 소멸시효가 완성된 후에 이르러 기한의 유예를 요청하는 것은 소멸시효의 이익을 포기한 취지로 보아야 한다.

32. 채무자가 시효완성 후에 채무의 승인을 한 때에는 시효완성의 사실을 알고 그 이익을 포기한 것이라고 본다.

33. 시효완성의 이익포기의 의사표시를 할 수 있는 자는 시효완성의 이익을 받을 당사자 또는 대리인에 한정된다고 할 것이고, 그 밖의 제3자가 시효완성의 이익포기의 의사표시를 하였다 하더라도 이는 시효완성의 이익을 받을 자에 대한 관계에서 아무 효력이 없다.

34. 소멸시효 이익의 포기는 상대적 효과가 있을 뿐이어서 다른 사람에게서는 영향을 미치지 아니함이 원칙이나, 소멸시효 이익의 포기 당시에는 권리의 소멸에 의하여 직접 이익을 받을 수 있는 이해관계를 맺은 적이 없다가 나중에 시효이익을 이미 포기한 자와의 법률관계를 통하여 비로소 시효이익을 원용할 이해관계를 형성한 자는 이미 이루어진 시효이익 포기의 효력을 부정할 수 없다.

35. 민법 제146조의 취소권의 단기소멸의 기간은 소멸시효기간이 아니라 제척기간으로서, 제척기간이 도과하였는지 여부는 당사자의 주장에 관계없이 법원이 당연히 조사하여 고려하여야 한다.

36. 채권자가 동일한 목적을 달성하기 위하여 복수의 채권을 갖고 있는 경우, 채권자로서는 그 선택에 따라 권리를 행사할 수 있되, 그 중 어느 하나의 청구권을 행사하는 것만으로는 다른 채권에 대한 소멸시효 중단의 효력이 없다.

37. 본래의 소멸시효 기산일과 당사자가 주장하는 기산일이 서로 다른 경우에는 변론주의의 원칙상 법원은 당사자가 주장하는 기산일을 기준으로 소멸시효를 계산하여야 한다.

38. 채무자가 소멸시효 완성 후 채무를 일부 변제한 때에는 그 액수에 관하여 다툼이 없는 한 그 채무 전체를 묵시적으로 승인한 것으로 보아야 한다.

39. 시효가 중단된 때에는 중단까지에 경과한 시효기간은 이를 산입하지 아니하고 중단사유가 종료한 때로부터 새로이 진행하는데(민법 제178조 제1항), 소멸시효의 중단사유 중 '압류'에 의한 시효중단의 효력은 압류가 해제되거나 집행절차가 종료될 때 중단사유가 종료한 것으로 볼 수 있다.

40. 보험계약자가 다수의 계약을 통하여 보험금을 부정 취득할 목적으로 체결한 보험계약이 민법 제103조에 따라 무효인 경우, 보험회사의 보험금에 대한 부당이득반환청구권은 상법 제64조를 유추적용하여 5년의 상사 소멸시효기간이 적용된다.



중요 지문 정리

01. 기간을 일, 주, 월 또는 연으로 정한 때에는 기간의 초일은 산입하지 아니한다. 그러나 그 기간이 오전 영시로부터 시작하는 때에는 그러하지 아니하다. ()
02. 매수인이 목적물을 인도받아 이를 사용·수익하고 있는 경우에는 그 등기청구권은 소멸시효에 걸리지 않는다. ()
03. 청구부분이 특정될 수 있는 경우에 있어서의 일부청구는 나머지 부분에 대한 시효중단의 효력이 있다. ()
04. 소멸시효가 완성되어도 당사자의 원용이 있어야 채무소멸의 효과가 발생한다. ()
05. 재판상의 청구를 하였다가 소를 취하한 경우에는 최고의 효력도 없다. ()
06. 최고를 여러 번 거듭하다가 재판상 청구 등을 한 경우에는 시효중단의 효력은 항상 최초의 최고시에 소급하여 발생한다. ()
- 07 제척기간이 도과하였는지 여부는 직권조사사항으로서 이에 대한 당사자의 주장이 없더라도 법원이 당연히 직권으로 조사하여 재판에 고려하여야 한다. ()
08. 주채무자에 대하여 이행청구소송을 제기하더라도 보증인에 대하여는 시효중단의 효력이 없다. ()
09. 주채무에 관한 판결이 확정되어 소멸시효기간이 10년으로 연장된 경우에도 보증채무의 시효기간은 여전히 종전의 소멸시효기간에 따른다. ()

타당한 기술이다. (○)

대법원 1976.11.6 76다148 (○)

청구부분이 특정될 수 있는 경우에 있어서의 일부청구는 나머지 부분에 대한 시효중단의 효력이 없고 나머지 부분에 관하여는 소를 제기하거나 그 청구를 확장하는 서면을 법원에 제출한 때에 비로소 시효중단의 효력이 생긴다(대법원 1975.2.25. 74다1557). (×)

당사자의 원용이 없어도 시효완성의 사실로서 채무는 당연히 소멸한다. (×)

재판상 청구가 각하, 기각, 취하된 경우에도 최고로서 효력은 인정된다. (×)

최고를 여러 번 거듭하다가 재판상 청구 등을 한 경우에 시효중단의 효력은 항상 최초의 최고시에 발생하는 것이 아니라 재판상청구 등을 한 시점을 기준으로 하여 이로부터 소급하여 6월 이내에 한 최고시에 발생한다. (×)

대법원 2000.10.13. 99다18725 (○)

대법원 2006.8.24 2004다26287 (×)

제195조 (○)

10. 소멸시효는 그 기산일에 소급하여 효력이 생기는데, 소멸시효가 완성된 채권이 그 완성 전에 상계할 수 있었던 경우라도 그 채권자는 상계할 수 없다. ()

소멸시효가 완성된 채권이 그 완성 전에 상계할 수 있었던 것이면 그 채권자는 상계할 수 있다(제495조). (×)

11. 시효중단 사유 중 하나인 가압류가 이루어진 경우, 소멸시효 중단의 효력은 가압류신청을 한 때로 소급한다. ()

대법원 2017.4.7. 2016다35451 (○)

12. 채무자가 소멸시효 완성 후에 채권자에 대하여 채무를 승인함으로써 그 시효의 이익을 포기한 경우에는 그때부터 새로이 소멸시효가 진행된다. ()

대법원 2009.7.9. 2009다14340 (○)

13. 소멸시효 완성의 이익 포기의 의사표시는 채무자에게 불리한 행위로서 시효이익을 받을 당사자인 채무자에 의하여 행하여져야 하고, 그 대리인에 의하여 행하여질 수 없다. ()

시효완성의 이익 포기의 의사표시를 할 수 있는 자는 시효완성의 이익을 받을 당사자 또는 그 대리인에 한정되고, 그 밖의 제3자가 시효완성의 이익 포기의 의사표시를 하였다 하더라도 이는 시효완성의 이익을 받을 자에 대한 관계에서 아무 효력이 없다(대법원 2014.1.23. 2013다64793). (×)

14. 소멸시효는 법률행위에 의하여 이를 배제, 연장 또는 가중할 수 없고, 이를 단축 또는 경감할 수도 없다. ()

제184조 (×)

15. 하나의 금전채권의 원금 중 일부가 변제된 후 나머지 원금에 대하여 소멸시효가 완성된 경우, 소멸시효 완성의 효력은 소멸시효가 완성된 원금 부분으로부터 그 완성 전에 발생한 이자 또는 지연손해금 뿐만 아니라 변제로 소멸한 원금 부분으로부터 그 변제 전에 발생한 이자 또는 지연손해금에도 미친다. ()

대법원 2008.3.14. 2006다2940 (×)



감정평가사 민법 핵심정리



PART

02

물권법

감정평가사 민법 핵심정리

CHAPTER 01 물권변동

CHAPTER 02 점유권

CHAPTER 03 소유권

CHAPTER 04 용익물권

CHAPTER 05 담보물권

◎ 단원별 출제경향

구 분	28회	29회	30회	31회	32회	33회	34회
물권변동	6	5	7	6	3	3	5

제1절 물권법정주의

(1) 의 의

물권의 종류와 그 내용은 법률 또는 관습법에 의하는 외에는 임의로 창설하지 못한다(제185조).

- ① 제185조는 강행규정이므로 이에 위반하는 법률행위는 무효이다.
- ② 법률은 국회가 제정한 법률만을 의미하고 명령과 규칙 등은 제외된다.

(2) 종 류

- ① 민법이 인정하는 물권은 점유권·소유권·지상권·지역권·전세권·유치권·질권·저당권의 8종류가 있다.
- ② 관습법상의 물권으로는 분묘기지권·관습법상의 법정지상권·동산의 양도담보권 등이 있다.
그러나 온천권, 미등기 무허가건물에 대한 소유권취득이나 근린공원이용권 등은 관습법상의 물권에 해당하지 않는다.

제2절 물권적 청구권

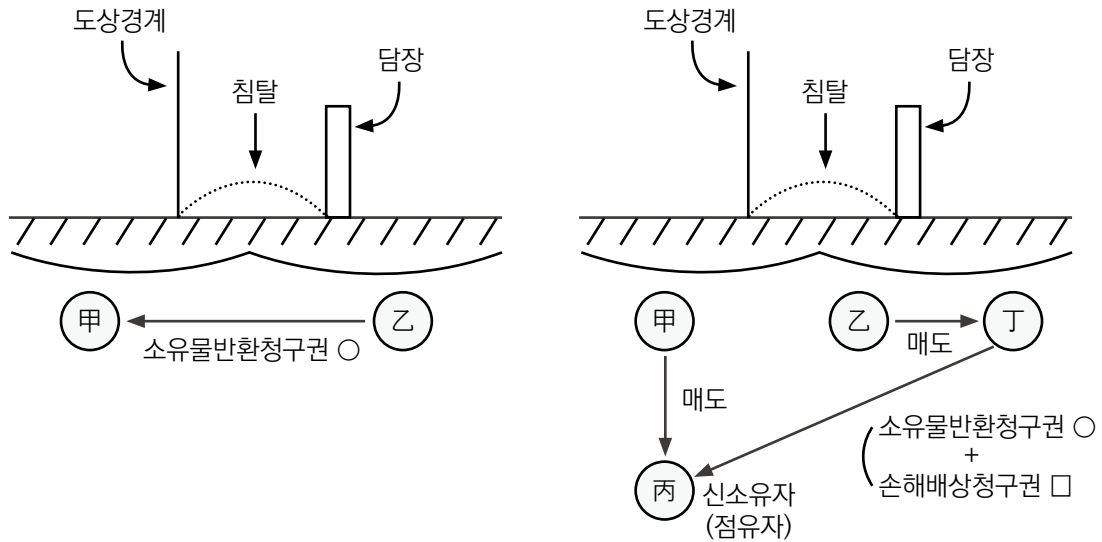
(1) 의 의

- ① 물권의 내용의 실현이 어떤 사정으로 인하여 방해당하고 있거나 방해당할 염려가 있는 경우에 그 방해의 제거 또는 예방에 필요한 일정한 행위를 청구할 수 있는 권리를 물권적 청구권이라고 한다.
- ② 점유권과 소유권에 관하여 명문의 규정을 두고 있고 소유권에 기인한 물권적 청구권을 다른 물권에도 준용한다.

(2) 성 질

- ① 물권적 청구권은 채권적 청구권에 우선하며, 물건이 이전되거나 소멸하면 물권적 청구권도 따라서 이전하거나 소멸한다.
- ② 물권적 청구권은 침해자(방해자)의 고의·과실(귀책사유)이 없는 때에도 인정된다. 그러나 불법행위로 인한 손해배상청구권을 행사하기 위해서는 침해자(방해자)의 고의·과실(귀책사유)을 요한다.
- ③ 물권적 청구권의 청구권자는 현재의 물건자이며 청구의 상대방은 현재의 점유자이다. 따라서 미등기건물의 매수인은 현재의 물건자라 할 수 없으므로 건물의 불법점유자에 대하여 소유권에 기한 명도를 청구하지 못한다.
- ④ 지역권자와 저당권자에게는 물권적 반환청구권이 인정되지 아니한다.
- ⑤ 방해예방청구권은 물건이 현재 방해당하고 있지는 않지만 방해가 생길 염려가 있는 경우에 청구할 수 있는 권리로서 방해의 예방 또는 손해배상담보를 선택적으로 행사할 수 있다.

◆ 물건적 청구권



제3절 부동산 물건변동

(1) 법률행위에 의한 부동산물건의 변동

부동산에 관한 법률행위로 인한 물건의 득실변경은 등기하여야 그 효력이 생긴다(제186조).

(2) 법률의 규정에 의한 물건변동

상속(피상속인 사망시 물건변동) · 공용징수(협의수용은 협의에서 정한 시기, 재결수용은 보상금지급을
정지조건으로 수용개시일에 물건변동) · 판결(판결확정시 물건변동) · 경매(매각대금 완납시 물건변동)

기타 법률의 규정에 의한 부동산에 관한 물건의 취득은 등기를 요하지 아니한다.

그러나 등기를 하지 않으면 이를 처분하지 못한다(제187조).

* 기타 등기를 요하지 않는 물건변동

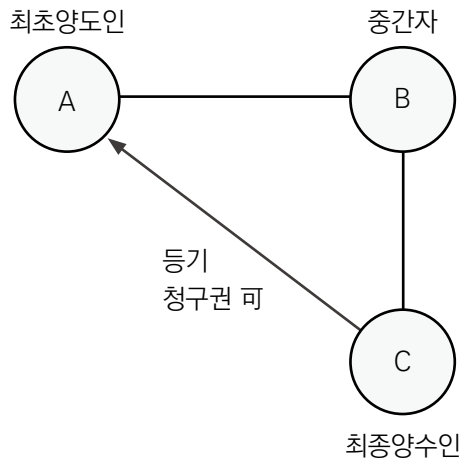
- ① 신축건물의 소유권 취득
- ② 법정지상권의 취득
- ③ 관습법상의 법정지상권의 취득
- ④ 법정저당권의 취득
- ⑤ 존속기간만료로 인한 용익물권의 소멸
- ⑥ 혼동에 의한 물건의 소멸
- ⑦ 피담보채권의 소멸로 인한 저당권의 소멸
- ⑧ 법률행위의 무효·취소·해제로 인한 물건의 복귀
- ⑨ 법정대위로 인한 저당권의 이전
- ⑩ 분묘기지권의 취득
- ⑪ 재단법인으로의 출연재산의 귀속(출연자와 법인사이)
- ⑫ 포괄적 승계(포괄유증·회사의 합병)

※ 취득시효로 인한 물건변동은 법률의 규정에 의한 물건변동이지만 반드시 등기를 요한다(제245조).

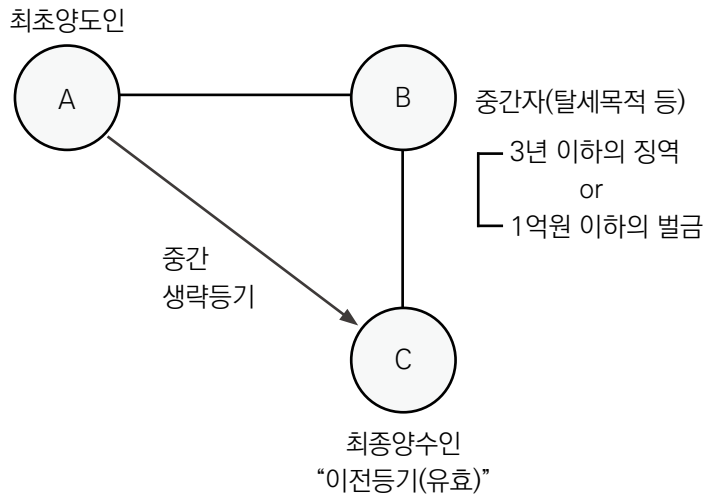
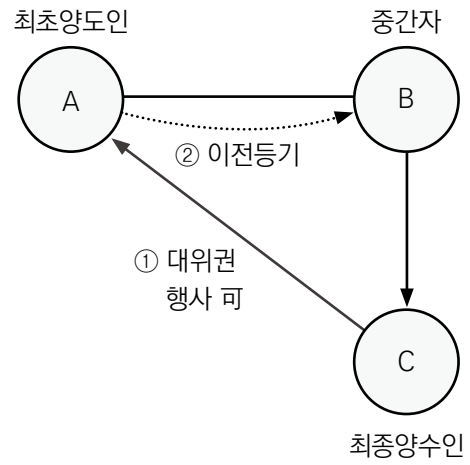
제4절 중간생략등기

- ① 3자의 합의가 있는 때에는 최종양수인은 최초양도인에 대하여 직접 소유권이전등기를 청구할 수 있다.
이러한 합의는 묵시적으로도 할 수 있고, 또한 순차적으로도 할 수 있다.
- ② 합의가 없는 때에는 최종양수인은 최초양도인에 대하여 직접 소유권이전등기를 청구할 수 없다.
따라서 최종양수인은 최초양도인에 대하여 중간자를 대위하여 중간자명의로 소유권이전등기를 할 것을
청구할 수 있을 뿐이다.
- ③ 3자의 합의가 없더라도 이미 중간생략등기가 적법한 등기원인에 기하여 이루어진 때에는
실체관계와 부합하므로 유효하다는 것이 판례의 태도이다.

◆ 3자 합의가 있는 경우



◆ 3자 합의가 없는 경우



제4절 가등기

- ① 청구권이 시기부 또는 정지조건부인 때에는 가등기를 할 수 있다.
- ② 가등기만으로는 물건변동의 효력이 생기지 않으며, 등기의 추정력도 인정되지 않는다.
- ③ 가등기에 기하여 본등기를 하는 때에 그 순위는 가등기의 순위에 의하지만
물권변동의 효력은 본등기를 하는 때에 발생한다. 즉, 물건변동의 효력은 가등기시로 소급하지 않는다.
- ④ 가등기에 기하여 본등기가 이루어지면 이에 대항할 수 없는 중간등기는 직권말소되거나 후순위권리가 된다.



핵심 판례 정리

- 01.** 소유권을 상실한 전소유자는 제3자인 불법점유자에게 물건적 청구권에 의한 방해배제를 청구할 수 없다.
- 02.** 미등기 무허가건물의 양수인이라도 소유권이전등기를 마치지 않는 한 건물의 소유권을 취득할 수 없고, 소유권에 준하는 관습상의 물건이 있다고도 할 수 없으므로, 미등기 무허가건물의 양수인은 소유권에 기한 방해제거청구를 할 수 없다.
- 03.** 건물의 소유자가 타인 소유의 토지를 점유하고 있다고 하더라도 그 토지 소유자로서는 그 건물의 철거와 그 대지 부분의 인도를 청구할 수 있을 뿐, 자기 소유의 건물을 점유하고 있는 자에 대하여 그 건물에서 퇴거할 것을 청구할 수는 없다.
- 04.** 소유자는 불법점거의 형태에 관계없이 그 사실상의 지배자를 상대로 불법점거물의 물건적 반환청구를 할 수 있다.
- 05.** 건물을 매수하여 점유하고 있는 자는 등기부상 아직 소유자로서의 등기명의를 없다 하더라도 그 건물이 건립되어 있어 불법으로 점유를 당하고 있는 토지소유자는 건물점유자에게 그 철거를 구할 수 있다.
- 06.** 판결에 의한 물건취득은 등기할 필요가 없으나 이때의 판결이란 부동산 소유권이전등기절차의 이행을 명하는 판결은 포함되지 아니한다.
[판례해설] 등기를 요하지 아니하는 물건변동으로서의 판결이란, 형성판결(공유물 분할판결, 사해행위 취소판결, 상속재산 분할판결)만을 의미하며 이행판결이나 확인판결은 이에 해당하지 아니한다.
- 07.** 부동산매수인의 등기청구권도 형식주의를 취하고 있는 현행 민법 하에서는 채권적 청구권이라고 해석되지만, 매수인이 매매목적물을 인도받은 경우에는 다른 채권과는 달리 소멸시효에 걸리지 않는다.

- 08.** 이미 중간생략등기가 이루어져 버린 경우에는 계약당사자 사이에 적법한 원인행위가 성립되어 이행된 이상, 다만 중간생략등기에 관한 합의가 없었다는 사유만으로는 그 등기를 무효라고 할 수는 없다.
- 09.** 중간생략등기의 합의가 있다고 하여 최초의 매도인이 자신이 당사자가 된 매매계약상의 매수인인 중간자에 대하여 갖고 있는 매매대금청구권의 행사가 제한되는 것은 아니다.
- 10.** 중간생략등기의 합의가 있는 후에 최초 매도인과 중간 매수인 간에 매매대금을 인상하는 약정이 체결된 경우, 최초 매도인은 인상된 매매대금이 지급되지 않았음을 이유로 최종 매수인 명의로의 이전등기 의무의 이행을 거절할 수 있다.
- 11.** 토지거래허가구역에서 최종 매수인이 자신과 최초 매도인을 매매당사자로 하는 토지거래허가를 받아 자신 앞으로 소유권이전등기를 경료하였더라도 그러한 이전등기는 적법한 토지거래허가 없이 경료된 등기로 무효이다.
- 12.** 최종 양수인이 중간자로부터 소유권이전등기 청구권을 양도받았다고 하더라도 최초 양도인이 그 양도에 대하여 동의하지 않고 있다면 최종 양수인은 최초 양도인에 대하여 채권양도를 원인으로 하여 소유권이전등기 절차 이행을 청구할 수 없다.
- 13.** 등기는 물권의 효력발생요건이고 효력존속요건이 아니므로 물권에 관한 등기가 원인없이 말소된 경우에도 그 물권의 효력에는 아무런 영향을 미치지 않는다.
- 14.** 사기의 의사표시에 의해 건물을 명도해 준 것이라면 건물의 점유를 침탈당한 것이 아니므로 피해자는 물권적 청구권을 행사하지 못한다.



중요 지문 정리

01. 유치권은 부동산을 객체로 할 수도 있다. ()

유치권의 객체는 부동산과 동산 그리고 유가증권이다. (○)

02. 온천권은 관습법상 인정되는 물건이다. ()

온천에 관한 권리는 관습상의 물건이나 준물권이라 할 수 없고 온천수는 공용수 또는 생활상 필요한 용수에 해당되지 않는다(대법원 1972.8.29. 72다1243). (×)

03. 건물이라고 함은 최소한의 기둥과 지붕 그리고 주벽이 이루어지면 이를 법률상 건물이라 할 수 있다. ()

타당한 기술이다. (○)

04. 일단의 증감 변동하는 동산을 하나의 물건으로 보아 이를 채권담보의 목적으로 삼으려는 이른바 집합물에 대한 양도담보 설정계약체결은 허용되지 않는다. ()

일단의 증감 변동하는 동산을 하나의 물건으로 보아 이를 채권담보의 목적으로 삼으려는 이른바 집합물에 대한 양도담보설정계약체결도 가능하다(대법원 1990.12.26. 88다카20224). (×)

05. 부동산매수인의 등기청구권은 물권적 청구권이다. ()

부동산매수인의 등기청구권은 채권적 청구권이다. (×)

06. 물권적 청구권은 그 침해자의 고의나 과실이 있는 경우에만 행사할 수 있다. ()

물권적 청구권은 침해자의 고의나 과실을 요하지 않는다. (×)

07. 물권적 청구권의 상대방은 침탈 또는 방해가 현재 자기의 지배하에 있는 자이다. ()

타당한 기술이다. (○)

08. 점유할 권리가 없는 저당권·지역권에 대하여는 물권적 반환청구권이 인정될 여지가 없다. ()

타당한 기술이다. (○)

09. 건물의 소유자가 그 건물의 소유를 통하여 토지를 불법점유하고 있는 경우 그 토지 소유자로서는 그 건물의 철거와 그 대지 부분의 인도를 청구할 수 있을 뿐, 자기 소유의 건물을 점유하고 있는 자에 대하여 그 건물에서 퇴거할 것을 청구할 수는 없다. ()

대법원 1999.7.9. 98다57457 (○)

10. 건물을 신축하여 그 소유권을 원시취득한 자로부터 그 건물을 매수하였으나 그 건물이 미등기 무허가 건물이어서 아직 소유권이전등기를 갖추지 못한 자는 그 건물의 불법점유자에 대하여 직접 자신에게 인도할 것을 청구할 수는 없다. ()

대법원 2007.6.15. 2007다11347 (○)

11. 판례는 소유권에 기인한 물권적 청구권은 소멸시효에 걸리지 않으나, 제한물권에 기인한 물권적 청구권은 소멸시효에 걸린다고 한다. ()

타당한 기술이다. (○)

12. 물권과 채권이 충돌한 경우 물권이 채권에 우선한다는 것에는 예외가 없다. ()

채권을 가동기하거나 부동산임차권을 등기한 경우에는 후에 성립하는 물권에 우선한다. (×)

13. 우리 민법은 동산에 관하여 선의취득을 인정하는 등 일정한 동산에 관하여는 공신의 원칙을 채택하고 있으나, 부동산에 관하여는 공신의 원칙을 채택하지 않는다. ()

타당한 기술이다. (○)

14. 판례는 경작권 없이 타인의 토지를 경작한 경우에는 그 농작물은 토지소유자에게 귀속한다고 한다. ()

경작자의 소유가 된다. (×)

- 15.** 우리 민법은 법률행위로 인한 부동산·동산의 물건변동에 관하여 공시방법을 갖추어야 효력이 생기는 것으로 규정함으로써 성립요건주의를 채택하고 있다. ()
- 16.** 동일한 부동산에 관하여 등기한 권리의 순위는 법률에 다른 규정이 없는 때에는 등기의 전후에 의하고, 등기의 전후는 등기용지의 같은 구에서 한 등기에 대하여는 접수번호에 의하고 다른 구에서 한 등기에 대하여는 순위번호에 의한다. ()
- 17.** 등기는 물권의 효력발생요건이고 효력존속요건이 아니므로 물건에 관한 등기가 원인 없이 말소된 경우에 그 물권의 효력에는 아무런 영향을 미치지 않는다. ()
- 18.** 동일 부동산에 관하여 등기명의인을 달리하여 중복된 소유권보존등기가 경료된 경우에는 먼저 이루어진 소유권보존등기가 원인무효가 아닌 한 뒤에 된 소유권보존등기는 실체관계에 부합한다고 하더라도 무효이다. ()
- 19.** 법정지상권의 성립은 법률의 규정(제305조·제366조)에 의한 물건변동으로서 등기 없이도 성립한다. ()
- 20.** 상속으로 인한 소유권취득은 법률의 규정에 의한 물건변동으로서 등기를 요하지 아니하나, 상속으로 취득한 권리의 이전은 등기를 요한다. ()
- 21.** 중간생략등기는 물건변동의 과정에는 부합하지 않으나 현재의 물건상태와 부합한다는 점에서 판례는 그 유효성을 인정한다. ()
- 22.** 지상권이 저당권의 목적이 된 경우, 지상권자가 목적 토지의 소유권을 취득 하더라도 지상권은 혼동으로 소멸하지 않는다. ()
- 23.** 무효등기의 유용이 인정되는 것은 사항란의 등기에만 한하는 것이며, 표제 부 등기의 유용은 인정되지 않는다. 따라서 건물이 멸실되어 새로 신축한 건물의 등기로 구등기를 유용한 경우에는 그 등기는 무효이다. ()
- 24.** 가등기에 기하여 본등기를 한 경우에 있어, 물건변동의 효력은 가등기를 한 때로 소급한다. ()
- 25.** 최종 양수인이 중간생략등기의 합의를 이유로 최초 양도인에게 직접 중간 생략등기를 청구하기 위하여는 관계 당사자 전원의 의사합치가 필요하지 만, 당사자 사이에 적법한 원인행위가 성립되어 일단 중간생략등기가 이루어진 이상 중간생략등기에 관한 합의가 없었다는 이유만으로는 중간생략등기가 무효라고 할 수는 없다. ()

타당한 기술이다. (○)

같은 구에서 한 등기에 대하여는 순위번호에 의하고 다른 구에서 한 등기에 대하여는 접수번호에 의한다. (×)

타당한 기술이다. (○)

대법원 1996.10.17. 96다12511 (○)

타당한 기술이다. (○)

대법원 2007.6.15. 2007다11347 (○)

타당한 기술이다. (○)

타당한 기술이다. (○)

타당한 기술이다. (○)

순위가 소급하는 것이고, 물건변동의 효력은 본등기할 때에 발생한다. (×)

대법원 2005.9.29. 2003다40651 (○)

- 26.** 토지거래허가구역 내에서 최종 매수인이 자신과 최초 매도인을 매매 당사자로 하는 토지거래허가를 받아 자신 앞으로 소유권이전등기를 경료하였다고 하더라도 이는 적법한 토지거래허가 없이 경료된 등기로서 무효이다. ()
- 27.** 부동산에 관하여 등기가 경료되어 있는 경우 특별한 사정이 없는 한 그 원인과 절차에 있어서 적법하게 경료된 것으로 추정된다. ()
- 28.** 실질관계의 소멸로 무효로 된 등기의 유용은 그 등기를 유용하기로 하는 합의가 이루어지기 전에 등기상 이해관계가 있는 제3자가 생기지 않은 경우에 허용된다. ()
- 29.** 부동산 매수인이 그 목적물을 인도받아서 이를 사용수익하고 있는 경우에는 그 매수인을 권리 위에 잠자는 것으로 볼 수도 없고 그 매수인의 등기청구권은 다른 채권과는 달리 소멸시효에 걸리지 않는다. ()
- 30.** 소유권이전등기가 경료되어 있는 경우 그 등기명의자는 제3자에 대하여는 적법한 등기원인에 의하여 소유권을 취득한 것으로 추정되지만, 그 前 소유자에 대하여는 그러하지 아니하다. ()

타당한 기술이다. (○)

등기의 추정력은 등기원인과 절차 등에 그 효력이 인정된다. (○)

대법원 2009.2.26. 2006다72802 (○)

타당한 기술이다. (○)

부동산에 관하여 소유권이전등기가 마쳐져 있는 경우, 등기명의자는 제3자에 대하여서뿐만 아니라 그 전의 소유자에 대하여도 적법한 등기원인에 의하여 소유권을 취득한 것으로 추정되므로, 이를 다투는 측에서 무효사유를 주장·증명하여야 한다(대법원 2013.1.10. 2010다75044). (×)

◎ 단원별 출제경향

구 분	28회	29회	30회	31회	32회	33회	34회
점유권	2	2	3	2	2	1	2

제1절 점유의 모습

(1) 점유보조자

- ① 점유보조자란 가사상·영업상 기타 이와 유사한 관계에 의하여 타인의 지시를 받아 물건에 대한 사실상의 지배를 하는 자를 말하다(제195조).
- ② 점유보조자는 점유자가 아니며, 점유주만이 점유자이므로 과실수취권이나 점유보호청구권을 행사할 수 없다. 그러나 점유보조자도 자력구제권을 행사할 수 있다.

(2) 간접점유자

- ① 직접점유자와 간접점유자 사이에 지상권·전세권 등의 법률관계가 존재하여야 한다.
- ② 간접점유자도 점유권을 가지며(제194조), 점유보호청구권도 있으나(제207조), 다만 침탈자에 대하여 직접점유자에게 반환할 것을 청구할 수 있을 뿐이다.

(3) 자주점유와 타주점유

- ① 소유의 의사로써 하는 점유를 자주점유라 하며(ex. 소유자·무효인 매매의 매수인·도둑(盜人) 등), 소유의 의사 없는 점유를 타주점유라 한다(ex. 지상권자·전세권자·임차인 등).
- ② 점유자가 주장하는 권원이 불분명한 경우에는 점유자는 소유의 의사로써 점유하는 것으로 추정된다(제197조 제1항).
- ③ 점유자는 소유의 의사로 선의·평온·공연·계속 그리고 적법하게 점유한 것으로 추정된다. 단, 무과실은 추정되지 않으므로 점유자가 스스로 증명하여야 한다는 것이 판례의 태도이다.

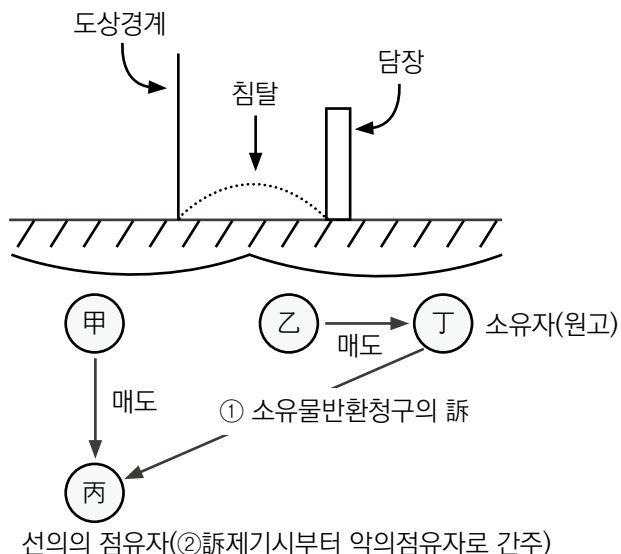
제2절 점유자와 회복자와의 관계

(1) 점유물의 멸실·훼손

- ① 점유자가 점유물을 멸실·훼손한 때에는 악의의 점유자는 그 손해의 전부를 배상하여야 하며, 선의의 자주점유자는 이익이 현존하는 한도에서 배상하면 된다.
- ② 타주점유자는 선의이더라도 악의점유자와 같은 책임을 진다.

(2) 점유자의 비용상환청구권

- ① 점유자(선의·악의 불문)는 점유물을 유지·보존하기 위하여 지출한 필요비의 상환을 회복자에 대하여 청구할 수 있다. 다만, 점유자가 과실을 취득한 때에는 통상의 필요비는 청구할 수 없다.
- ② 점유물의 개량을 위하여 지출한 유익비는 그 가액의 증가가 현존한 경우에 한하여 회복자의 선택에 좇아 그 지출액이나 증가액의 상환을 청구할 수 있다.
- ③ 선의의 점유자는 점유물에서 생기는 과실(果實)을 취득할 수 있다(제201조 제1항).
그러나 악의의 점유자는 수취한 과실(果實)을 반환하여야 할 뿐만 아니라, 이미 소비하였거나 과실(過失)로 인하여 훼손 또는 수취하지 못한 과실(果實)의 대가를 보상하여야 한다(제201조 제2항).
- ④ 선의의 점유자라도 본권에 관한訴에서 패소한 때에는 그訴가 제기된 때로부터 악의의 점유자로 간주된다.



제3절 점유보호청구권

(1) 의의

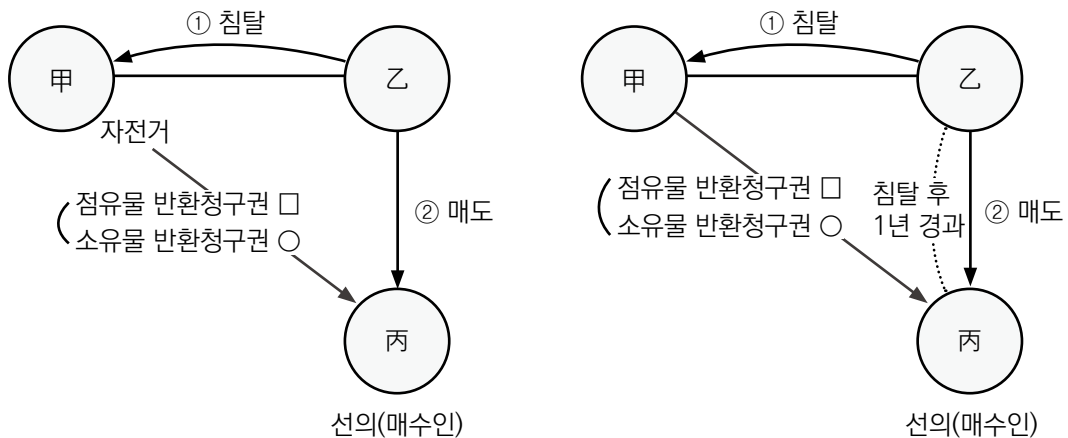
점유보호청구권은 점유를 침해·방해당하거나 방해당할 염려가 있는 경우에 점유자가 침해자(방해자)에 대하여 그 침해의 배제 및 손해배상 또는 그 담보를 청구하는 권리로서 물권적 청구권의 일종이다.

(2) 내용

구 분	요 건	내 용	제척기간
점유물반환 청구권	· 점유를 침탈당하였을 것 · 침탈자의 고의·과실은 불문함 · 선의의 특별승계인에게는 행사하지 못함	목적물반환 및 손해배상청구	침탈당한 날로부터 1년
점유물방해 제거청구권	· 점유의 방해를 받았을 것 · 방해자의 고의·과실은 불문함 · 정당한 방해, 수인한도 내의 것이 아닐 것	방해의 제거 및 손해배상청구	방해가 종료한 날로부터 1년
점유물방해 예방청구권	· 점유를 방해받을 염려가 있을 것 · 염려의 존부는 사회통념으로 판단	방해예방 또는 손해배 상담보의 선택적 청구	방해염려의 존속중은 언제나 행사가능

□ 점유보호청구권을 행사하기 위해서는 침탈자 또는 방해자의 고의나 과실을 요하지 않으나, 손해배상청구권을 행사하기 위해서는 고의 또는 과실을 요한다.

◆ 점유보호청구권





핵심 판례 정리

- 01.** 점유자의 자주점유는 제197조 제1항에 의하여 추정되는 것이므로 점유자의 점유가 타주점유임을 주장하는 상대방에게 그에 관한 증명책임이 있다.
- 02.** 점유자가 점유개시 당시에 소유권 취득의 원인이 될 수 있는 법률행위 기타 법률요건이 없다는 사실을 잘 알면서 타인 소유의 부동산을 무단 점유한 것임이 증명된 경우에는 자주점유의 추정은 깨어진다.
- 03.** 점유자의 점유가 자주점유인지 아니면 타주점유인지의 여부는 점유자의 내심의 의사에 의하여 결정되는 것이 아니라 점유취득의 원인이 된 권원의 성질이나 점유와 관계가 있는 모든 사정에 의하여 외형적·객관적으로 결정되어야 한다.
- 04.** 민법 제201조 제1항은 “선의의 점유자는 점유물의 과실을 취득한다.”라고 규정하고 있는 바, 여기서 선의의 점유자라 함은 과실수취권을 포함하는 권원이 있다고 오신한 점유자를 말하고, 다만 그와 같은 오신을 함에는 오신할 만한 정당한 근거가 있어야 한다.
[판례해설] 과실취득권이 있는 선의의 점유자란 과실취득권을 포함하는 권원인 소유권·지상권·임차권 등이 있다고 오신한 점유자를 말한다.
- 05.** 선의의 점유자는 비록 법률상 원인 없이 타인의 건물을 점유·사용하고 이로 말미암아 그에게 손해를 입혔다고 하더라도 그 점유·사용으로 인한 이득을 반환할 의무는 없다.
- 06.** 점유자의 필요비 또는 유익비상환청구권은 점유자가 회복자로부터 점유물의 반환을 청구받거나 회복자에게 점유물을 반환한 때에 회복자에 대하여 행사할 수 있다.
- 07.** 민법 제205조에 의하면, 점유자가 점유의 방해를 받은 때에는 방해의 제거 및 손해의 배상을 청구할 수 있고(제1항), 제1항의 청구권은 방해가 종료한 날로부터 1년 내에 행사하여야 하는데(제2항), 민법 제205조 제2항이 정한 ‘1년의 제척기간’은 재판 외에서 권리행사하는 것으로 족한 기간이 아니라 반드시 그 기간 내에 소를 제기하여야 하는 이른바 출소기간으로 해석함이 타당하다. 그리고 기산점이 되는 ‘방해가 종료한 날’은 방해 행위가 종료한 날을 의미한다(대법원 2016.7.29. 2016다214483).



중요 지문 정리

- 01.** 점유자가 물건에 대한 사실상의 지배를 상실한 때에는 침탈당한 물건을 회수 하더라도 그 점유권은 소멸한다. ()
- 02.** 선의의 점유자라도 본권에 관한 소에 패소한 때에는 그 패소한 때로부터 악 의의 점유자로 본다. ()
- 03.** 악의의 점유자는 수취한 과실을 반환하여야 하며, 소비하였거나 과실로 인 하여 훼손 또는 수취하지 못한 경우에는 그 과실의 대가를 보상하여야 한 다. ()
- 04.** 가사상, 영업상 기타 유사한 관계에 의하여 타인의 지시를 받아 물건에 대한 사 실상의 지배를 하는 때에는 그 타인만을 점유자로 한다. ()
- 05.** 점유권에 기인한 소는 본권에 관한 이유로 재판하지 못한다. ()
- 06.** 점유물의 멸실·훼손에 대하여 선의의 점유자는 현존이익의 한도 내에서 배상 책임을 지나, 소유의 의사가 없으면 악의의 점유자와 같이 손해의 전부를 배 상하여야 한다. ()
- 07.** 점유자의 필요비상환청구권은 점유자가 회복자로부터 점유물의 반환을 청 구받기 전에도 행사할 수 있다. ()
- 08.** 건물의 소유자라고 하더라도 당해 건물을 현실적으로 점유하고 있지 아니 하다면 그 부지인 토지를 점유하고 있다고 볼 수 없다. ()
- 09.** 점유가 성립하기 위해서는 적어도 사실적 지배관계를 가지려는 의사인 점 유설정의사는 필요하다. ()
- 10.** 직접 점유자가 그 물건을 반환받기를 원하지 않은 때에는 간접점유자는 직 접 자신에게 반환할 것을 청구할 수 있다. ()

점유자가 물건에 대한 사실상의 지 배를 상실한 때에는 점유권이 소멸한 다. 그러나 점유를 회수한 때에는 그 러하지 아니하다(제192조). (×)

선의의 점유자라도 본권에 관한 소에 패소한 때에는 그 '소가 제기된 때로 부터' 악의의 점유자로 본다(제197조). (×)

제201조 (○)

제195조 (○)

제208조 (○)

제202조 (○)

점유자의 필요비 또는 유익비상환청 구권은 점유자가 회복자로부터 점유 물의 반환을 청구받거나 회복자에게 점유물을 반환한 때에 비로소 회복 자에 대하여 행사할 수 있다. (×)

건물의 소유자는 그가 현실적으 로 건물이나 그 부지를 점거하고 있 지 아니하고 있더라도, 그 건물의 소 유를 위하여 그 부지를 점유한다고 보아야 한다(대법원 2010.1.28. 2009다 61193). (×)

점유가 성립하기 위해서는 사실상의 지배 외에도 적어도 사실적 지배관계 를 가지려는 의사, 즉 점유설정의사 는 필요하다. (○)

점유자가 점유의 침탈을 당한 경우에 간접점유자는 그 물건을 점유자에게 반환할 것을 청구할 수 있고 점유자 가 그 물건의 반환을 받을 수 없거나 이를 원하지 아니하는 때에는 자기에 게 반환할 것을 청구할 수 있다. (○)

11. 직접점유자가 임의로 점유를 타에 양도한 경우에는 점유이전이 간접점유자의 의사에 반한다 하더라도 간접점유자의 점유가 침탈된 경우에 해당하지 않는다. ()

대법원 1993.3.9. 92다5300 (○)

12. 점유자는 소유의 의사로 평온, 공연하게, 선의이며, 과실(過失) 없이 점유한 것으로 추정한다. ()

무과실은 추정되지 않는다(제197조).
(×)

13. 진정 소유자가 자신의 소유권을 주장하여 점유자를 상대로 소유권이전등기의 말소등기청구소송을 제기하여 점유자의 패소로 확정된 경우, 그 소송의 제기시부터는 점유자의 점유가 타주점유로 전환된다. ()

점유자의 토지에 대한 점유는 패소 판결 확정 후 부터는 타주점유로 전환된다(대법원 2000.12.8. 2000다14934).
(×)

14. 공동상속인의 1인이 상속재산인 부동산을 전부 점유한다고 하더라도 달리 특별한 사정이 없는 한 다른 공유자의 지분비율의 범위에서는 타주점유로 보아야 한다. ()

대법원 2008.9.25. 2008다31485 (○)

◎ 단원별 출제경향

구 분	28회	29회	30회	31회	32회	33회	34회
소유권	5	5	3	5	7	5	5

제1절 상린관계

(1) 상린관계와 지역권의 비교

구 분	상 린 관 계	지 역 권
성 질	소유권의 내제적 제한	독립한 용익물권
성 립	법률의 규정	법률행위
등 기	요하지 않음	등기요함
관 계	부동산이용자와 이용자 사이의 관계	두 개의 토지 사이의 관계
소멸시효	걸리지 않음	걸림
인접관계	반드시 인접을 요함	인접을 요하지 않음

(2) 상린관계 일반

- ① 인접지의 나뭇가지 경계를 넘은 때에는 그 소유자에 대하여 가지의 제거를 청구할 수 있다.
이 청구에 응하지 않으면 청구한 자가 그 가지를 제거할 수 있다.
- ② 인접지의 나무뿌리가 경계를 넘은 때에는 임의로 제거할 수 있다.
- ③ 건물을 축조함에는 특별한 관습이 없으면 경계로부터 반미터 이상의 거리를 두어야 한다.
이러한 거리를 두지 않고 건물을 축조한 자에 대하여는 건물의 변경 또는 철거를 청구할 수 있다.
그러나 건축에 착수한 후 1년을 경과하거나 건물이 완성된 후에는 손해배상만을 청구할 수 있다.

- ④ 우물을 파거나 용수·하수 또는 오물 등을 저장할 지하시설을 하는 때에는 경계로부터 2미터 이상의 거리를 두어야 한다.
- ⑤ 저수지·구거 또는 지하실공사에는 경계로부터 그 깊이의 반 이상의 거리를 두어야 한다. 이러한 공사를 함에는 토지가 붕괴하거나 하수 또는 오액이 이웃에 흐르지 않도록 적당한 조치를 하여야 한다.
- ⑥ 어느 토지와 공로 사이에 그 토지의 용도에 필요한 통로가 없는 경우에 그 토지소유자는 공로에 출입하기 위하여 이웃 토지를 통행할 수 있고, 필요한 경우에는 통로를 개설할 수도 있다.

제2절 취득시효

01 부동산의 점유취득시효

(1) 요건

- ① 20년간 소유의 의사로 평온·공연하게 점유하고 등기함으로써 소유권을 취득한다(제245조 제1항).
점유자는 소유의 의사로 평온·공연하게 점유한 것으로 추정되므로 취득시효 주장자의 소유의 의사·평온·공연은 추정을 받으며, 선의·악의는 묻지 않는다.
- ② 자기의 소유물에도 시효취득이 인정된다는 것이 판례이다.
- ④ 점유취득시효에 있어서는 부동산의 일부에 대한 시효취득도 인정된다.
- ⑤ 취득시효가 완성된 이후 제3자의 명의로 이전등기가 된 경우에는 그 자가 악의자라 하더라도 취득시효의 완성으로 대항하지 못한다. 다만, 부동산을 취득한 제3자가 매도인의 불법행위에 적극 가담하였다면 매도인의 배임행위에 적극 가담한 이중매매로서 무효가 된다.
- ⑥ 취득시효기간의 만료 전에 제3자의 명의로 이전등기가 된 경우라 하더라도 취득시효의 완성에는 영향을 미치지 않는다. 따라서 시효취득완성자는 그 기간만료 당시의 등기명의자인 제3자를 상대로 취득시효를 주장하여 소유권이전등기를 청구할 수 있다.
- ⑦ 국유재산 가운데 행정재산이 아닌 사적 거래의 대상이 되는 일반재산은 시효취득의 대상이 된다.

(2) 효과

- ① 취득시효는 법률의 규정에 의한 물건변동이지만 예외적으로 등기하여야 소유권을 취득한다.
- ② 등기를 하면 점유를 개시한 때에 소급하여 그 부동산의 소유권을 원시적으로 취득한다(제247조 제1항).

02 부동산의 등기부취득시효

(1) 요건

- ① 부동산의 소유자가 아닌 자가 소유자로 등기하고 10년간 소유의 의사로 평온·공연하게 선의·무과실로 그 부동산을 점유한 때에는 소유권을 취득한다(제245조 제2항).
- ② 부동산의 비소유자가 소유자로 등기되어 있고(ex. 소유권이전등기 후에 매매계약이 취소된 경우) 그 점유는 10년간 계속되어야 한다. 점유기간은 전주(前主)의 점유와 합산할 수 있으나(제199조 제1항), 등기기간에 관하여는 그러한 규정이 없다. 판례는 10년간이란 반드시 자기 명의로 등기되어야 하는 것은 아니고 전주(前主)의 등기기간을 합산하여 10년이 되면 된다고 한다(전합 1989.12.26. 87다카2176).
따라서 등기의 승계를 인정한다.
- ③ 소유의 의사로 평온·공연·선의·무과실로 점유하여야 한다. 무과실은 추정되지 않으므로 시효취득을 주장하는 자가 무과실을 증명하여야 한다. 그리고 선의·무과실은 점유개시시에만 있으면 충분하고, 전(全) 시효기간을 통하여 계속될 필요는 없다.

(2) 효과

점유자는 점유를 개시한 때에 소급하여 부동산의 소유권을 원시적으로 취득한다(제247조 제1항).

03 동산의 취득시효

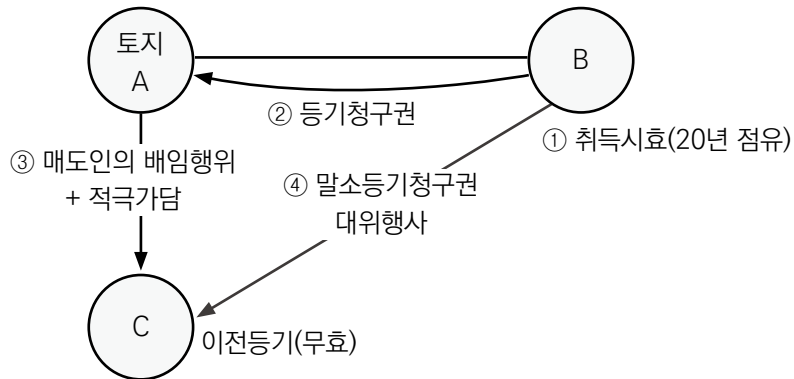
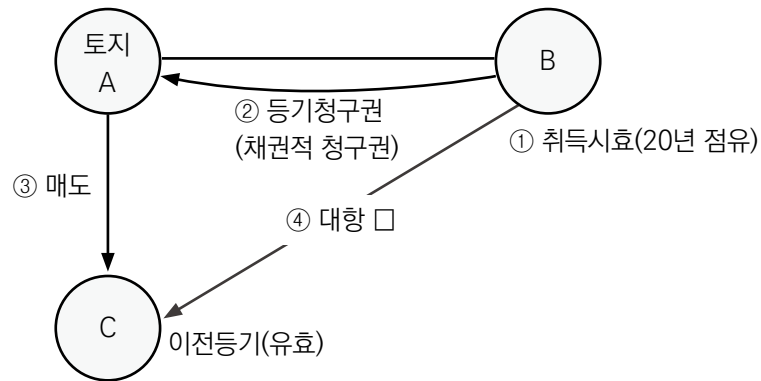
(1) 점유취득시효

10년간 소유의 의사로 평온·공연하게 점유하면 소유권을 취득한다(제246조 제1항).

(2) 선의취득시효

5년간 소유의 의사로 평온·공연·선의·무과실로 점유하면 소유권을 취득한다(제246조 제2항).

◆ 시효취득자와 제3자와의 관계



제3절 공동소유

(1) 공유의 성립

① 지분의 비율

각 공유자의 지분의 비율은 공유자의 의사표시 또는 법률의 규정에 의하여 정하여지나 불명확한 경우에는 균등한 것으로 추정된다(제262조 제2항).

② 지분의 탄력성

공유자 중 어느 한 사람이 그의 지분을 포기하거나, 상속인 없이 사망한 때에는 그 자의 지분은 다른 공유자에게 각 지분의 비율로 귀속한다(제267조).

③ 공유물의 이용관계

㉠ 공유자는 공유물 전부를 지분의 비율로 사용·수익할 수 있다(제263조 후단).

㉡ 공유물의 관리행위, 즉 목적물의 이용 및 개량을 목적으로 하는 행위는 지분의 과반수로써 결정한다(제265조 본문). 그러나 보존행위는 각자가 단독으로 할 수 있다(제265조 단서).

㉢ 다른 공유자의 동의 없이 공유물을 처분하거나 변경하지 못한다(제264조).

다른 공유자의 동의 없이 처분을 한 경우에는 그 처분은 무효이다.

㉣ 공유물의 관리비용 기타 의무는 공유자가 그 지분의 비율로 부담한다(제266조 제1항).

공유자가 1년 이상 그 의무의 이행을 지체한 때에는 타 공유자는 상당한 가액으로 지분을 매수할 수 있다(제266조 제2항). 이 매수청구권은 일종의 형성권이다.

㉤ 공유자는 지분을 자유로이 처분할 수 있다(제263조 전단).

즉, 지분의 양도·담보제공(저당권의 설정 등)·포기 등을 자유로이 할 수 있다.

다만 용익물권의 설정과 같은 처분은 공유물 전체의 처분이 되므로 단독으로 하지 못한다.

(2) 공유의 외부관계

① 반환청구

공유자는 그의 지분의 비율에 따른 점유의 반환을 청구할 수 있을 뿐 아니라 그 지분에 기하여 단독으로 모든 공유자를 위하여 자기에게 전부의 인도를 청구할 수 있다.

② 방해제거청구

제3자가 공유물에 대하여 방해하는 때에는 각 공유자는 단독으로 공유물 전부에 대한 방해제거청구를 할 수 있다.

(3) 공유물의 분할

① 분할의 자유와 금지

㉠ 각 공유자는 언제든지 공유물의 분할을 청구할 수 있다(제268조 제1항).

그러나 특약에 의하여 5년을 넘지 않는 한도에서 불분할특약을 맺을 수 있다(제268조 제2항).

㉡ 공유물 불분할특약은 등기되어 있을 때에만 지분의 양수인에게 그 효력이 미친다.

② 분할의 방법

㉠ 각 공유자는 언제든지 공유물의 분할을 청구할 수 있다(제268조 제1항).

이 분할청구권은 일종의 형성권이다. 분할의 방법은 협의분할과 재판상 분할이 있다.

㉡ 협의분할의 경우에는 현물분할이 원칙이며, 예외적으로 대금분할과 가격배상에 따른 분할이 있다.

재판상 분할의 경우에도 현물분할이 원칙이며, 예외적으로 대금분할에 의한다.

③ 분할의 효과

분할로 어떤 공유자가 취득한 부분에 하자가 있을 때에는 다른 공유자는 매도인의 담보책임을 진다.

* 공유 · 합유 · 총유의 비교

형태 내용	공 유	합 유	총 유
인 적 결합형태	공동소유자 사이에 아무런 인적 결합관계가 없는 개인주의적인 소 유형태 ex) 1필지 토지를 여러 사람이 공동으로 매수하는 경우	조합체(제271조) ex) 공장을 함께 경영할 목적으로 여러 사람이 공동으로 토지를 매수하는 경우	권리능력 없는 사단(제275조) ex) 문중 또는 종중이 선산을 매수하는 경우
지분의 처분	각 공유자는 그 지분을 자유롭게 처분할 수 있다(제263조).	조합원 이외의 제3자의 침입을 방지 하기 위하여 지분의 처분 등은 제한된 다(제277조).	지분을 갖지 못한다.
분할청구	각 공유자는 언제든지 분할을 청 구하여 공유관계를 종료시킬 수 있다 (제268조).	합유관계가 존속하는 한 합유물의 분 할은 청구할 수 없다. 다만, 조합이 해 산한 경우에는 청산절차에 따라 합유 물을 분할하여 각 조합원에게 분배할 수 있다.	할 수 없다.
보존행위	각자 단독으로 할 수 있다.	각자 단독으로 할 수 있다.	사원총회의 결의에 의한다.
관리행위	지분의 과반수로 결정한다.	조합계약 기타 규약의 정함에 따른다.	사원총회의 결의에 의한다.
사용·수익	지분의 비율로 사용한다.	조합계약 기타 규약의 정함에 따른다.	정관 기타 규약의 정함에 따른다.
처분·변경	공유자 전원의 동의가 있어야 한다.	합유자 전원의 동의가 있어야 한다.	사원총회의 결의가 있어야 한다.
등기방식	공유자 전원의 명의로 등기하되 그 지분을 기재한다.	합유자 전원의 명의로 등기하되 합유 의 취지를 기재하여야 한다.	권리능력 없는 사단 자체의 명의로 등기하나 대표자의 이름을 첨기한다.



핵심 판례 정리

- 01.** 주위토지통행권은 현재의 토지의 용법에 따른 이용의 범위에서 인정되는 것이지 더 나아가 장차의 이용상황까지를 미리 대비하여 통행로를 정할 수는 없다.
- 02.** 주위토지통행권은 어떤 통로가 이미 있더라도 그 통로가 당해 토지의 이용에 부적합하여 실제로 통로로서의 충분한 기능을 하지 못하고 있는 경우에도 인정될 수 있다.
- 03.** 주위토지통행권은 이미 그 소유 토지의 용도에 필요한 통로가 있는 경우에는 그 통로를 사용하는 것보다 더 편리하다는 이유만으로 다른 장소로 통행할 권리를 인정할 수 없다.
- 04.** 통행에 대한 보상의 의무가 없다고 하는 민법 제220조의 규정은 직접 분할자, 일부 양도의 당사자 사이에만 적용되고 포위된 토지 또는 피통행지의 특정승계인의 경우에는 주위토지통행권에 관한 민법 제219조의 일반원칙으로 돌아가 통행권의 유무를 가려야 한다.
- 05.** 명의신탁에 의하여 부동산의 소유자로 등기된 자의 점유는 그 권원의 성질상 자주점유라 할 수 없다.
[판례해설] 명의수탁자의 점유는 자주점유가 아니므로 명의수탁자는 취득시효를 주장하지 못한다.
- 06.** 등기부취득시효에 있어서 선의, 무과실은 등기에 관한 것이 아니고 점유취득에 관한 것으로서, 그 무과실에 관한 증명책임은 그 시효취득을 주장하는 사람에게 있다.
- 07.** 취득시효완성 후에 그 사실을 모르고 당해 토지에 관하여 어떠한 권리도 주장하지 않기로 하였다 하더라도 이에 반하여 시효주장을 하는 것은 특별한 사정이 없는 한 신의칙상 허용되지 않는다.
- 08.** 부동산에 대한 취득시효가 완성되면 점유자는 소유명의자에 대하여 취득시효완성을 원인으로 한 소유권 이전등기절차의 이행을 청구할 수 있고 소유명의자는 이에 응할 의무가 있으므로 점유자가 그 명의로 소유권이전등기를 경료하지 아니하여 아직 소유권을 취득하지 못하였다고 하더라도 소유명의자는 점유자에 대하여 점유로 인한 부당이득반환청구를 할 수 없다.
- 09.** 등기부취득시효에 의하여 소유권을 취득하는 자는 10년간 반드시 그의 명의로 등기되어 있어야 하는 것은 아니고 앞 사람의 등기까지 아울러 그 기간 동안 부동산의 소유자로 등기되어 있으면 된다.
- 10.** 취득시효를 주장하는 자는 점유기간 중에 소유자의 변동이 없는 토지에 관하여는 취득시효의 기산점을 임의로 선택할 수 있고, 이는 취득시효완성 후 토지소유자에 변동이 있어도 당초의 점유자가 계속 점유하고 있고 소유자가 변동된 시점을 새로운 기산점으로 삼아 취득시효의 완성을 주장할 수 있다.

11. 부동산에 대한 점유취득시효가 완성되었다고 하더라도 이를 등기하지 아니하고 있는 사이에 그 부동산에 관하여 제3자에게 소유권이전등기가 마쳐지면 점유자는 그 제3자에게 대항할 수 없는 것이고, 이 경우 제3자의 이전등기 원인이 점유자의 취득시효완성 전의 것이라 하더라도 마찬가지이다.

12. 부동산에 관한 취득시효가 완성된 후 취득시효를 주장하거나 이로 인한 소유권이전등기청구를 하기 이전에는 등기명의인인 부동산소유자로서는 특별한 사정이 없는 한 시효취득사실을 알 수 없는 것이므로 이를 제3자에게 처분하였다 하더라도 불법행위가 성립할 수 없다할 것이나, 시효취득을 주장하는 권리자가 취득시효를 주장하면서 소유권이전등기청구소송을 제기하여 그에 관한 입증까지 마쳤다면 부동산소유자로서는 시효취득사실을 알 수 있다 할 것이고 이러한 경우에 부동산소유자가 부동산을 제3자에게 처분하여 소유권이전등기를 넘겨줌으로써 취득시효완성을 원인으로 한 소유권이전등기의무가 이행불능에 빠짐으로써 시효취득을 주장하는 자가 손해를 입었다면 불법행위를 구성한다고 할 것이며, 부동산을 취득한 제3자가 부동산소유자의 이와 같은 불법행위에 적극 가담하였다면 이는 사회질서에 반하는 행위로서 무효라 할 것이다.

13. 부동산에 대한 점유로 인한 소유권취득시효가 완성되었다 하더라도 이를 등기하지 않고 있는 사이에 그 부동산에 관하여 제3자에게로 소유권이전등기가 경료되면 점유자가 그 제3자에게는 그 시효취득으로 대항할 수 없으나, 그로 인하여 점유자가 취득시효완성 당시의 소유자에 대한 시효취득으로 인한 소유권이전등기청구권을 상실하게 되는 것은 아니고 위 소유자의 점유자에 대한 소유권이전등기의무가 이행불능으로 된 것이라고 할 것인데, 그 후 어떠한 사유로 취득시효완성 당시의 소유자에게로 소유권이 회복되면 그 소유자에게 시효취득의 효과를 주장할 수 있다.

14. 부동산을 취득시효기간 만료 당시의 점유자로부터 양수하여 점유를 승계한 현 점유자는 전 점유자의 소유자에 대한 소유권이전등기청구권을 대위행사할 수 있을 뿐, 전 점유자의 취득시효 완성의 효과를 주장하여 직접 자기에게 소유권이전등기를 청구할 권원은 없다.

15. 민법 제245조 제2항이 정한 등기부취득시효의 요건인 '부동산의 소유자로 등기한 자'에서 말하는 등기는 적법·유효한 등기일 필요는 없고 무효의 등기라도 관계없다.

16. 상속에 의하여 점유권을 취득한 경우에는 상속인은 새로운 권원에 의하여 자기 고유의 점유를 개시하지 않는 한 피상속인의 점유를 떠나 자기만의 점유를 주장할 수 없다.

17. 과반수 지분의 공유자로부터 사용·수익을 허락받은 점유자에 대하여 소수 지분의 공유자는 그 점유자가 사용·수익하는 건물의 철거나 퇴거 등 점유배제를 구할 수 없다.

18. 과반수 지분의 공유자로부터 다시 그 특정 부분의 사용·수익을 허락받은 제3자의 점유는 적법한 점유이므로 그 제3자는 소수지분권자에 대하여 그 점유로 인하여 법률상 원인 없이 이득을 얻고 있다고 볼 수 없다.

- 19.** 공유물의 소수지분권자가 다른 공유자와 협의 없이 공유물의 전부 또는 일부를 독점적으로 점유·사용하고 있는 경우, 다른 소수지분권자가 공유물의 보존행위로서 공유물의 인도를 청구할 수는 없다(대법원 2020.5.21. 2018다287522 전원합의체).
- 20.** 공유물의 분할은 당사자 간에 협의가 이루어지는 경우에는 그 방법을 임의로 선택할 수 있으나 협의가 이루어지지 아니하여 재판에 의하여 공유물을 분할하는 경우에는 법원은 현물로 분할하는 것이 원칙이고, 현물로 분할할 수 없거나 현물로 분할을 하게 되면 현저히 그 가액이 감소될 염려가 있는 때에 비로소 물건의 경매를 명할 수 있다.
- 21.** 공유 토지를 현물분할하는 경우에 반드시 공유지분의 비율대로 토지면적을 분할해야 하는 것은 아니고 토지의 형상이나 위치, 이용 상황이나 경제적 가치 등 제반 사정을 고려하여 경제적 가치가 지분비율에 상응하도록 분할할 수 있다.
- 22.** 갑, 을의 공유인 부동산 중 갑의 지분위에 설정된 근저당권 등 담보물권은 특단의 합의가 없는 한 공유물 분할이 된 뒤에도 종전의 지분비율대로 공유물 전부의 위에 그대로 존속하고 근저당권설정자인 갑 앞으로 분할된 부분에 당연히 집중되는 것은 아니다.
[판례해설] 지분권의 효력은 목적물 전부위에 그 효력이 미치므로 그러한 결과가 된다.
- 23.** 공유물분할청구의 소는 분할을 청구하는 공유자가 원고가 되어 다른 공유자 전부를 공동피고로 하여야 하는 고유필수적 공동소송이다.
- 24.** 공유자 중 1인의 단독 명의로 마쳐진 원인무효의 소유권이전등기에 관하여 다른 공유자가 등기명의인인 공유자를 상대로 말소등기절차의 이행을 구할 수 있는 범위는 등기명의인인 공유자의 공유지분을 제외한 나머지 공유지분 전부이다.
- 25.** 민법 제267조는 “공유자가 그 지분을 포기하거나 상속인 없이 사망한 때에는 그 지분은 다른 공유자에게 각 지분의 비율로 귀속한다.”라고 규정하고 있다. 여기서 공유지분의 포기는 법률행위로서 상대방 있는 단독행위에 해당하므로, 부동산 공유자의 공유지분 포기의 의사표시가 다른 공유자에게 도달하더라도 이로써 곧바로 공유지분 포기에 따른 물건변동의 효력이 발생하는 것은 아니고, 다른 공유자는 자신에게 귀속될 공유지분에 관하여 소유권이전등기청구권을 취득하며, 이후 민법 제186조에 의하여 등기를 하여야 공유지분 포기에 따른 물건변동의 효력이 발생한다(대법원 2016.10.27. 2015다52978).
- 26.** 부동산의 공유자의 1인은 당해 부동산에 관하여 제3자 명의로 원인무효의 소유권이전등기가 경료되어 있는 경우 공유물에 관한 보존행위로서 제3자에 대하여 그 등기 전부의 말소를 구할 수 있다.

- 27.** 3자간 등기명의신탁에서 명의수탁자가 제3자에게 부동산을 매도하거나 부동산에 근저당권을 설정하는 등으로 처분행위를 하여 제3자가 부동산에 관한 권리를 취득하는 경우, 명의신탁자가 명의수탁자를 상대로 직접 부당이득반환을 청구할 수 있다(대법원 2021.9.9. 2018다284233 전원합의체).
- 28.** 명의신탁약정이 3자간 등기명의신탁인지 아니면 계약명의신탁인지의 구별은 계약당사자가 누구인가를 확정하는 문제로 귀결되는데, 계약명의자가 명의수탁자로 되어 있다 하더라도 계약당사자를 명의신탁자로 볼 수 있다면 이는 3자간 등기명의신탁이 된다. 따라서 계약명의자인 명의수탁자가 아니라 명의신탁자에게 계약에 따른 법률효과를 직접 귀속시킬 의도로 계약을 체결한 사정이 인정된다면 명의신탁자가 계약당사자이고, 이 경우의 명의신탁관계는 3자간 등기명의신탁으로 보아야 한다(대법원 2021.9.9. 2018다284233 전원합의체).
- 29.** 구분소유적 공유자가 그 권리를 타인에게 처분하는 경우에는 구분소유의 목적인 특정 부분을 처분하면서 등기부상 공유지분을 그 특정 부분에 대한 표상으로서 이전하는 경우와 등기부의 기재대로 1필지 전체에 대한 진정한 공유지분을 처분하는 경우가 있을 수 있다. 전자의 경우에는 구분소유적 공유관계가 승계되나, 후자의 경우에는 그 매수인이 부동산 전체에 대한 공유지분을 취득하고, 구분소유적 공유관계는 소멸된다.(대법원 2022. 3. 31. 2021다215589, 215596).
- 30.** 공유자는 공유물 전부를 지분의 비율로 사용·수익할 수 있으므로 공유토지의 일부를 배타적으로 점유하면서 사용·수익하는 공유자는 그가 보유한 공유지분의 비율에 관계없이 다른 공유자에 대하여 부당이득반환의무를 부담한다. 그런데 일반 건물에서 대지를 사용·수익할 권원이 건물의 소유권과 별개로 존재하는 것과는 달리, 집합건물의 경우에는 대지사용권인 대지지분이 구분소유권의 목적인 전유부분에 종속되어 일체화되는 관계에 있으므로, 집합건물 대지의 공유관계에서는 이와 같은 민법상 공유물에 관한 일반 법리가 그대로 적용될 수 없고, 이는 대지 공유자들 중 구분소유자 아닌 사람이 있더라도 마찬가지이다(대법원 2022.8.25. 2017다257067 전원합의체).
- 31.** 집합건물에서 전유부분 면적 비율에 상응하는 적정 대지지분을 가진 구분소유자는 그 대지 전부를 용도에 따라 사용·수익할 수 있는 적법한 권원을 가지므로, 구분소유자 아닌 대지 공유자는 그 대지 공유지분권에 기초하여 적정 대지지분을 가진 구분소유자를 상대로는 대지의 사용·수익에 따른 부당이득반환을 청구할 수 없다(대법원 2022.8.25. 2017다257067 전원합의체).



중요 지문 정리

- 01.** 포위된 토지가 사정변경에 의하여 공로에 접하게 되거나 포위된 토지 소유자가 주위의 토지를 취득함으로써 주위토지통행권을 인정할 필요성이 없어지게 된 경우에는 통행권은 당연히 소멸한다. ()

대법원 2014.12.24 2013다11669 (○)
- 02.** 어느 토지가 타인 소유의 토지에 둘러싸여 공로에 통할 수 없는 경우뿐만 아니라, 별도의 진입로가 이미 있다고 하더라도 그 진입로로 통로를 개설하는 데 과다한 비용을 요하는 때에는 민법 제219조에 의한 주위토지통행권이 인정될 수 있다. ()

대법원 2013.2.14 2012마1427 (○)
- 03.** 분할로 인하여 공로에 통하지 못하는 토지가 있는 때에는 그 토지소유자는 공로에 출입하기 위하여 다른 분할자의 토지를 통행할 수 있고, 이 경우에는 보상의 의무가 없다. ()

제220조 (○)
- 04.** 인접하여 토지를 소유한 자들이 통상의 담을 설치하는 경우 다른 관습이 없으면 그 설치비용은 소유토지의 면적에 관계없이 쌍방이 절반씩 부담한다. ()

제237조 (○)
- 05.** 인접지의 수목뿌리가 경계를 넘은 때에는 임의로 제거할 수 없고 수목 소유자에게 제거청구를 하여야 한다. ()

인접지의 수목뿌리가 경계를 넘은 때에는 임의로 제거할 수 있다(제240조). (×)
- 06.** 동산의 소유권은 점유의 이전에 따라 변동되는 것이므로 동산에 관하여는 점유취득시효에 관한 규정이 적용되지 않는다. ()

10년간 소유의 의사로 평온, 공연하게 동산을 점유한 자는 그 소유권을 취득한다(제246조). (×)
- 07.** 미등기 부동산의 경우에는 점유취득시효가 완료되면 등기없이도 점유자가 소유권을 취득한다. ()

미등기 부동산의 경우라 하여 취득시효 기간의 완성만으로 등기 없이도 점유자가 소유권을 취득한다고 볼 수 없다(대법원 2006다22074). (×)
- 08.** 간이인도에 의한 동산의 선의취득은 인정되지 않지만, 점유개정의 방법에 의한 동산의 선의취득은 인정된다. ()

점유개정에 의한 선의취득은 인정되지 않는다. (×)
- 09.** 동산과 동산이 부합하여 훼손하지 아니하면 분리할 수 없거나 그 분리에 과다한 비용을 요할 경우에는 그 합성물의 소유권은 주된 동산의 소유자에게 속한다. 부합한 동산의 주종을 구별할 수 없는 때에는 동산의 소유자는 부합당시의 가액의 비율로 합성물을 공유한다. ()

제257조 (○)

10. 매장물은 법률에 정한 바에 의하여 공고한 후 1년 내에 그 소유자가 권리를 주장하지 아니하면 발견자가 그 소유권을 취득하나, 타인의 토지 기타 물건 으로부터 발견한 매장물은 그 토지 기타 물건의 소유자와 발견자가 절반하 여 취득한다. ()

제254조 (○)

11. 유실물은 법률에 정한 바에 의하여 공고한 후 6개월 내에 그 소유자가 권리 를 주장하지 아니하면 습득자가 그 소유권을 취득한다. ()

제253조 (○)

12. 무주의 부동산 및 동산은 국유로 한다. ()

무주의 부동산은 국유로 한다(제252 조). (×)

13. 타인의 동산에 가공한 때에는 그 물건의 소유권은 가공자에게 속한다. 그 러므로 가공으로 인한 가액의 증가가 원재료의 가액보다 현저히 다액인 때 에도 마찬가지다. ()

타인의 동산에 가공한 때에는 그 물 건의 소유권은 원재료의 소유자에게 속한다. 그러나 가공으로 인한 가액 의 증가가 원재료의 가액보다 현저히 다액인 때에는 가공자의 소유로 한 다(제259조). (×)

14. 건물의 증축 부분이 기존건물에 부합하여 기존건물과 분리하여서는 별개 의 독립물로서의 효용을 갖지 못하는 이상 기존건물에 대한 근저당권은 민 법 제358조에 의하여 부합된 증축 부분에도 효력이 미치는 것이므로 기존 건물에 대한 경매절차에서 경매목적물로 평가되지 아니하였다고 할지라도 경락인은 부합된 증축 부분의 소유권을 취득한다. ()

대법원 2002.10.25. 2000다63110 (○)

15. 부동산에 부합된 물건이 사실상 분리복구가 불가능하여 거래상 독립된 권 리의 객체성을 상실하고 그 부동산과 일체를 이루는 부동산의 구성부분이 된 경우에는 타인의 권원에 의하여 이를 부합시킨 경우에도 그 물건의 소유 권은 부동산의 소유자에게 귀속된다. ()

대법원 2008.5.8. 2007다36933. (○)

16. 합유물의 보존행위, 처분 또는 변경함에는 합유자 전원의 동의가 있어야 한 다. ()

합유물을 처분 또는 변경함에는 합 유자 전원의 동의가 있어야 하지만, 보존행위는 각자가 단독으로 할 수 있다. (×)

17. 비법인사단이 타인 간의 금전채무를 보증하는 행위는 총유물 그 자체의 관 리·처분이 따르지 아니하는 단순한 채무부담행위에 불과하여 이를 총유물 의 관리·처분행위라고 볼 수는 없다. ()

대법원 2007.4.19. 2004다600 (○)

18. 공유자가 공유물을 타인에게 임대하는 행위 및 그 임대차계약을 해지하는 행위는 공유물의 관리행위에 해당하므로 공유자 지분의 과반수로써 결정 하여야 한다. ()

타당한 기술이다. (○)

19. 부동산 공유자가 그 지분을 포기한 경우 다른 공유자들은 민법 제187조에 따라登記 없이 부동산 물권을 취득한다. ()

20. 과반수의 지분을 가진 공유자라고 하더라도, 다른 공유자와 공유물 관리방법에 관한 협의를 하지 않고 그 공유물을 자신이 배타적으로 사용·수익하기로 정할 수는 없다. ()

21. 재판에 의하여 공유물을 분할하는 경우에는 법원은 현물로 분할하는 것이 원칙이고, 현물로 분할할 수 없거나 현물로 분할을 하게 되면 현저히 그 가액이 감소될 염려가 있는 때에 비로소 물건의 경매를 명하여 대금분할을 할 수 있다. ()

22. 부동산의 일부 공유지분에 관하여 저당권이 설정된 후 그 부동산이 분할된 경우, 그 저당권은 분할된 각 부동산 위에 종전의 지분비율대로 존속하고, 분할된 각 부동산은 그 저당권의 공동담보가 된다. ()

23. 공유자가 그 지분을 포기하거나 상속인 없이 사망한 때에는 그 지분은 다른 공유자에게 균등하게 귀속한다. ()

24. 공유물의 소수지분권자가 다른 공유자와 협의 없이 공유물의 전부 또는 일부를 독점적으로 점유·사용하고 있는 경우, 다른 소수지분권자가 공유물의 보존행위로서 공유물의 인도를 청구할 수 있다. ()

25. 부동산의 합유자 중 일부가 사망한 경우 합유자 사이에 특별한 약정이 없는 한 사망한 합유자의 상속인이 그 지분을 승계한다. ()

26. 공유물에 관한 보존행위는 공유자 각자가 할 수 있고, 이는 합유물도 마찬가지이다. 그러나 총유물에 관한 보존행위로서 소송을 하는 경우에는 총회의 결의를 거치거나 정관이 정하는 바에 따른 절차를 거쳐야만 한다. ()

공유지분 포기의 의사표시가 다른 공유자에게 도달하더라도 186조(부동산물권변동의 효력)에 의하여 등기를 하여야 물권변동의 효력이 발생한다. (×)

과반수의 지분을 가진 공유자는 다른 공유자와 사이에 미리 공유물의 관리방법에 관한 협의가 없었다 하더라도 공유물의 관리에 관한 사항을 단독으로 결정할 수 있으므로, 과반수의 지분을 가진 공유자가 그 공유물의 특정 부분을 배타적으로 사용·수익하기로 정하는 것은 공유물의 관리방법으로서 적법하다(대법원 2001.11.27. 2000다33638). (×)

타당한 기술이다. (○)

대법원 2012.3.29 2011다74932 (○)

제267조 (×)

대법원 2020.9.7. 2017다204810 (×)

부동산의 합유자 중 일부가 사망한 경우 합유자 사이에 특별한 약정이 없는 한 사망한 합유자의 상속인은 합유자로서의 지위를 승계하지 못하므로, 해당 부동산은 잔존 합유자가 2인 이상일 경우에는 잔존 합유자의 합유로 귀속되고 잔존 합유자가 1인인 경우에는 잔존 합유자의 단독소유로 귀속된다(대법원 1996.12.10. 96다23238). (×)

대법원 2014.2.13 2012다112299 (○)

27. 법인이 아닌 사단의 사원이 집합체로서 물건을 소유할 때에는 합유로 한다.
()

28. 부부간 명의신탁이 일단 유효한 것으로 인정되었다면 그 후 배우자 일방의 사망으로 부부관계가 해소되었더라도 그 명의신탁은 사망한 배우자의 다른 상속인과의 관계에서도 여전히 유효하게 존속한다고 보아야 한다. ()

29. 부동산 실권리자명의 등기에 관한 법률상 양자간 명의신탁약정에 따라 명의수탁자 명의로 등기를 한 경우 이는 불법원인급여로서 명의신탁자는 명의수탁자를 상대로 등기말소를 청구할 수 없다. ()

30. 명의신탁자와 명의수탁자의 명의신탁약정에 기하여 명의수탁자 앞으로 부동산소유권이전등기가 마쳐진 후 명의수탁자가 이를 새로운 이해관계를 가진 제3자에게 처분한 경우에는 그 제3자에 대하여 명의신탁약정의 무효를 이유로 대항하지 못한다. ()

법인이 아닌 사단의 사원이 집합체로서 물건을 소유할 때에는 총유로 한다. (×)

대법원 2013.1.24. 2011다99498 (○)

부동산 실권리자명의 등기에 관한 법률을 위반하여 무효인 명의신탁약정에 따라 명의수탁자 명의로 등기를 한 경우, 명의신탁자가 명의수탁자를 상대로 그 등기의 말소를 구하는 것이 불법원인급여를 이유로 금지되는지 여부에 대하여 판례는 불법원인급여에 해당하지 않는다고 한다(대법원 2019.6.20. 2013다218156). (×)

타당한 기술이다. (○)

◎ 단원별 출제경향

구 분	28회	29회	30회	31회	32회	33회	34회
용익물권	3	5	3	3	4	5	4

제1절 지상권

(1) 의의

건물 기타의 공작물(도로·교량·광고탑·전주·지하철·터널 등)이나 수목을 소유하기 위하여 타인의 토지를 사용할 수 있는 용익물권을 말한다.

(2) 법률적 성질

- ① 지상권의 객체인 토지는 1필의 토지의 일부 위에도 설정될 수 있다.
- ② 건물 기타의 공작물이나 수목의 소유를 목적으로 하는 권리이다.
- ③ 지상권은 물건으로서 양도성과 상속성이 있다.
- ④ 지료의 지급은 지상권성립의 요소가 아니다. 따라서 무상(無償)의 지상권도 설정이 가능하다.

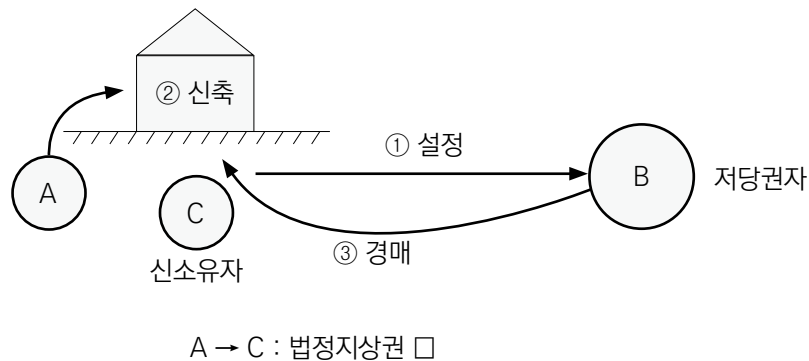
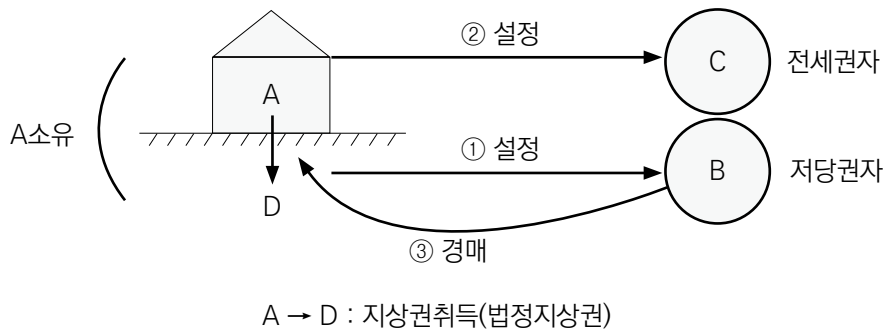
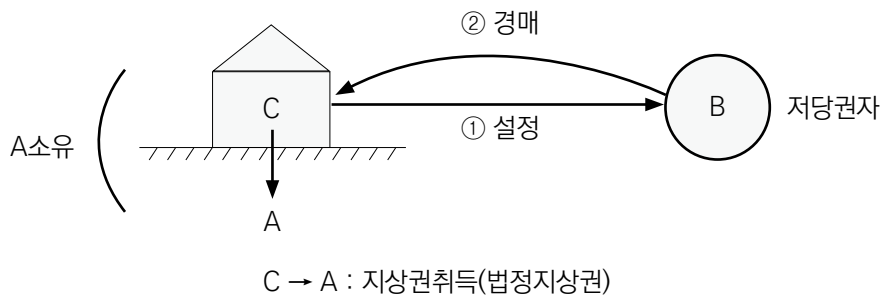
(3) 지상권의 취득

법률행위로 인한 취득	① 지상권설정의 물건적 합의와 등기에 의한 취득 ② 지상권의 양도에 의한 취득
법률의 규정에 의한 취득	① 상속·판결·경매·공용징수·취득시효 등에 의한 취득 ② 법정지상권에 의한 취득 ㉠ 대지와 건물이 동일소유자에게 속한 경우에 건물에 전세권을 설정한 때에는 그 대지소유권의 특별승계인은 전세권설정자에 대하여 지상권을 설정한 것으로 본다(제305조). ㉡ 저당물의 경매로 인하여 토지와 그 지상건물이 다른 소유자에게 속한 경우에는 토지소유자는 건물소유자에 대하여 지상권을 설정한 것으로 본다(제366조). * 법정지상권의 성립요건 ㊸ 저당권설정 당시에 건물이 존재할 것 ㊹ 저당권설정 당시 토지와 건물이 동일소유자에게 속할 것

**법률의 규정에
의한 취득**

- ㉔ 경매의 결과로 입목소유자와 토지소유자가 다르게 된 경우
입목소유자는 법정지상권을 취득한 것으로 본다(입목법 제6조).
 - ㉕ 토지와 건물이 동일소유자에게 속하는 경우, 그 토지 또는 건물에만 가등기담보·양도담보·매도담보 등이 설정되고 이들의 실행으로 토지와 건물의 소유자가 다르게 된 때 토지 소유자는 건물소유자에 대하여 지상권을 설정한 것으로 본다.
- * 법정지상권의 취득은 등기를 요하지 않으나 제3자에게 처분하기 위해서는 등기를 하여야 한다.
- * 법정지상권에 관한 규정은 강행규정이므로 당사자의 특약으로 그 성립을 막지 못한다.

◆ 법정지상권의 취득



(4) 관습법상의 법정지상권

토지와 건물이 동일 소유자에게 속하였다가 그 중 하나가 매매 기타의 원인(증여, 공매, 대물변제 등)으로 양자의 소유자가 다르게 되었을 때는, 특히 그 건물을 철거한다는 합의가 없는 한 그 건물의 소유자는 그 토지 위에 관습법상의 법정지상권을 취득하게 된다.

제2절 지역권

(1) 의의

설정행위로써 정한 일정한 목적(통행, 인수, 관망 등)을 위하여 타인의 토지를 자기의 토지의 편익에 이용하는 용익물권이다. 여기서 편익을 얻는 토지를 요역지라고 하며 편익을 제공하는 토지를 승역지라고 한다.

(2) 법률적 성질

- ① 편익을 받는 것은 토지이어야 하며 ‘편익에 이용한다’는 것은 요역지의 사용가치를 증가시킨다는 것을 뜻한다.
- ② 지역권은 유상으로 하거나 무상으로 하거나 무방하다.
- ③ 지상권자·전세권자·임차인은 그들이 이용하는 토지의 편익을 위하여 그 권한 내에서 유효하게 지역권을 설정받을 수 있다.
- ④ 요역지는 1필의 토지이어야 하고 토지의 일부를 위하여 지역권을 설정할 수 없으나, 승역지는 토지의 일부라도 무방하다.
- ⑤ 요역지소유권의 처분은 지역권의 처분을 수반한다(부종성). 그러나 다른 약정이 있는 때에는 그 약정에 따른다(제292조).
- ⑥ 지역권은 요역지와 분리하여 양도하거나 다른 권리의 목적으로 하지 못한다.
- ⑦ 계속되고 표현된 지역권에 한하여 시효취득의 대상이 된다(통로가 설치된 통행지역권, 지상에 노출된 인수지역권).
- ⑧ 토지공유자의 1인은 자기의 지분에 관하여 그 토지를 위한 지역권 또는 그 토지가 부담하고 있는 지역권을 소멸하게 하지 못한다(제293조①).
- ⑨ 공유자의 1인이 지역권을 취득한 때에는 다른 공유자도 이를 취득한다(제295조①).
- ⑩ 요역지를 공유하고 있는 경우에 공유자의 1인을 위한 소멸시효의 중단 또는 정지가 있는 경우에는 그 중단 또는 정지의 사유는 다른 공유자를 위해서도 효력이 있다(제296조).
- ⑪ 요역지가 분할된 경우 승역지는 요역지의 각 부분을 위하여, 승역지가 분할된 경우 지역권은 승역지 각 부분위에 존속한다.

제3절 전세권

(1) 의의

전세금을 지급하고 타인의 부동산을 그 용도에 좇아 사용·수익하는 용익물권임과 동시에 전세금의 우선변제를 받을 수 있는 담보물권성을 가진 권리이다.

(2) 법률적 성질

- ① 타인의 토지 및 건물에 대한 권리이며, 1필의 토지 또는 1동의 건물의 일부분 위에도 설정이 가능하다. 그러나 농경지는 전세권의 목적물이 되지 못한다(제303조 제2항).
- ② 전세금의 지급은 전세권 성립의 요소이다.
- ③ 설정계약과 부동산의 용도에 좇아 사용·수익하는 물권으로서 소유권의 상린관계의 규정이 준용되며, 전세권은 양도·임대·전전세·담보로 제공할 수 있다.
- ④ 담보물권성을 가지는 권리이다. 따라서 전세권자에게 우선변제권과 경매청구권이 인정된다.

(3) 전세권의 취득과 존속기간

취득	설정계약과 등기, 전세금의 수수에 의하여 취득되며 목적부동산의 인도는 전세권성립의 요소가 아니다.
존속기간	① 최장기간 : 10년을 넘지 못한다(갱신하여도 동일). ② 최단기간 : 건물에 대한 존속기간은 1년 미만으로 하지 못한다. ③ 건물의 전세권에 있어서의 법정갱신 건물의 전세권설정자가 전세권의 존속기간 만료 전 6월부터 1월까지의 사이에 전세권자에 대하여 갱신거절의 통지나 또는 조건을 변경하지 않으면 갱신하지 않겠다는 뜻의 통지를 하지 않은 경우에는 존속기간이 만료된 때에 전전세권의 동일한 조건으로 다시 전세권을 설정한 것으로 본다(이 때 존속기간은 정하지 않은 것으로 본다). ④ 존속기간은 등기하지 않으면 제3자에게 대항력이 없으며 존속기간을 정하지 않은 것으로 다루어진다. ⑤ 전세권자에게 '계약갱신청구권'은 인정되지 않는다. ⑥ 존속기간을 정하지 않은 경우에는 언제든지 소멸통고를 할 수 있고, 소멸통고가 상대방에게 도달된 날로부터 6월이 경과하면 전세권은 소멸한다.

*** 지상권, 전세권, 임차권의 비교**

구 분	지 상 권	전 세 권	임 차 권
성 질	용익물권 절대권·대세권	용익물권+담보물권성 절대권·대세권	채권 상대권·대인권
성 립	설정계약+등기	설정계약+등기+전세금 수수	설정 계약
대 항 력	인정	인정(경매권 인정)	등기하면 인정
최장기간	제한 없음	10년	제한 없음
최단기간	· 견고한 건물, 수목-30년 · 기타 건물-15년 · 공작물-5년	· 토지전세권: 제한 없음 · 건물전세권: 1년	· 민법: 제한 없음 · 주택임대차보호법: 2년 · 상가임대차보호법: 1년
기간약정 없는 경우	최단기간으로 제한	언제든지 소멸통고	언제든지 해지통고
약정갱신	최단기간 이상으로 약정	10년을 초과할 수 없음	제한 없음
법정갱신	규정 없음	규정 있음	규정 있음
요 소	지료는 요소가 아님	반드시 전세금이 수수	차임이 요소
증감청구권	인정	인정	인정
연 체	2년 연체시 소멸청구		2기의 연체로 해지
비용청구	유익비만 가능	유익비만 가능	필요비·유익비 모두 가능
매수청구권	지상물매수청구권 인정	부속물매수청구권 인정	지상물, 부속물매수청구권 인정
양 도 성	설정자 동의 없이 양도, 임대 가능	설정자 동의 없이 양도, 전전세, 임대 가능	임대인의 동의가 있어야 양도, 전대 가능
담보제공	저당권의 목적 가능	저당권의 목적 가능	저당권의 목적 불가



핵심 판례 정리

- 01.** 저당권설정의 당사자 간의 특약으로 저당목적물인 토지에 대하여 법정지상권을 배제하는 약정을 하더라도 그 특약은 효력이 없다.
- 02.** 대지와 건물의 소유자가 건물만을 양도하고 동 양수인과 대지에 대하여 임대차계약을 체결하였다면 특별한 사정이 없는 한 양수인은 대지에 관한 관습법상의 법정지상권을 포기하였다고 본다.
- 03.** 저당권의 설정 당시 저당권의 목적이 되는 토지 위에 건물이 존재한 이상, 그 이후 건물을 개축·증축하는 경우에도 법정지상권이 성립한다.
[판례해설] 저당권의 설정 당시 저당권의 목적이 되는 토지 위에 건물이 존재한 이상, 그 건물이 미등기, 무허가 건물이거나 신축중의 건물 또는 증축이나 개축의 건물이라 하더라도 법정지상권이 성립한다.
- 04.** 토지에 관하여 저당권이 설정될 당시 토지 소유자에 의하여 그 지상에 건물을 건축 중이었던 경우 그것이 사회관념상 독립된 건물로 볼 수 있는 정도에 이르지 않았다 하더라도 건물의 규모, 종류가 외형상 예상할 수 있는 정도까지 건축이 진전되어 있었고, 그 후 경매절차에서 매수인이 매각대금을 다 낸 때까지 최소한의 기동과 지붕 그리고 주벽이 이루어지는 등 독립된 부동산으로서 건물의 요건을 갖춘 경우 법정지상권의 성립이 인정된다.
- 05.** 법정지상권을 취득한 건물소유자가 법정지상권의 설정등기를 경료함이 없이 건물을 양도하는 경우에는 건물양수인은 건물양도인을 순차 대위하여 토지소유자에 대하여 건물소유자였던 최초의 법정지상권자에게 법정지상권설정등기절차이행을 청구할 수 있다.
- 06.** 법정지상권을 가진 건물소유자로부터 건물을 양수하면서 지상권까지 양도받기로 한 사람에 대하여 대지 소유자가 건물철거 및 대지의 인도를 구하는 것은 지상의 부담을 용인하고 그 설정등기절차를 이행할 의무 있는 자가 그 권리자를 상대로 한 청구라 할 것이어서 신의성실의 원칙상 허용될 수 없다.
- 07.** 미등기건물을 그 대지와 함께 매수한 사람이 그 대지에 관하여만 소유권이전등기를 넘겨받고 건물에 대하여는 그 등기를 이전받지 못하고 있다가, 대지에 대하여 저당권을 설정하고 그 저당권의 실행으로 대지가 경매되어 다른 사람의 소유로 된 경우에는, 그 저당권의 설정 당시에 이미 대지와 건물이 각각 다른 사람의 소유에 속하고 있었으므로 법정지상권이 성립될 여지가 없다.
- 08.** 동일인의 소유에 속하는 토지 및 그 지상 건물에 관하여 공동저당권이 설정된 후 그 지상 건물이 철거되고 새로 건물이 신축된 경우에는 그 신축건물을 위한 법정지상권은 성립하지 않는다.
[판례해설] 토지에 대한 단독저당권의 설정 후 건물이 멸실되고 신축된 경우에는 당연히 법정지상권이 성립한다. 그 이유는 건물이 있는 상태에서 토지에 저당권을 설정 받은 자는 건물에 의한 토지가치의 제한을 인정한 것이기 때문이다.

09. 전세금의 지급은 전세권 성립의 요소가 되는 것이지만 그렇다고 하여 전세금의 지급이 반드시 현실적으로 수수되어야만 하는 것은 아니고 기존의 채권으로 전세금의 지급에 갈음할 수도 있다.

10. 전세권이 기간만료로 종료된 경우 전세권은 전세권설정등기의 말소등기 없이도 당연히 소멸한다.

11. 전세권설정계약의 당사자 사이에 그 계약이 합의해지 또는 존속기간이 만료된 경우 당사자 간의 약정에 의하여 전세권의 처분이 따르지 않는 전세금반환채권만의 분리양도가 이루어진 경우에는 양수인은 유효하게 전세금반환채권을 양수한 것으로 본다.

[판례해설] 전세권이 존속하는 동안에는 전세금반환채권만을 분리양도하는 것은 인정되지 않는다. 그러나 전세권계약의 합의해지 또는 존속기간이 만료된 경우에는 전세권은 담보적 권능을 갖게 되며, 전세금반환채권을 전세권과 분리하여 양도할 수 있다.

12. 전세권자의 전세목적물 인도의무 및 전세권설정등기 말소등기의무와 전세권설정자의 전세금반환의무는 서로 동시이행의 관계에 있다.

13. 건물의 일부에 대하여 전세권이 설정되어 있는 경우 그 전세권자는 그 건물 전부에 대하여 후순위권리자 기타 채권자보다 전세금의 우선변제를 받을 권리가 있고, 전세권설정자가 전세금의 반환을 지체한 때에는 전세권의 목적물의 경매를 청구할 수 있으나, 전세권의 목적물이 아닌 나머지 건물부분에 대하여는 경매 신청권이 없다.

14. 전세목적물의 소유권이 이전된 경우 목적물의 신 소유자는 구 소유자와 전세권자 사이에 성립한 전세권의 내용에 따른 권리의무의 직접적인 당사자가 되어 전세권이 소멸하는 때에 전세권자에 대하여 전세권설정자의 지위에서 전세금반환의무를 부담하게 된다.

15. 전세권의 법정갱신(제312조 제4항), 이는 법률의 규정에 의한 부동산에 관한 물권의 변동이므로 전세권갱신에 관한 등기를 요하지 않는다.

16. 타인 토지에 승낙 없이 분묘를 설치한 경우에는 20년간 평온·공연하게 그 분묘기지를 점유함으로써 분묘 기지권을 시효로 취득한다. 이 경우 지료는 유상이다.

17. 장사 등에 관한 법률(장사법)의 시행일인 2001. 1. 13. 이전에 타인의 토지에 분묘를 설치한 다음 20년간 평온·공연하게 분묘의 기지를 점유함으로써 분묘기지권을 시효로 취득하였더라도, 분묘기지권자는 토지소유자가 분묘기지에 관한 지료를 청구하면 그 청구한 날부터의 지료를 지급할 의무가 있다(대법원 2021.4.29. 2017다228007 전원합의체).

18. 자기 소유의 토지 위에 분묘를 설치한 후 토지의 소유권이 경매 등으로 타인에게 이전되면서 분묘기지권을 취득한 자가, 판결에 따라 분묘기지권에 관한 지료의 액수가 정해졌음에도 책임 있는 사유로 판결확정 전후에 걸쳐 2년분 이상의 지료지급을 지체한 경우, 새로운 토지소유자는 분묘기지권의 소멸을 청구할 수 있다.

19. 토지 및 그 지상 건물 모두가 각 공유에 속한 경우 토지 및 건물공유자 중 1인이 그 중 건물 지분만을 타에 증여하여 토지와 건물의 소유자가 달라진 경우에도 해당 토지 전부에 관하여 건물의 소유를 위한 관습법상 법정지상권이 성립된 것으로 보게 된다면, 이는 토지공유자의 1인으로 하여금 다른 공유자의 의사에 기하지 아니한 채 자신의 지분을 제외한 다른 공유자의 지분에 대하여서까지 지상권설정의 처분행위를 허용하는 셈이 되어 부당하다(대법원 2022. 8. 31. 2018다218601).

중요 지문 정리

01. 지상권자는 토지사용의 대가로서 지료를 지급하는 것이 보통이지만, 지료의 지급은 지상권의 성립요건이 아니므로 지료에 관한 약정이 없으면 무상의 지상권을 설정한 것으로 인정된다. ()

타당한 기술이다. (○)

02. 토지의 근저당권자가 주로 목적물의 담보가치가 감소하는 것을 막기 위하여 지상권을 취득하였다면 그 피담보채권이 변제로 소멸한 경우에는 그 지상권은 소멸한다. ()

2011.4.14 2011다6342 (○)

03. 지상권자가 토지소유권의 양도 전후에 걸쳐서 지료지급을 지체한 경우, 양도인과 양수인에 대하여 연체된 지료의 합이 2년분에 이르면 양수인은 지상권의 소멸을 청구할 수 있다. ()

대법원 2001.3.13 99다17142 (×)

04. 법정지상권의 경우 지료가 결정되지 않았다 하더라도 지료에 관하여 무상으로 하는 합의가 없는 한 지상권자가 지료를 지급하지 않았다면 지료지급의 지체가 된다. ()

법정지상권의 경우 당사자 사이에 지료에 관한 합의가 있었다거나 법원에 의하여 지료가 결정되었다는 아무런 증명이 없다면, 법정지상권자가 지료를 지급하지 않았다고 하더라도 지료지급을 지체한 것으로는 볼 수 없다. (×)

05. 민법상 지상권의 존속기간은 최단기만이 규정되어 있을 뿐 최장기에 관하여는 아무런 제한이 없으므로, 지상권의 존속기간을 영구로 약정하는 것도 허용된다. ()

대법원 2001.5.29 99다66410 (○)

06. 수목의 소유를 목적으로 하는 지상권은 수목이 멸실되면 소멸한다.

기존의 건물 기타의 공작물이나 수목이 멸실되더라도 존속기간이 만료되지 않는 한 지상권이 소멸되지 않는다. (×)

07. 무허가 또는 미등기건물을 소유하기 위한 관습법상의 법정지상권도 성립할 수 있다. ()

제254조 (○)

08. 근저당권이 설정된 나대지 소유자가 근저당권자의 동의를 얻어 그 지상에 건물을 신축하였다가 그 근저당권의 실행에 의하여 토지만이 제3자에게 낙찰된 경우 건물소유자는 낙찰자에 대하여 법정지상권을 취득한다. ()

대법원 2003.9.5 2003다26051 (×)

09. 동일인 소유의 토지와 그 지상건물에 관하여 공동저당권이 설정된 후 그 건물이 철거되고 다른 건물이 신축된 경우, 저당물의 경매로 인하여 토지와 신축건물이 서로 다른 소유자에게 속하게 되면 법정지상권이 성립한다. ()

대법원 2003.12.18. 98다43601 (×)

10. 미등기건물을 대지와 함께 매수하였으나 대지에 관하여만 소유권이전등기를 넘겨받고 대지에 대하여 저당권을 설정한 후 저당권이 실행된 경우에는 법정지상권이 성립하지 않는다. ()

대법원 2002.6.20 2002다9660 (○)

11. 관습상의 법정지상권이 성립하였으나 건물의 소유자가 토지의 소유자와 건물의 소유를 목적으로 하는 토지임대차계약을 체결한 경우에는 관습상의 법정지상권을 포기한 것으로 본다. ()

대법원 1992.10.27 92다3984 (○)

12. 강제경매의 목적이 된 토지 또는 그 지상 건물의 소유권이 강제경매로 인하여 그 절차상의 매수인에게 이전된 경우에는 매각대금의 완납시를 기준으로 토지와 그 지상 건물이 동일인에 속하였는지 여부를 판단한다. ()

강제경매의 목적이 된 토지 또는 그 지상 건물의 소유권이 강제경매로 인하여 그 절차상의 매수인에게 이전된 경우에는 매각대금의 완납시가 아니라 압류의 효력이 발생하는 때를 기준으로 토지와 그 지상 건물이 동일인에 속하였는지 여부를 판단한다(대법원 2012.10.18. 2010다52140). (×)

13. 대지와 건물이 동일한 소유자에 속한 경우에 건물에 전세권을 설정한 때에는 그 대지소유권의 특별승계인은 전세권자에 대하여 지상권을 설정한 것으로 본다. ()

대지와 건물이 동일한 소유자에 속한 경우에 건물에 전세권을 설정한 때에는 그 대지소유권의 특별승계인은 전세권설정자에 대하여 지상권을 설정한 것으로 본다. (×)

14. 지역권은 요역지 소유권에 부종하여 이전하며 또는 요역지에 대한 소유권 이외의 권리의 목적이 된다. 그러나 다른 약정이 있는 때에는 그 약정에 의한다. ()

제292조 제1항 (○)

15. 토지공유자의 1인은 지분에 관하여 그 토지를 위한 지역권 또는 그 토지가 부담한 지역권을 소멸하게 하지 못한다. ()

타당한 기술이다. (○)

- 16.** 지역권은 계속되고 표현된 것에 한하여 민법 제245조의 부동산 점유취득 시효에 관한 규정을 준용한다. ()
- 17.** 점유로 인한 지역권 취득기간의 중단은 지역권을 행사하는 모든 공유자에 대한 사유가 아니면 그 효력이 없다. ()
- 18.** 전세권 소멸 시 목적부동산의 인도 및 전세권설정등기의 말소등기에 필요한 서류의 교부의무와 전세금반환의무는 동시이행의 관계에 있다. ()
- 19.** 전세권자에게 책임 있는 사유로 전세권의 목적인 부동산이 일부 멸실된 경우 전세권설정자는 멸실된 부분만이 아니라 전세권 전부의 소멸을 청구할 수 있다. ()
- 20.** 건물의 일부에 대하여 전세권이 설정되어 있는 경우 그 전세권자는 전세권의 목적이 아닌 나머지 건물부분에 대하여는 경매신청을 할 수 없다. ()
- 21.** 전세권이 성립한 후 전세목적물의 소유권이 이전된 경우 전세권이 소멸하면 전세권자는 전 소유자에 대해서도 전세금반환을 청구할 수 있다. ()
- 22.** 전세권이 존속하는 동안에 전세권을 존속시키기로 하면서 전세금반환채권만을 전세권과 분리하여 확정적으로 양도할 수 없다. ()
- 23.** 타인의 토지에 있는 건물에 전세권을 설정한 때에는 전세권의 효력은 그 건물의 소유를 목적으로 한 지상권 또는 임차권에 미친다. ()
- 24.** 전세금의 지급은 전세권 성립의 요소이지만 전세금의 지급이 반드시 현실적으로 수수되어야만 하는 것은 아니고 기존의 채권으로 전세금의 지급에 갈음할 수도 있다. ()
- 25.** 건물의 일부에 대하여 전세권이 설정되어 있는 경우, 그 전세권자는 전세권의 목적이 된 부분이 구조상 또는 이용상 독립성이 없어 독립한 소유권의 객체로 분할할 수 없다면 그 건물 전부에 대하여 경매를 신청하여 전세금의 우선변제를 받을 수 있다. ()
- 26.** 전세권의 목적물을 전전세 또는 임대한 경우에는 전세권자는 전전세 또는 임대하지 아니하였으면 면할 수 있는 불가항력으로 인한 손해에 대하여 그 책임을 부담한다. ()

제294조 (○)

지역권의 불가분성(제295조) (○)

타당한 기술이다. (○)

타당한 기술이다. (○)

대법원 2001.7.2. 2001마212 (○)

목적물의 신 소유자는 구 소유자와 전세권자 사이에 성립한 전세권의 내용에 따른 권리의무의 직접적인 당사자가 되어 전세권이 소멸하는 때에 전세권자에 대하여 전세권설정자의 지위에서 전세금 반환의무를 부담하게 된다(대법원 2006.5.11. 2006다6072). (×)

타당한 기술이다. (○)

제304조 (○)

대법원 1995.2.10. 94다18508 (○)

대법원 2001.7.2 2001마212 (×)

제308조 (○)

◎ 단원별 출제경향

구 분	28회	29회	30회	31회	32회	33회	34회
담보물권	4	3	4	4	4	6	4

제1절 유치권

(1) 의의

타인의 물건 또는 유가증권을 점유하는 자가 그 물건이나 유가증권에 관하여 생긴 채권이 변제기에 있는 경우에 변제를 받을 때까지 그 물건 또는 유가증권을 유치하여 우선변제를 간접적으로 강제하는 법정담보물권을 말한다.

(2) 법률적 성질

- ① 법정담보물권이다.
- ② 부종성·수반성·불가분성이 인정되나 추급력과 물상대위성은 부정된다.
- ③ 우선변제권은 법적으로 부정되나 실질적으로는 인정되는 것과 같다.
- ④ 별채권이 인정된다(채무자회생 및 파산에 관한 법률)

(3) 유치권의 성립요건과 효력

성
립
요
건

- ① 유치권의 목적물은 부동산·동산·유가증권이다.
- ② 채권과 목적물과의 견련성이 있어야 한다. 그러나 채권과 '목적물의 점유'와의 견련성을 요하지는 않는다.
따라서 채권이 목적물에 관하여 발생한 경우라면 그 후 채권자가 그 목적물의 점유를 취득하더라도 유치권은 성립한다.
 - ㉠ 물건의 수선비청구권
 - ㉡ 목적물에 지출한 비용상환청구권
 - ㉢ 목적물로부터 받은 손해배상청구권
 - ㉣ 서로 물건을 바꾸어 간 경우
 - ㉤ 매매계약이 취소된 경우 부당이득에 의한 대금반환청구권
- ③ 채권이 변제기에 있어야 한다.

성 립 요 건	④ 점유가 계속되어야 한다. ㉠ 직접, 간접점유를 불문한다. ㉡ 불법행위로 인한 점유가 아니어야 한다. ⑤ 유치권의 발생을 배제하는 특약이 없어야 한다.	
효 력	유치권자의 권리	① 목적물을 유치할 수 있다. ② 경매권을 행사할 수 있다. ③ 간이변제충당권이 인정된다. ④ 과실수취권이 인정된다. 유치물의 과실을 수취하여 1차적으로 이자에 충당하고 2차적으로는 원본에 충당하여야 한다. ⑤ 유치물의 사용권이 있다. 유치물의 보존범위 내에서의 사용은 채무자의 승낙을 요하지 아니한다. ⑥ 비용상환청구권이 인정된다. 필요비용상환청구권은 전액을, 유익비용상환청구권은 지출금액 또는 증가액의 상환을 청구할 수 있다.
	유치권자의 의무	① 선량한 관리자의 주의의무로 유치물을 보관하여야 한다. ② 채무자의 승낙 없는 유치물의 사용 대여 담보제공행위는 할 수 없다. 채무자와 소유자가 동일인이 아닐 때에는 소유자의 승낙이 있어야 한다. 이러한 의무에 위반하면 소유자는 유치권의 소멸을 청구할 수 있다(제324조 제3항).

(4) 유치권의 소멸

- ① 유치권은 소멸시효에 걸리지 않으며 피담보채권이 소멸시효에 걸려 소멸하면 부종성에 의해 유치권도 소멸한다. 아울러 유치권의 행사는 피담보채권의 소멸시효진행에 영향을 미치지 아니한다.
- ② 유치권자가 그의 의무에 위반한 경우 채무자의 소멸청구로 유치권은 소멸한다.
예컨대, 유치권자가 소유자의 승낙 없이 목적물을 임대 또는 담보로 제공한 경우에 채무자가 의무위반을 이유로 유치권의 소멸을 청구하면 유치권은 즉시 소멸한다(제324조).
- ③ 다른 담보의 제공 또는 점유의 상실로 유치권은 소멸한다.

제2절 질권

(1) 의의

채권자가 그 채권을 담보하기 위하여 채무자 또는 제3자 소유의 동산 또는 권리를 채무가 변제될 때까지 유치함으로써 채무자를 간접적으로 강제하는 동시에 변제가 없는 경우에는 그 목적물로부터 우선적으로 변제받는 것을 내용으로 하는 약정담보물권이다.

(2) 법률적 성질

- ① 약정담보물권이다.
- ② 부종성·수반성·불가분성·물상대위성을 가진다.
- ③ 유치적 효력과 우선변제적 효력을 갖는다.

(3) 동산 질권

성립	계약당사자	채권자와 채무자 또는 제3자(물상보증인)이다.
	동산의 인도	① 현실의 인도, 간이인도, 반환청구권의 양도에 의한 질권의 설정도 인정하나 점유개정에 의한 설정은 부정된다. ② 점유개정에 의한 질권설정은 유치적 효력이 확보되지 않기 때문이다.
	객 체	① 양도할 수 없는 물건(금제물, 압류금지물 등)은 객체가 될 수 없다. ② 등기나 등록으로 공시되는 동산(선박·자동차·건설기계·항공기)은 저당권의 객체가 된다.
	피담보채권	담보물권의 부종성으로 인해 반드시 피담보채권의 존재를 요한다.
	법정질권	① 토지임대인의 법정질권(제648조) ② 건물 등의 임대인의 법정질권(제650조)
효력	효력이 미치는 목적물의 범위	· 명문의 규정은 없으나 아래와 같이 해석한다. ① 종 물

(4) 권리질권

권리질권은 채권 기타 재산권을 목적으로 하는 질권을 말한다(제345조 본문).

권리질권의 목적	① 재산권이어야 하며 금전적 가치로서 평가할 수 있는 것이어야 한다. 따라서 인격권·상속권·친족권 등은 인정될 수 없다. ② 양도성이 있는 재산권이어야 한다. 부양청구권·재해보상청구권·연금청구권 등은 인정될 수 없다. ③ 부동산의 사용·수익을 목적으로 하는 지상권·전세권 등은 권리질권의 목적이 될 수 없다. ④ 어업권·광업권·공장재단 등은 권리질권의 목적이 될 수 없다. 권리질권의 목적이 되는 것으로 대표적인 것은 주식, 채권, 지식재산권 등이다.
채권질권의 공시방법	① 지명채권: 합의와 채권증서의 교부(채무자에게 통지 또는 승낙은 대항요건) ② 지시채권: 합의와 배서 후 교부 ③ 무기명채권: 합의와 교부 ④ 저당권부채권: 합의와 부기등기

제3절 저당권

(1) 저당권의 의의 및 법률적 성질

① 의의

채무자 또는 제3자(물상보증인)가 점유를 이전하지 않고 채무의 담보로 제공한 물건에서 채권자가 우선변제를 받을 수 있는 약정담보물권이다.

② 법률적 성질

- ㉠ 약정담보물권이다.
- ㉡ 우선변제적 효력이 인정된다.
- ㉢ 물상대위성·불가분성·타물권·부종성·수반성이 있다.
- ㉣ 목적물의 점유를 수반하지 않는 권리이다.

(2) 저당권의 효력이 미치는 범위

피담보채권의 범 위	① 원본 ② 이자(변제기 이전의 이자는 제한 없이 담보된다) ③ 위약금(등기한 경우에 저당권에 의하여 담보된다.) ④ 채무불이행으로 인한 손해배상(지연배상·지연이자) ⑤ 저당권실행비용(감정평가비용·경매신청등록세 등의 비용)
---------------	--

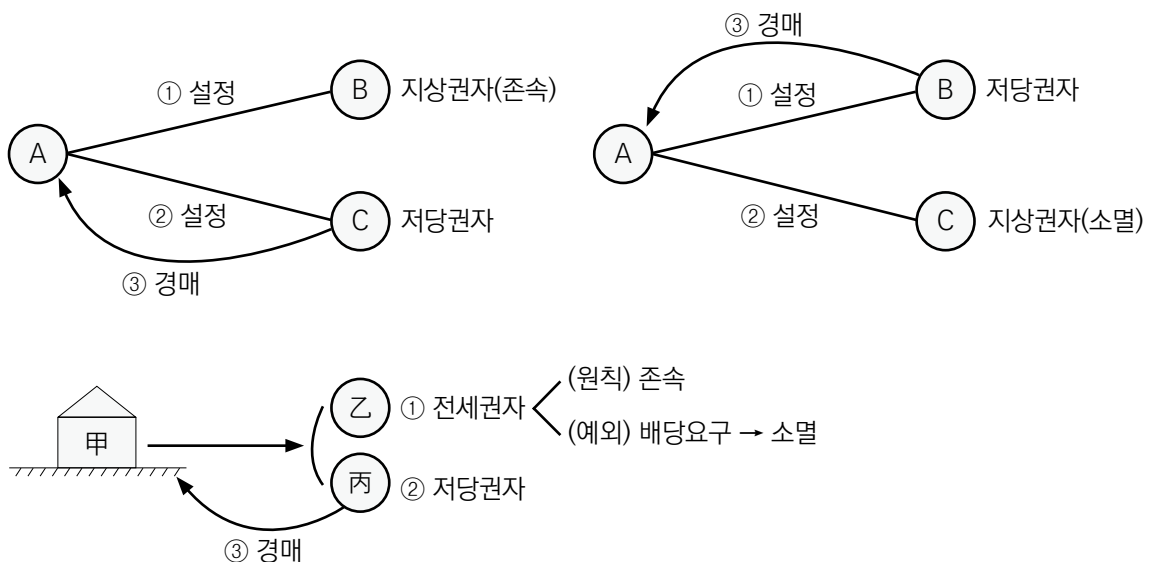
목적물의
범 위

- ① 저당권의 효력은 저당부동산에 부합(저당권의 설정전후를 불문)된 부합물과 종물에도 미친다. 예외적으로 설정계약에서 반대의 특약을 한 경우와 지상권자·전세권자 등이 부합한 물건에는 미치지 아니한다.
- ② 토지와 건물은 별개의 부동산이므로 저당목적 토지 위의 건물에는 저당권의 효력이 미치지 아니한다. 단, 설정자가 그 저당 토지 위에 건물을 축조한 경우에는 토지와 함께 건물에 대해서도 경매를 청구할 수 있으나 먼저 건물의 매각대금으로부터는 우선변제를 받지 못한다.
- ③ 과실에는 저당권의 효력이 미치지 않으나 저당권의 실행으로 목적물에 대한 압류가 있는 후에는 설정자가 수취하는 과실 또는 수취할 수 있는 과실에도 저당권의 효력이 미친다.
- ④ 저당권에도 물상대위성이 있으므로 저당목적물의 멸실·훼손·공용징수로 인하여 저당권설정자가 받을 금전 기타의 물건에 저당권의 효력이 미친다. 다만 이 경우에는 지급(인도)전에 반드시 압류하여야 한다.

(3) 저당권과 용익관계

- ① 저당권을 설정하기 전에 이미 제3자가 목적물에 관하여 저당권에 대항할 수 있는 용익권(지상권·지역권·전세권 및 등기된 임차권)을 가지고 있는 경우에는, 저당권이 실행되더라도 용익권자는 매수인(경락인)에게 대항할 수 있다. 다만, 그 중 전세권의 경우에는 전세권자가 경매절차에서 배당요구를 하면 매각으로 소멸한다(민사집행법 제91조).
- ② 용익권이 저당권의 실행에 의하여 소멸하느냐의 여부는 경매를 신청한 저당권자와의 우열이 아니라 그 부동산 위 최고 순위의 저당권과의 사이의 우열로 정하여진다. 후순위저당권의 실행으로 인해 선순위저당권도 소멸하고 선순위저당권자는 배당에 참여하여 우선변제를 받기 때문이다(민사집행법 제91조).

◆ 우선적 효력



(4) 저당권침해에 대한 구제

① 물건적 청구권

저당권자는 그 저당권에 의거하여 침해의 제거 또는 예방을 청구할 수 있다(제214조·제370조).
그러나 저당목적물의 반환청구권은 인정되지 아니한다.

② 손해배상청구권

저당권침해가 불법행위의 요건을 충족하면 저당권자는 손해배상을 청구할 수 있다(제750조).
그러나 침해에 의하여 담보가치가 감소되더라도 잔존부분에 의하여 완제가 가능한 경우에는 손해가 없으므로 손해배상청구권이 생기지 않는다.

그리고 손해배상을 청구함에는 저당권실행 전이라도 무방하다.

그 이전이라도 손해액을 산정할 수 있기 때문이다.

③ 저당물보충청구권

저당권설정자의 책임있는 사유로 인하여 저당물의 가액이 현저히 감소된 때에는,
저당권자는 설정자에 대하여 그 원상복구 또는 상당한 담보제공을 청구할 수 있다(제362조).
이 청구권을 행사하는 때에는 위의 손해배상청구권과 즉시변제청구권은 행사하지 못한다.

④ 즉시변제청구권

저당권의 침해가 채무자의 귀책사유로 인한 때에는 채무자는 기한의 이익을 상실하고,
저당권자는 즉시 변제를 청구할 수 있고 저당권을 실행할 수 있다(제388조 제1호).

제4절 공동저당

(1) 의 의

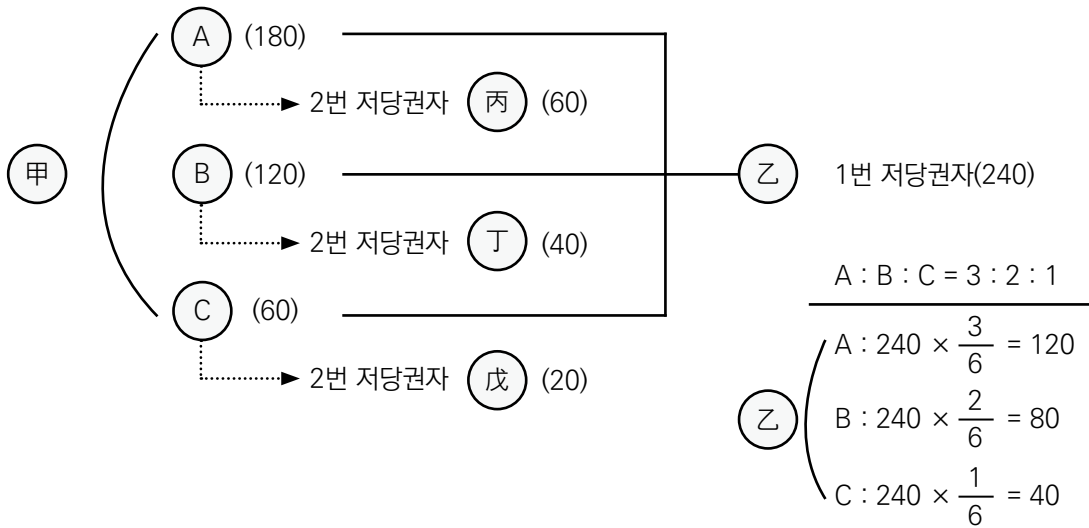
동일한 채권담보를 위하여 여러 개의 부동산 위에 설정되는 저당권으로서 불가분성의 예외가 된다.

(2) 실 행

① 동시배당: 공동저당권의 목적물을 전부 경매하여 동시에 배당하는 때에는 각 부동산의 경매대가에
비례하여 피담보채권액을 안분한다(제368조 제1항).

② 이시배당(순차배당): 공동저당의 목적물 중 일부만이 경매되어 그 대가를 먼저 배당하는 때에는 공동저
당권자는 전액변제를 받을 수 있으나, 그 부동산의 후순위저당권자는 선순위저당
권자가 동시배당하였더라면 다른 부동산의 경매대가에서 변제받을 수 있었던 한
도에서 선순위를 대위하여 저당권을 행사할 수 있다(제368조 제2항).

◆ 동시배당



제5절 근저당

(1) 근저당의 의의 및 설정

- ① 근저당은 거래에 따라 채권액이 증감하더라도 그 증감에 관계없이 결산기에 존재하는 채권을 미리 정한 최고액의 한도에서 담보하는 데 그 특색이 있다.
- ② 근저당을 설정하려면 기본이 되는 계속적인 용자계약을 하고 담보할 최고액을 정하여, 이에 관한 저당권설정계약과 등기를 하게 된다. 이 등기에는 반드시 근저당이라는 취지와 채권의 최고액을 등기하여야 한다.

(2) 근저당권의 효력

- ① 결산기에 저당권을 실행하여 우선변제를 받을 수 있는 액은 등기된 최고액의 범위 안에서 실제로 결산기에 존재한 채권액이다.
- ② 최고액이란 채권자(근저당권자)의 목적물에 대한 우선변제를 받을 수 있는 한도액을 의미하는 것이지 채무자의 책임의 한도액을 의미하는 것이 아니다.
- ③ 근저당권의 실행비용은 채권최고액에 포함되지 않으며 별도로 우선변제를 받는다.
- ④ 이자는 최고액 속에 산입된 것으로 보게 되므로 원본과 이자를 합한 것이 최고액을 넘으면 그 초과부분은 담보되지 못한다.

(3) 피담보채권의 확정

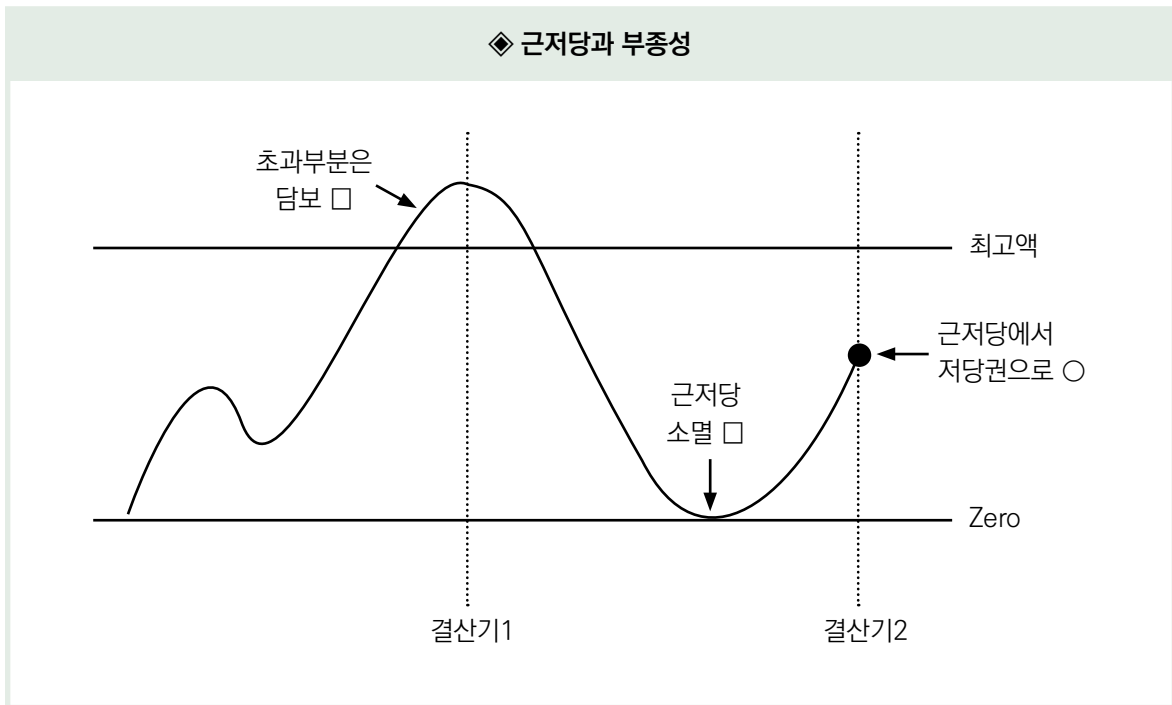
- ① 설정계약 또는 기본계약에서 규정한 결산기의 도래
- ② 근저당권의 존속기간이 있는 경우 존속기간의 만료
- ③ 기본계약 또는 설정계약이 해지 또는 해제된 때
- ④ 근저당권자가 경매를 신청하는 때
- ⑤ 채무자에 대한 회생절차의 개시결정이 있는 때
- ⑥ 제3자(후순위저당권자 등)가 경매 신청한 경우에는 매수인(경락인)이 매각대금을 완납한 때

(4) 근저당권의 처분

근저당권은 그 기초인 계약관계와 함께 양도할 수 있다. 그러나 그것은 근저당권자라는 지위의 변동을 생기게 하므로 근저당권자와 양수인 이외에 근저당채권의 채무자도 참가시킨 3면 계약으로 하여야 한다. 근저당의 양도는 등기함으로써 그 효력이 생긴다.

(5) 근저당권의 소멸

- ① 피담보채권이 확정되면 근저당권은 보통의 저당권과 동일하게 되고 그 이후에 발생하는 채권은 근저당권에 의해 담보되지 않는다. 예컨대 기본계약인 당좌대월계약에서 발생한 채무를 담보하기 위한 근저당권은 그 결산기가 도래한 이후에 발행된 약속어음상의 채권을 담보하지 않는다(판례).
- ② 피담보채권이 확정되기 전이라도 채권이 변제 등으로 소멸하거나 또는 거래의 계속을 원하지 않는 경우에는 근저당설정계약을 해지하고 설정등기의 말소를 청구할 수 있다.





핵심 판례 정리

- 01.** 건물의 임대차에 있어서 임차보증금반환청구권이나 임대인이 건물시설을 아니하기 때문에 임차인에게 건물을 임차목적대로 사용 못한 것을 이유로 하는 손해배상청구권은 모두 그 건물에 관하여 생긴 채권이라 할 수 없다.
- 02.** 임대인과 임차인 사이에 건물명도시 권리금을 반환하기로 하는 약정이 있었다 하더라도 그와 같은 권리금 반환청구권은 건물에 관하여 생긴 채권이라 할 수 없으므로 그와 같은 채권을 가지고 건물에 대한 유치권을 행사할 수 없다.
[판례해설] 임차보증금반환채권이나 권리금반환채권은 모두 그 건물에 관하여 생긴 채권이라 할 수 없으므로 유치권의 성립요건인 '채권과 목적물의 견련성'에 해당하지 아니한다.
- 03.** 주택건물의 신축공사를 한 수급인이 그 건물을 점유하고 있고 또 그 건물에 관하여 생긴 공사금 채권이 있다면, 수급인은 그 채권을 변제받을 때까지 건물을 유치할 권리가 있다.
[판례해설] 수급인이 자기의 재료와 노력(제작물공급계약)으로 제작·완성한 경우에는 유치권이 성립하지 않는다.
- 04.** 어느 부동산에 관하여 경매개시결정등기가 된 뒤에 비로소 점유를 이전받아 유치권을 취득한 사람은 경매 절차에서 그의 유치권을 주장할 수 없다(대법원 2017.2.8. 2015마2025).
- 05.** 물건의 인도를 청구하는 소송에서 피고의 유치권 항변이 인용되는 경우, 그 물건에 관하여 생긴 채권의 변제와 상환으로 물건의 인도를 명하여야 한다.
- 06.** 부동산의 점유가 불법행위로 인하여 시작되었을 경우에는 유치권이 성립하지 않는다.
- 07.** 건물의 임차인이 임대차 종료시에는 건물을 원상으로 복구하여 임대인에게 명도하기로 약정한 것은 건물에 지출한 각종 유익비 또는 필요비의 상환청구권을 미리 포기하기로 한 취지의 특약이라고 볼 수 있어 임차인은 유치권 주장을 할 수 없다.
- 08.** 구분건물의 전유부분만에 관하여 설정된 저당권의 효력은 대지사용권의 분리처분이 가능하도록 규약으로 정하는 등의 특별한 사정이 없는 한 그 전유부분의 소유자가 사후에라도 대지사용권을 취득함으로써 전유부분과 대지권이 동일 소유자의 소유에 속하게 되었다면, 그 대지사용권에까지 미친다.
- 09.** 저당권자는 설정자로부터 일탈한 저당목적물을 저당권자 자신에게 반환할 것을 청구할 수는 없다.
- 10.** 저당권설정자로부터 저당토지에 대한 용익권을 설정 받은 자가 그 토지에 건물을 축조한 경우라도 그 후 저당권설정자가 그 건물의 소유권을 취득한 경우에는 저당권자는 토지와 함께 그 건물에 대하여 일괄경매를 청구할 수 있다.

11. 채권자가 물상보증인 소유토지와 공동담보로 주채무자 소유토지에 1번 근저당권을 취득한 후 이와 별도로 주채무자 소유토지에 2번 근저당권을 취득한 사안에서, 먼저 주채무자의 토지에 대하여 피담보채무의 불이행을 이유로 근저당권이 실행되어 경매대금에서 1번 근저당권의 피담보채권액을 넘는 금액이 배당된 경우에는, 후순위(2번) 저당권자는 물상보증인 소유토지에 대하여 1번 근저당권을 대위행사할 수 없다.
12. 근저당권의 물상보증인은 채권최고액만을 변제하면 근저당권설정등기의 말소청구를 할 수 있고 채권최고액을 초과하는 부분의 채권액까지 변제할 의무가 있는 것이 아니다.
[판례해설] 채무액이 최고액을 초과한 경우, 물상보증인이나 목적물의 제3취득자는 채권최고액만을 변제하면 말소청구를 할 수 있으나, 채무자는 실제채무액 전부를 변제하여야 한다.
13. 근저당권이 설정된 후에 그 소유권이 제3자에게 이전된 경우에는 현재의 소유자가 자신의 소유권에 기하여 피담보채무의 소멸을 원인으로 그 근저당권설정등기의 말소를 청구할 수 있음은 물론이지만, 근저당권설정자인 종전의 소유자도 근저당권설정계약의 당사자로서 근저당권소멸에 따른 원상회복으로 근저당권자에게 근저당권설정등기의 말소를 청구할 수 있다.
14. 후순위 근저당권자가 경매를 신청한 경우 선순위 근저당권의 피담보채권은 그 근저당권이 소멸하는 시기, 즉 경락인이 경락대금을 완납한 때에 확정된다고 보아야 한다.
15. 근저당권자가 피담보채무의 불이행을 이유로 경매신청을 한 경우에는 경매신청시에 근저당 채무액이 확정되고, 위와 같이 경매신청을 하여 경매개시결정이 있는 후에 경매신청이 취하되었다고 하더라도 채무확정의 효과가 반복되는 것은 아니다.
16. 공동저당권이 설정되어 있는 수개의 부동산 중 일부는 채무자 소유이고 일부는 물상보증인 소유인 경우 각 부동산의 경매대가를 동시에 배당하는 때에는 민법 제368조 제1항은 적용되지 아니하고, 채무자 소유 부동산의 경매대가에서 공동저당권자에게 우선적으로 배당을 하고, 부족분이 있는 경우에 한하여 물상보증인 소유 부동산의 경매대가에서 추가로 배당을 하여야 한다.
17. 이미 소멸한 근저당권에 기하여 임의경매가 개시되고 매각이 이루어진 경우, 그 경매는 무효이다. 민사집행법 제267조(매수인의 부동산 취득은 담보권 소멸로 영향을 받지 아니한다)는 경매개시결정이 있는 뒤에 담보권이 소멸하였음에도 경매가 계속 진행되어 매각된 경우에만 적용된다(대법원 2022.8.25. 2018다205209 전원합의체).



중요 지문 정리

- 01.** 유치권의 성립요건이자 존속요건인 유치권자의 점유는 직접점유이든 간접점유이든 관계가 없으므로, 직접점유자가 채무자인 경우에도 유치권의 요건으로서의 점유에 해당한다. ()
- 02.** 임대인과 임차인 사이에 건물명도시 권리금을 반환하기로 하는 약정이 있었다 하더라도 그와 같은 권리금반환청구권은 건물에 관한 채권이라 할 수 없으므로, 그와 같은 채권을 가지고 건물에 대한 유치권을 행사할 수 없다. ()
- 03.** 채무자 소유의 건물 등 부동산에 강제경매개시결정의 기입등기가 경료되어 압류의 효력이 발생한 이후에 채무자가 위 부동산에 관한 공사대금 채권자에게 그 점유를 이전함으로써 그로 하여금 유치권을 취득하게 한 경우, 점유자로서는 위 유치권을 내세워 그 부동산에 관한 경매절차의 매수인에게 대항할 수 없다. ()
- 04.** 유치권자가 유치물의 보존에 필요한 사용을 한 경우에도 특별한 사정이 없는 한 차임에 상당한 이득을 소유자에게 반환할 의무가 있다. ()
- 05.** 유치권이 성립한 부동산의 매수인은 피담보채권의 소멸시효가 완성되면 시효로 인하여 채무가 소멸 되는 결과 직접적인 이익을 받는 자에 해당하므로 소멸시효의 완성을 원용할 수 있는 지위에 있다. ()
- 06.** 건물의 임차인이 임대차관계 종료시에는 건물을 원상으로 복구하여 임대인에게 명도하기로 약정하였다고 하더라도 임차인은 임대차 보증금을 반환받을 때까지 건물에 관하여 비용상환청구권이 있음을 전제로 하는 유치권을 주장할 수 있다. ()
- 07.** 유치권자는 정당한 이유가 있는 때에는 미리 채무자에게 통지함이 없이 감정인의 평가에 의하여 유치물로 직접 변제에 충당할 것을 법원에 청구할 수 있다. ()
- 08.** 유치권은 점유의 상실로 인하여 소멸한다. ()
- 09.** 유치권을 행사하면 채권의 소멸시효의 진행은 중단된다. ()

유치권은 목적물을 유치함으로써 채무자의 변제를 간접적으로 강제하는 것을 본체적 효력으로 하는 권리인 점 등에 비추어, 그 직접점유자가 채무자인 경우에는 유치권의 요건으로서의 점유에 해당하지 않는다(대법원 2008.4.11. 2007다27236). (×)

타당한 기술이다. (○)

대법원 2005.8.19. 2005다22688 (○)

대법원 2009.9.24. 2009다40684 (○)

대법원 2009.9.24 2009다39530 (○)

임대차관계 종료시에는 건물을 원상으로 복구하여 임대인에게 명도하기로 약정한 것은 건물에 지출한 각종 유익비 또는 필요비의 상환청구권을 미리 포기하기로 한 취지의 특약이라고 볼 수 있어 임차인은 유치권을 주장할 수 없다. (×)

정당한 이유가 있는 때에는 유치권자는 감정인의 평가에 의하여 유치물로 직접 변제에 충당할 것을 법원에 청구할 수 있다. 이 경우에는 유치권자는 미리 채무자에게 통지하여야 한다. (×)

타당한 기술이다. (○)

유치권의 행사는 채권의 소멸시효의 진행에 영향을 미치지 아니한다. (×)

- 10.** 유치권자는 채무자의 승낙 없이 유치물의 사용, 대여, 담보제공을 하지 못하고, 유치권자가 이에 위반한 때에는 채무자는 유치권의 소멸을 청구할 수 있다. ()
- 11.** 유치권자는 채권전부의 변제를 받을 때까지 유치물 전부에 대하여 그 권리를 행사할 수 있다. ()
- 12.** 유치권자는 유치물의 과실을 수취하여 다른 채권자보다 우선하여 자신의 채권의 변제에 충당할 수 있다. ()
- 13.** 질권은 원본, 이자, 위약금, 질권실행의 비용, 질물보존의 비용 및 채무불이행 또는 질물의 하자로 인한 손해배상의 채권을 담보한다. 그러나 다른 약정이 있는 때에는 그 약정에 의한다. ()
- 14.** 질권의 목적인 채권의 양도행위는 질권자의 이익을 해하는 변경에 해당하므로 질권자의 동의를 요한다. ()
- 15.** 저당권은 채무불이행으로 인한 손해배상도 담보하나, 지연배상에 대하여는 원본의 이행기일을 경과한 후의 1년분에 한한다. ()
- 16.** 피담보채권의 채권자가 아닌 제3자가 저당권자가 될 수 있는 경우가 있다. ()
- 17.** 근저당권설정자인 종전의 소유자는 목적물의 소유권을 상실하였으므로 계약상 권리에 따라 근저당권자에게 피담보채무의 소멸을 이유로 하여 그 근저당권설정등기의 말소를 청구할 수 없다. ()
- 18.** 건물의 소유를 목적으로 하여 토지를 임차한 사람이 그 토지 위에 소유하는 건물에 저당권을 설정한 때에는 저당권의 효력은 건물의 소유를 목적으로 한 토지의 임차권에도 미친다. ()
- 19.** 위약금은 저당권에 의하여 담보될 수 있다. ()
- 20.** 일괄경매청구권은 저당권설정자가 건물을 축조한 경우 뿐만 아니라 저당권설정자로부터 저당토지에 대한 용익권을 설정받은 자가 그 토지에 건물을 축조한 경우라도 그 후 저당권설정자가 그 건물의 소유권을 취득한 경우에는 저당권자는 토지와 함께 그 건물에 대하여 경매를 청구할 수 있다. ()

타당한 기술이다. (○)

유치권의 불가분성 (○)

제323조 제1항 (○)

제334조 (○)

질권의 목적인 채권의 양도행위는 질권자의 이익을 해하는 변경에 해당되지 않으므로 질권자의 동의를 요하지 아니한다. (×)

제360조 (○)

대법원 2009.11.26 2008다64478 (○)

종전의 소유자도 근저당권자에게 피담보채무의 소멸을 이유로 하여 그 근저당권설정등기의 말소를 청구할 수 있다. (×)

타당한 기술이다. (○)

제360조 (○)

대법원 2003.4.11. 2003다3850 (○)

- 21.** 저당권은 원본, 이자, 위약금, 채무불이행으로 인한 손해배상 및 저당권의 실행비용을 담보하고, 특히 지연배상에 대하여는 원본의 이행기일을 경과한 기간에 상관없이 저당권을 행사할 수 있다. ()
- 22.** 저당권은 그 담보한 채권과 분리하여 타인에게 양도하거나 다른 채권의 담보로 하지 못한다. ()
- 23.** 부동산의 일부 공유지분에 관하여 저당권이 설정된 후 부동산이 분할된 경우, 그 저당권은 분할된 각 부동산 위에 종전의 지분비율대로 존속하고, 분할된 각 부동산은 저당권의 공동담보가 된다. ()
- 24.** 구분건물의 전유부분만에 관하여 설정된 저당권의 효력은 특별한 사정이 없는 한 그 전유부분의 소유자가 사후에 취득한 대지사용권에까지 미친다고 할 수 없다. ()
- 25.** 근저당권자는 근저당권의 목적이 된 토지의 공용징수 등으로 인하여 토지의 소유자가 받을 금전이나 그 밖의 물건에 대하여 물상대위권을 행사할 수 있으므로, 토지의 소유자가 금전 등을 수령한 경우에도 물상대위권을 행사할 수 있다. ()
- 26.** 후순위 근저당권자가 경매를 신청한 경우 선순위 근저당권의 피담보채권은 그 근저당권이 소멸하는 시기, 즉 경락인이 경락대금을 완납한 때에 확정된다. ()
- 27.** 근저당권자가 피담보채무의 불이행을 이유로 경매신청을 한 경우에는 경매신청시에 근저당 채무액이 확정되고, 그와 같이 경매신청을 하여 경매개시결정이 있는 후에 경매신청이 취하되었다고 하더라도 채무확정의 효과가 반복되는 것은 아니다. ()
- 28.** 가등기담보 부동산에 대한 예약 당시의 시가가 그 피담보채무액에 미치지 못하는 경우에 있어서는 가등기담보 등에 관한 법률이 정하는 청산금 평가액의 통지 및 청산금 지급 등의 절차를 이행할 여지가 없다. ()
- 29.** 양도담보권자는 사용·수익할 수 있는 정당한 권한이 있는 채무자나 채무자로 부터 그 사용·수익할 수 있는 권한을 승계한 자에 대하여 사용·수익을 하지 못한 것을 이유로 임료 상당의 손해배상이나 부당이득반환청구를 할 수 있다. ()
- 30.** 양도담보 목적물이 소실되어 양도담보 설정자가 보험회사에 대하여 화재보험 계약에 따른 보험금청구권을 취득한 경우, 양도담보권자는 위 화재보험금청구권에 대하여 양도담보권에 기한 물상대위권을 행사할 수 있다. ()

제360조 (×)

타당한 기술이다. (○)

대법원 2012.3.29 2011다74932 (○)

구분건물의 전유부분만에 관하여 설정된 저당권의 효력은 대지사용권의 분리처분이 가능하도록 규약으로 정하는 등의 특별한 사정이 없는 한, 그 전유부분의 소유자가 사후에라도 대지사용권을 취득함으로써 전유부분과 대지권이 동일 소유자의 소유에 속하게 되면 그 대지사용권에까지 미친다. (×)

근저당권자는 근저당권의 목적이 된 토지의 공용징수 등으로 토지의 소유자가 받을 금전이나 그 밖의 물건에 대하여 물상대위권을 행사할 수 있으나, 다만 그 지급이나 인도 전에 압류하여야 한다. (×)

타당한 기술이다. (○)

대법원 2002.11.26. 2001다73022 (○)

타당한 기술이다. (○)

대법원 2008.2.28 2007다37394 (×)

대법원 2009.11.26. 2006다37106 (○)

